

論國際條約的國內法效力與法位階定序^{*}

—— 國際條約與憲法解釋之關係的基礎課題

李建良^{**}

目次

壹、問題意識：憲法秩序與國際規範的接軌之道？	三、國際條約在臺灣的內國法化模式
貳、基礎論述：國際條約的法源論與憲法解釋	伍、適用原則：國際條約之法位階與法適用問題
參、實務觀察：國際條約作為憲法解釋之法源依據？	一、國際條約之法位階定序
一、以國際條約作為增補人權的參據	二、不同位階之法適用問題
二、以國際條約作為審查標準的參據	三、相同位階之法適用問題
三、以國際條約作為宣告方式的參據	陸、案例研究：液晶顯示器(LCD)課徵關稅之法適用爭議
四、以國際條約作為解釋憲法的參據	一、事實背景與爭點整理
五、以國際條約作為解釋法律的參據	二、關稅法的課徵規範構造與法位階
六、小結	三、資訊科技協定(ITA)之性質與位階
肆、轉接模式：國際條約之形式合憲性與國內法效力	四、資訊科技協定(ITA)與HS註解之關係
一、憲法上之條約與形式合憲性問題：從司法院釋字第329號解釋談起	五、系爭函釋違反租稅法律主義
二、國際條約的內國法化模式與問題	六、系爭函釋違反法律優位原則
	七、小結
	柒、總結綜論：臺灣法律人的國際視野與法律思維

* 投稿日：2012年9月6日；接受刊登日：2013年1月25日。〔責任校對：陳嫻恬、向民潔〕。

** 中央研究院法律學研究所研究員。

穩定網址：<http://publication.iias.sinica.edu.tw/90501141.pdf>。



摘 要

憲政主義與人權保障的國際化與普世化，為當前國際人權法發展之趨勢，國際規範（尤其是條約）的認識、順應、折衝與接軌，為一國憲政發展不容忽視的課題。然而，憲政主義與人權保障的國際化及普世性不等於國際人權法的普世效力，國際規範亦非當然可以直接視為有法拘束力且具高位階之內國法規範。本文提出：「國際規範≠國內法≠高位階之國內法規範」的前設命題，嘗試從國際規範與憲法解釋互動關係之高度，觀察國際規範是否成為我國憲法解釋之法源；其次從學理、實務與法制面出發，分層探討國際條約的國內法效力與法位階之問題；最後以液晶顯示器(LCD)課徵關稅之法適用爭議為例，進行案例研究，期有助於我國憲法的解釋與法律的適用。身處全球化的時代，臺灣的法律人除了要有宏觀開闊的視野，更需要嚴謹縝密的法理思辨與分析能力，既不能無視於國際發展而渾然未覺，但也不能曲意盲從、隨聲附和。唯有如此，始能放眼世界、立足臺灣，走出屬於自己的憲法之路。

關鍵詞：國際法、國際條約、憲法解釋、人權、內國法化、一元論、二元論、法位階、法效力。

The Application and Status of International Treaties in Domestic Law:

Towards a Theory of the Relationship between
International Law and Constitutional Law

*Chien-Liang Lee**

Abstract

The widespread acceptance of both constitutionalism and the protection of human rights as universal values has been a remarkable global trend in tandem with the development of international human rights law. To pursue constitutional democracy nowadays, a country simply cannot do well without knowing, adapting, negotiating with, and incorporating into its legal system international law in general and international treaties in particular. However, this article argues that such developments do not necessarily entail that international law is directly applicable in a domestic legal system or can trump domestic law whatsoever. From this standpoint, this article enters the ongoing debate over the uses of international law in constitutional adjudication. Drawing insights from the relevant legal theories and legal practices, this article presents an in-depth analysis of the core jurisprudential issues as well as the institutional arrangements concerning the application and status of international treaties in domestic legal systems. It also studies the case about the customs duty on liquid crystal display (LCD) panels to shed light on the relationship between international law and domestic law in

* Research Professor, Institutum Iurisprudentiae, Academia Sinica.

Taiwan. For Taiwan's constitutional democracy to thrive in this era of globalization, this article calls on us—the jurists in Taiwan—to sharpen our reasoning, while thinking globally without losing sight of local contexts or surrendering our independent judgment.

KEYWORDS: international law, international treaty, constitutional interpretation (adjudication), human rights, the incorporation of international law, Monism, Dualism, the application of international law, domestic legal system, legal authority, sources of law.

壹、問題意識：憲法秩序與國際規範的接軌之道？

憲法作為一種法制度，乃近代憲政主義得以實踐的重要因素之一。憲法確立國家政體，決定國家組織型態，規範政府基本架構，並以保障人民基本權利為目的。憲法具有根本大法之性格，無可避免地必須保有「框架性規範」的特質，加上憲法的綱領性與規範性之學理論辯與法制差異，「法律」（立法）及「法院」（司法）爰成為落實憲政主義及人權理念的重要制度。正如因此，憲法的實踐必然與各國法政制度存有互為條件的緊密關係，同時受到所在政治處境與社會條件的制約與影響。然國與國之間向來互有連動，於今頻繁日益，密不可分，各國憲法的發展與實踐既要有本土關懷，亦須盱衡世局，順勢應時，不能自外於國際規範與全球互動，特別是憲政主義與人權保障的國際化與普世化，殆已蔚為一股明顯趨勢之今日，國際規範（尤其是條約）的認識、順應、折衝與接軌，允為一國憲政發展不容忽視的課題，對於以繼受外國法為宗的國家（例如臺灣）來說，尤其重要。

國際規範泰半是各國磋商、協調而成的產物。在樽俎折衝、壇坫週旋的過程中，不斷磨合異論、泯除歧見，進而打破或放棄既有法制的藩籬，趨近於識見與共的普遍規範。各國透過國際條約或宣言整合而成的共識，雖未必能絕對放諸四海而皆準，但至少也是一定程度的最大公約數，對於一國憲政體制與人權保障體系的充實與建構，無疑足以提供取捨損益的參照準據¹。然而，從嚴格的法思維來說，憲政主義與人權保障的國際化及普世性不等於國際人權法

¹ 司法院大法官解釋不乏參考、援引國際人權公約相關規定者，例如司法院釋字第587號解釋理由書開宗直述：「子女有獲知其血統來源之權利，為聯合國一九九〇年九月二日生效之兒童權利公約(Convention on the Rights of the Child)第七條第一項所揭載；確定父子真實身分關係，攸關子女之人格權，應受憲法第二十二條所保障。」本號解釋之意義，容後論述。

的普世效力，國際規範亦非當然可以直接視為有法拘束力且具高位階之內國法規範。國際規範有係置重於國家與國家之間的關係，亦有著眼於地域之特殊性者，故在汲取國際或跨國規範的內容時，除了必須留意國際法或區域法的關照取向外²，亦須究明國際規範（尤其是條約）或跨國區域法「是否」及「如何」成為一國的法規範之問題，包涵國際法在國內法的法效力及其法位階排序。唯有準確掌握此一屬於內國憲法與國際規範（尤其是條約）「接軌之道」的前提要素及核心議題，「國際化潮流下的憲法」方不致流於政治口號，或淪為盲從反智的學術語彙³。爰此，本文提出：國際規範≠國內法法拘束力≠高位階之國內法規範的前設命題⁴，嘗試先從國際規範與（內國）憲法解釋互動關係之高度⁵，觀察國際規範是

2 例如歐盟基本權利憲章第41條第4項規定，任何人與聯盟之機關接觸時，得使用公約所規定任何一種語言，處理之機關應以相同之語言答覆之。此一規定基本上係著眼於歐盟國家統一性及互通性的角度，是否移植於本國，即應考量實施的可能性。參見李建良，憲法人權清單改革芻議——「台灣基本權利憲章」草案初稿，收於：人權思維的承與變，頁579-581（2010年）。

3 本文旨在從制度規則與規範理論的思維基礎出發，力圖打破「國際條約當然有國內法效力」與「國際條約位階當然高於國內法」兩種形式主義或概念主義。唯有「先破」，而後「能立」。蓋在「國際條約當然有國內法效力」與「國際條約位階當然高於國內法」的形式主義之下，實無規範理論可言，更不可能有制度規則之開展。

4 本文在此提出的「前設命題」（國際規範≠國內法法拘束力≠高位階之國內法規範），係作為問題探討的基本出發點，而非結論，屬於一種「開放性」的命題。經由探討析論的結果，可能得出與前設命題相同的結論，當然亦不排除存在「國際規範=國內法法拘束力=高位階之國內法規範」見解的可能性（此種見解反而是一種「封閉性」的論斷）。抑且，從事物之本質而言，國際規範、國內法法拘束力、高位階之國內法規範，原本即屬不同之概念與事物，若要將此三者強行等而視之，反而要有更為堅實的理據，方足以支持。凡此正是本文之作所欲予深究廓清者。為免讀者誤會，爰先此說明，敬祈鑒察。

5 「內國法」與「國內法」是否同義，並無定說，多半互用，但亦有加以區分者，認為國際法下之municipal law，係國際法學者對國家內部或國內全部法律之泛稱，非指特定國家之法律，故宜稱「內國法」，以資與特定國家內部法律之「國內法」相區隔（參見姜皇池，國際公法導論，2版，頁285（2011年））。本文認為若要嚴予區分，固可採後一見解，然此係站在國際法之角度以言。本文研究的重點不在探討國際法與「各國」法律之關係，而是「我國」憲法或法律與國際法之關係，故除泛指各國法之一般性論述外，概以「國內法」指涉我國憲法或法律與國際法之關係。

否成為我國憲法解釋之法源；其次從學理、實務與法制面出發，分層探討國際條約的國內法效力與法位階之問題；最後以液晶顯示器(LCD)課徵關稅之法適用爭議為例，進行案例研究，期有助於我國憲法的解釋與法律的適用。按「國際法」或「國際規範」者，一般泛指條約、國際習慣、國際法上一般原則、國際法院裁判等，礙於篇幅，本文論述集中在國際條約，特先指明⁶。

貳、基礎論述：國際條約的法源論與憲法解釋

國際條約為國際法的一種，國際條約作為一種「法源」⁷，牽涉國際法的法源與國內法的法源兩種不同層次的問題。在國際法的層次，國際條約為國際法的法源(sources of international law)之一，殆無爭議⁸；條約的定義、名稱、訂定程序、生效要件等，主要以1969年簽署的「維也納條約法公約」(Vienna Convention on the Law

6 國際條約為國際規範之一種，不等於國際規範，乃國際法之基本常識。作者選擇以「國際條約」作為本文研究的重點，當然也是基於此一認知。作者並非有意忽略或不知在國際條約之外尚有其他之國際規範，更無國際條約之重要性高於其他國際規範的主觀預設。反而正因為國際規範多樣而繁雜，才應有所區隔、分門研究，切忌匱圖治於一爐，否則不僅不易有體系、深入、徹底並精緻的探討，甚而容易淪為大而化之、籠統而未必精確的論述或誤解。

7 「法源」一詞，基本上有「法之產生來源」(產生論)、「法之評價來源」(評價論)、「法之認識來源」(認識論)三種涵意。本文使用法源一詞指涉之內涵，依所處問題脈絡而定。關於「法源」的多種理解方式，參見李建良，*行政法基本十講*，4版，頁125-127（2013年）。

8 現代國際法的法源，主要以1945年國際法院規約(Statute of the International Court of Justice)第38條第1項規定為起點，即國際法院裁判得適用的依據，主要包括條約、國際習慣、文明國家共通承認之一般原則、司法裁判(判例)、權威學說見解等。此後，在國際實踐上，則還包括國際組織之決議等。參見黃昭元，*國際公法課程基準的檢討與反思：國際法法源、國際法與內國法關係*，台灣法學雜誌，181期，頁63（2011年）；Alain Pellet, *Article 38, in THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE: A COMMENTARY* 677, 735-83 (Andreas Zimmermann, Karin Oellers-Frahm, Christian Tams & Christian Tomuschat eds., 2006)。

of Treaties)⁹為規範基礎。國際條約的類型¹⁰、是否生效等，悉依國際規範與司法實踐，屬於國際法上法源問題，也就是以國際社會為空間領域所自成的一種「跨國性法域」。各國對於國際法的法源，雖仍可保有本國的觀點或立場，但某種程度上觸及國際法（條約）作為國內法法源的層面問題，必須作「國內法（特別是憲法）取向」的思考與探討，方不致有所偏失。簡要表述如下：

國際條約作為一種「法源」的兩種層次：

—國際法的法源

—國內法的法源

國際法的層次：條約的定義、名稱、訂定程序、生效要件等？

→「跨國性法域」之法源：依國際規範與司法實踐

國內法的層次：條約於國內法之地位？是否及如何成為國內法？

→「一國性法域」之法源：本文探討重點

國際條約為國際法的法源之一，並不當然成為國內法的法源。國際條約是否成為國內法的法源，乃國際法之存在所衍生的國內法問題。精確的說，涉及的是國際法的憲法問題，探討之前，必須先分辨以下幾個不同的課題與思維層次：

一、國際條約是否發生國際法上的效力？

凡涉國際條約之效力者，首須探究其與國際法上之條約定義、名稱、訂定程序、生效要件之關係等問題，例如國際條約是否完成簽署、批准、存放程序¹¹？此為國際條約是否成為國內法法源的

9 1980年1月27日生效(1155 U.N.T.S. 331)。

10 根據維也納條約法公約第2條第1項a款規定：條約，指國家(States)之間簽訂的任何國際書面協定(international agreement in written form)，不問名稱為何。依照各國實踐，國際條約的名稱有：條約(Treaty)、公約(Convention)、議定書(Protocol)、協定(Agreement)、辦法(Arrangement)、議事記錄(Procès-verbal)、規約(Statute)、宣言(Declaration)、換文(Exchange of Notes or Letters)、最後議定書(Final Act)、總議定書(General Act)、同意記錄(Agreed Minutes)等。

11 我國雖已批准公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約（所謂「兩公約」），但並未完成將批准書送至聯合國秘書長處存放(deposit)之程序，

「前階性」課題¹²。

二、國際條約是否及如何具有國內法的效力？

國際條約在國際法上無論生效與否，皆非必然成為國內法，是否及如何具有國內法的效力涉及「轉換」理論與機制，此為國際條約是否成為國內法法源的「要件性」及「（取得）法效力」課題→憲法解釋的課題之一，通常包含以下的子問題：

（一）國際條約是否一經生效，即成為國內法？

（二）國際條約是否須經內國機關（例如國會）的審議通過，始成為國內法？

（三）國際條約除經內國機關（例如國會）的審議通過外，是否尚須轉換成為法律條文，始成為國內法？

（四）國際條約可否不經內國機關（例如國會）的審議通過，直接經法律明定成為內國法？

國際條約「內國法化」的四種模式，何者為妥，基本上可進行學理分析與制度比較¹³，但此一問題並非單純國際法上學說或觀點的探討，毋寧強烈具有「國內法取向」¹⁴。

故嚴格而言，兩公約在「國際法上」尚未生效。至於公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法第2條明定：「兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法律之效力。」亦即不問兩公約是否送至聯合國存放，均有國內法效力，則屬國內法層次之問題（容後探討），非可由此反推兩公約於國際法上業已生效。

¹² 在邏輯上，此「前階性」課題可能帶出兩種問題：一、「已生效」之國際條約如何成為國內法？二、「未生效」之國際條約如何成為國內法？

¹³ 例如德國基本法第25條規定：「國際法上之一般原則為聯邦法之一部分。其優先於法律，且直接對聯邦區域內之居民產生權利與義務。」惟其僅針對「國際法上之一般原則」，而不及於成文之國際條約。

¹⁴ 在國際法學上，國際法與國內法之關係，向有「一元論」與「二元論」之爭辯，一般（中外文）國際法之教科書中均有介紹，國內也有頗多探討之文獻，可資參照，本文不擬詳論，僅作必要之說明，作者研究之重點毋寧是從我國法制與實務出發，尋繹歸納出國際條約內國法化（國際規範臺灣法化）之途徑，並探討其相關問題。有關一元論與二元論的文獻資料，主要如下：姜皇池（註5），頁285-293；俞寬賜，國際法新論，頁61-65（2002年）；丘宏達，現代國

三、國際條約成為國內法的憲法上要件？

國際條約「內國法化」模式的探討，係從制度設計與模式改革的角度出發，國際條約內國法化的要件與模式，尚須觀照各國憲法的規範框架，此為國際條約是否成為國內法法源的「形式合憲性」課題→憲法解釋的課題之二。

四、國際條約成為國內法後，其效力是否高於其他國內法？

國際條約成為國內法，具有國內法的效力之後，接續的問題是，國際條約與其他國內法的位階關係為何，此為國際條約成為國內法法源的「法位階」課題→憲法解釋的課題之三，至少包含以下的子問題：

（一）國際條約是否具有憲法位階？

（二）國際條約是否屬於一種「特別法」，而適用「特別法優於普通法」之法理？

（三）國際條約與「後法優於前法」原則之關係為何？

五、國際條約成為國內法後，是否抵觸憲法？

國際條約是否成為國內法，與國際條約的內容是否合憲，乃屬二事。縱使國際條約具有憲法位階，亦有可能因變更「憲法中具有本質之重要性而為規範秩序存立之基礎」（例如抵觸民主憲政之基

際法，修訂2版，頁110-111（2006年）；廖福特，國際人權條約內國法化與地方自治體，台灣國際法季刊，7卷2期，頁78-88（2010年）；王震宇，WTO與區域貿易協定之締結與適用——從最高行政法院九十六年度判字第一九八六號判決談起，月旦法學雜誌，195期，頁272（2011年）；陳長文，國際法之回顧與展望——以超國界法律角度檢視，月旦法學雜誌，200期，頁102（2012年）；Heinz Wagner, Monismus und Dualismus: Eine methodenkritische Betrachtung zum Theorienstreit, AöR 89 (1964), S. 212 (212 ff.); Andrzej Wasilkowski, *Monism and Dualism*, in *THEORY OF INTERNATIONAL LAW AT THE THRESHOLD OF THE 21ST CENTURY: ESSAYS IN HONOUR OF KRZYSZTOF SKUBISZEWSKI* 323, 323-30 (Jerzy Makarczyk ed., 1996).

本原則)而構成違憲¹⁵，此為國際條約成為國內法法源的「實質合憲性」課題→憲法解釋的課題之四。

以上問題與課題，係建立在規範體系與位階次序的基本構造之上。簡要言之，國際條約必須先發生國內法的效力（有無效力），其次判定其與國內法之間的效力位階關係（效力高低），再者是規範內涵與憲法的合致關係（合憲與否）。跳脫金字塔式的規範階層思維框架，國際條約作為國內法的法源，尚有另一重要課題：

六、國際條約能否直接透過法院的援引（尤其是憲法解釋）而成為國內法？其效力為何？

前述國際條約成為國內法之情形，不問轉換模式為何，基本上是透過某種意義或形式的「立法程序或行為」，國際條約一經轉換後，即取得「法規」的性質，被納入國內法規體系之中。若將憲法第80條：「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」規定中之「法律」¹⁶，作廣義的理解，則法官必須依據業經法定轉換程序成為國內法的國際條約獨立審判。換言之，除聲請大法官釋憲外，法官受內國法化之國際條約（內國法律）的拘束（國際條約的被動適用）¹⁷。與此不同者，乃大法官或法官「主動」援引「未經內國法化」之國際條約，作為解釋或補充國內法的依據，產生或個案或通案的效力（國際條約的主動引用）。就此情形，值得探討者，乃大法官或法官得否將國際條約直接透過援引（尤其是憲法解釋）而成為國內法？經援引之國際條約與國內法之關係為何？其效力、位階又如何？→憲法解釋的課題之五。

以上基於國際條約所生之五項憲法解釋課題，其中「條約之實

¹⁵ 參見司法院釋字第499號解釋。

¹⁶ 憲法第80條所稱「法律」，從體系及目的解釋，顯非僅指憲法第170條所定：「本憲法所稱之法律，謂經立法院通過，總統公布之法律。」至少還包括憲法及總統發布的緊急命令。

¹⁷ 參見司法院釋字第371號解釋。

質合憲性問題」，理論上可能，但實際上鮮少發生¹⁸，故本文僅探討其餘四項課題，先此敘明。

參、實務觀察：國際條約作為憲法解釋之法源依據？

關於國際條約與憲法解釋之關係，或許可以從上述的第五個課題談起，也就是國際條約能否直接透過法院的援引（尤其是憲法解釋）而成為國內法？其效力為何？此一問題之所以重要，乃因臺灣的特殊國家屬性與國際地位，無法直接參與國際條約的締結，除了少數條約外（詳見後述），臺灣通常不是國際條約的締約國。因此，國際條約的內國法化，往往不是透過簽署、批准等程序，毋寧以直接援引（自願受拘束！）較為常見。此種把國際條約當成「參考文獻」的作法，從法源論的角度應如何理解，饒負實務運用的價值及學理探索的況味。受限於本文題旨，僅先以司法院大法官解釋為素材，進行初步的觀察與分析。

檢索歷來大法官解釋中提及國際規範者（參見「附錄一：有關國際規範之司法院解釋（一）」），略可得出以下六種模式：

1. 以國際條約作為增補人權的參據（司法院釋字第372、582、

¹⁸ 條約之實質合憲性問題，實際上鮮少發生，並不表示不可能發生，近期爭議頗鉅的「兩岸經濟合作架構協議」(Economic Cooperation Framework Agreement, 下稱ECFA)，即是一例，值得探討。ECFA屬於WTO架構下自由貿易協定的一環，攸關臺灣在國際上的經貿談判及內國之政經社文結構。姑且不問其內涵為何，單從此一協議之簽訂所牽動的臺灣國格與主權地位問題，即有可能牴觸憲法國民主權原則之疑義，此所以民間團體推動公民投票的主要原因。實務上，公民投票主管機關一再否決公民投票的提出，因而引發接連的行政爭訟，亦足以凸顯反襯出ECFA存有憲法上之重大疑義。相關問題及實務裁判分析，可參見李建良，依「辭海」審判的行政法院——北高行99年度ECFA公投判決的法治警訊，台灣法學雜誌，182期，頁63以下（2011年）；李建良，依「憲法」審判的行政法院——最高行101年度ECFA公投判決的民主底蘊，台灣法學雜誌，209期，頁1以下（2012年）。

- 587、623號解釋)。
2. 以國際條約作為審查標準的參據（司法院釋字第591、623、678、689號解釋）。
 3. 以國際條約作為宣告方式的參據（司法院釋字第549、578號解釋）。
 4. 以國際條約作為解釋憲法的參據（司法院釋字第392、582號解釋）。
 5. 以國際條約作為解釋法律的參據（司法院釋字第428號解釋）。
 6. 以國際組織之意見作為法律解釋適用之準據（司法院釋字第690號解釋）。

以上第5、6種模式，可合稱為「以國際條約作為解釋法律的參據」（參見「附錄二：有關國際規範之司法院解釋（二）」）。

一、以國際條約作為增補人權的參據

司法院大法官首次在解釋中提及國際條約者，應推司法院釋字第372號解釋理由書：

「人格尊嚴之維護與人身安全之確保，乃世界人權宣言所揭示，並為我國憲法保障人民自由權利之基本理念。憲法增修條文第九條第五項規定：『國家應維護婦女之人格尊嚴，保障婦女之人身安全，消除性別歧視，促進兩性地位之實質平等』即在宣示上述理念。此一憲法意旨，於婚姻關係及家庭生活，亦有其適用，業經本院釋字第三六五號解釋釋示在案。」

本號解釋援引世界人權宣言，闡釋人格尊嚴及人身安全為憲法所保障，雖未指明條文並作闡述，但大法官旨在創設憲法未明文的「人格尊嚴」與「人身安全」兩種基本人權，則至為明顯。從引據的方式來看，世界人權宣言只是作為「參考依據」，而非上述基本人權的「規範基礎」或「直接法源」。人格尊嚴（或「人性尊嚴」）為憲法所保障的完整論述，見諸於司法院釋字第603號解釋：

「維護人性尊嚴與尊重人格自由發展，乃自由民主憲政秩序之核心價值。隱私權雖非憲法明文列舉之權利，惟基於人性尊嚴與個人主體性之維護及人格發展之完整，並為保障個人生活私密領域免於他人侵擾及個人資料之自主控制，隱私權乃為不可或缺之基本權利，而受憲法第二十二條所保障（本院釋字第五八五號解釋參照）。」

在本號解釋中，大法官未引用任何國際條約，直接將人性尊嚴高懸為「自由民主憲政秩序之核心價值」，再結合憲法第22條，作為肯認隱私權為基本權利的基礎；「人身安全」則於司法院釋字第689號解釋改稱「免於身心傷害之身體權」，大法官承認其為憲法上之權利，同樣亦是以憲法第22條為依據，未提及國際條約。人性尊嚴的保障雖見諸於世界人權宣言¹⁹，惟人性尊嚴之所以為我國憲法所保障，實出於人的尊嚴具有「原權」的屬性，先於國家而存在，與世界人權宣言是否為憲法（國內法）的法源無直接關聯。至於二次戰後，部分國家制定憲法明定人性尊嚴保障條款，例如德國基本法第1條第1項，則是人性尊嚴保障的入憲化及成文化的表現，非得謂之為國際條約直接作為國內法的法源²⁰。況且，德國基本法第1條第1項不但保障人性尊嚴，更賦予「不容侵犯」的絕對性格，與世界人權宣言第1條僅規定：「人人生而自由，在尊嚴及權利上一律平等」，非可同日而語²¹。另須指出者，細究上揭解釋的文句，大法官並未將人性尊嚴認定為一種「基本權利」，而是所有基本權利的「核心價值」。因此，嚴格而言，大法官是否援引國際條約增補了人

19 人性尊嚴出現在憲法條文，首見於1937年7月1日愛爾蘭憲法的前言，早於世界人權宣言。

20 有謂：「世界人權宣言，可以說是各國在憲法與國際人權法匯流中最常被引用之國際人權法法源。而人格尊嚴之保護，亦首見於此一宣言，而後來被許多戰後國家新制定之憲法所接納，德國基本法就是其中一個典型的例子。」（參見張文貞，憲法與國際人權法的匯流——兼論我國大法官解釋之實踐，收於：廖福特編，憲法解釋之理論與實務第六輯（上冊），頁262（2009年）），不無誤會。

21 2000年12月8日公布之「歐盟基本權利憲章」，則受德國基本法之影響，其第1條人性尊嚴的保障規定同於德國基本法第1條第1項及第2項。

權清單，尚難斷言²²。

司法院大法官解釋中具有「創設」基本權利的解釋，要屬司法院釋字第587號解釋，解釋理由書的第一段明揭：

「子女有獲知其血統來源之權利，為聯合國一九九〇年九月二日生效之兒童權利公約(Convention on the Rights of the Child)第七條第一項所揭載；確定父子真實身分關係，攸關子女之人格權，應受憲法第二十二條所保障。」

本件釋憲案的主要爭點在於民法有關禁止子女提起否認生父之訴的規定是否違憲，此一爭議的前提問題在於系爭規定限制子女何種憲法上之權利？大法官於解釋文明白肯認「子女獲知其血統來源，確定其真實父子身分關係，攸關子女之人格權，應受憲法保障」，至於此一權利是否受有限制，則屬另一問題²³。較須費思的是，此一權利的憲法規範基礎何在？在上舉的理由書中，前段實僅引述兒童權利公約第7條第1項有關「知悉……父母之權利」(the right to know....his or her parents)的規定；後段則援引憲法第22條，將「確定父子真實身分關係」(獲知血統來源)納為一種「人格

22 關於人性尊嚴是否為一項獨立基本權的爭議，參見李建良，自由、平等、尊嚴——人的尊嚴作為憲法價值的思想根源與基本課題，收於：人權思維的承與變，頁45-46（2010年）。

23 有學者批評：「倘若大法官確知此一權利在國際法上的相關討論，一定會進一步發現此一權利當然並非絕對，在許多情況下都可能因為其他公益考量或相衝突之基本權而必須受到限制。例如，在特殊情況（如亂倫、強暴）下出生或出養之子女，或在人工協助生殖科技下，因人工捐贈之精卵而出生之子女，是否都有獲知其血統來源之權利？許多對於人工協助生殖科技採取開放態度之國家，在批准或加入兒童權利公約時，即對子女此一權利有相當多之聲明、甚至是保留，東歐國家中之捷克、波蘭即為適例。大法官在本件解釋，表面上是援引兒童權利公約的規定，但實際上並未對此一公約之內涵，以及在該公約之下對此一權利之定位與論辯多所討論，也容易使人滋生對此一公約所保護權利之誤解。」（參見張文貞（註20），頁262）。實則，在特殊情況（如亂倫、強暴）下出生或出養之子女，或在人工協助生殖科技下，因人工捐贈之精卵而出生之子女，是否享有獲知其血統來源之權利，屬於權利是否受限制之問題（須有憲法上之正當性），與獲知其血統來源之權利是否為憲法上保障的基本權，乃屬二事。此項見解不無混淆「是否承認憲法上之權利」與「該權利是否應受限制」兩種不同層次的問題。

權」。綜合以觀，兒童權利公約仍只是「參考依據」，真正構成「獲知血統來源之權利」的憲法規範基礎為憲法第22條，而且依附於人格權之下。至於該理由書後段所述：「……為貫徹前開憲法意旨，應肯認確定真實血統關係，乃子女固有之權利，外國立法例如德國舊民法原已規定在特殊情形子女得以補充地位提出否認生父之訴，一九九八年德國民法修正時配合聯合國兒童權利公約之規定，更明定子女自己亦得提起此項訴訟（德國民法第一六〇〇條、第一六〇〇a條、第一六〇〇b條參照），瑞士民法第二五六條、第二五六c條亦有類似規定，足供參考。」其中指德國民法修正係配合「聯合國兒童權利公約」之規定，易生德國係受國際條約之影響始承認「獲知血統來源之權利」的誤解。實則，「獲知血統來源之權利」（das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung），在德國係於1989年1月31日由聯邦憲法法院所承認，並宣告親屬法有關禁止成年子女提起否認血統來源訴訟之規定違憲。當時，兒童權利公約尚未生效²⁴，聯邦憲法法院透過基本法第2條第1項之一般人格權，再加上人性尊嚴保障條款推導出「獲知血統來源之權利」²⁵。

大法官另一次援引兒童權利公約，見於司法院釋字第623號解釋理由書第1段及第5段，內容如下：

「兒童及少年之心智發展未臻成熟，與其為性交易行為，係對兒童及少年之性剝削。性剝削之經驗，往往對兒童及少年產生永久且難以平復之心理上或生理上傷害，對社會亦有深遠之負面影響。從而，保護兒童及少年免於從事任何非法之性活動，乃普世價值之基本人權（聯合國於西元一九八九年十一月二十日通過、一九九〇年九月二日生效之兒童權利公約第十九條及第三十四條參照），為重大公益，國家應有採取適當管制措施之義務，以保護兒童及少年

²⁴ 兒童權利公約於1989年11月20日通過、1990年9月2日生效。

²⁵ BVerfGE 79, 256 (268 f.). 其後之裁判：BVerfGE 90, 263 (270 f.); BVerfGE 96, 56 (63). 參見Christian Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Bd. 1, 6. Aufl., 2010, Art. 2 Abs. 1 Rn. 107.

之身心健康與健全成長。兒童及少年性交易防制條例第一條規定：『為防制、消弭以兒童少年為性交易對象事件，特制定本條例』，目的洵屬正當。」（粗體為作者所強調）

「保護兒童及少年免於因任何非法之性活動而遭致性剝削，乃普世價值之基本人權，為國家應以法律保護之重要法益，上開規定以刑罰為手段，取締促使人為性交易之訊息，從根本消弭對於兒童少年之性剝削，自為達成防制、消弭以兒童少年為性交易對象事件之立法目的之有效手段；又衡諸保護兒童及少年免於從事任何非法之性活動之重大公益，相對於法律對於提供非法之性交易訊息者權益所為之限制，則上開規定以刑罰為手段，並以傳布以兒童少年性交易或促使其為性交易為內容之訊息，或向未滿十八歲之兒童少年或不特定年齡之多數人傳布足以促使一般人為性交易之訊息為其適用範圍，以達防制、消弭以兒童少年為性交易對象事件之立法目的，尚未逾越必要合理之範圍，與憲法第二十三條規定之比例原則，並無抵觸。」（粗體為作者所強調）

從「保護兒童及少年免於從事任何非法之性活動，乃普世價值之基本人權」等語以觀，表面上，大法官似乎是引用國際條約揭示新的「國際人權」，實則不然。蓋兒童權利公約第19條及第34條係以締約國為規範對象，課予各締約國保護兒童及少年免於從事任何非法性活動或採取必要保護措施之「義務」。對於應受保護的兒童及少年而言，該公約本身並未賦予其「基本人權」，毋寧是課予「國家保護義務」。在憲法人權理論上，基本人權與國家保護義務既非同一概念，亦非立於直接相對的關係。基本人權固為國家保護義務的基礎與對象，國家亦可能基於保護之目的而限制被保護者之基本人權²⁶。從上揭理由書的論理脈絡及釋憲結論以觀，大法官援引

²⁶ 凡此之類，例不勝舉，司法院釋字第664號解釋有關少年事件處理法有關剝奪「逃家、逃學」少年「人身自由」規定合憲的理由構成，即為一例。相關分析，參見李建良，學之逃、家之逃、法之逃？／釋字六六四號解釋，台灣法學雜誌，140期，頁151-164（2009年）。

兒童權利公約，旨在認定系爭兒童及少年性交易防制條例中「以刑罰手段」禁止大眾傳播媒體刊登或傳播足以誘使兒童或少年為性交易之規定，規範目的正當、手段有效。換言之，大法官係以國際條約作為違憲審查標準之理據，並得出合憲之結論。

二、以國際條約作為審查標準的參據

人民權利的限制，應有法律之依據，為憲法第23條所明定。此項法律保留原則的保障旨趣在於，人民權利應否受到限制及其範圍，須由經人民選出、代表民意的立法機關予以決定，民主原則與法律保留原則互為條件，故此所謂之「法律」，基本上係以國內法為基礎²⁷。換言之，在法律保留原則之下，限制人民基本權利的法規範，必須經過內國的「立法程序」或具有「內國民主正當性」，故未經內國法化程序之國際條約非得作為限制人民基本權利之直接法源，尤不得直接成為行政機關或司法機關限制人民基本權利的依據²⁸。因此，國際條約至多可以作為限制人民權利正當性事由的補強論證。就此而言，在上舉司法院釋字第623號解釋理由書中，大法官所援引之兒童權利公約，即只能理解為審查限制言論自由（禁止大眾傳播媒體刊登或傳播足以誘使兒童或少年為性交易）規定是否正當之準據，而非作為限制之法源。

進一步論之，大法官將國際條約引為操作「比例原則」的準

²⁷ 姑不論是否授權行政機關以命令補充之。

²⁸ 國際規範作為一國直接之法源者，目前僅存於區域性的跨國協定。例如在歐洲聯盟（歐盟）的法領域中，歐盟規則(Regulation, Verordnung)具有直接、一般的拘束效力。歐盟以規則規定之事項，原則上各成員國不再享有自主的規範權。僅於例外情形，得在歐盟規則之授權下自行制定。例如2001年3月19日由歐洲議會及理事會通過的（第二次）「歐盟環境治理規則」(EU-EMAS-Regulation)，即賦予各成員國自主的規範權。德國依此一授權於2002年4月9日制定公布「環境治理法」(Umweltauditgesetz)。參見李建良，歐盟環境法的演進與發展——從經濟合作到環境共榮，法學叢刊，55卷4期，頁106-107（2010年）。

據，就「目的審查」而言²⁹，應無扞格。各國欲透過締結條約共同解決的問題，目的洵屬正當，大法官所謂之「普世價值」，若指涉目的正當的層面，恰如其分³⁰。惟就手段是否適當、必要、合理來說，卻未必允妥。蓋手段與目的之關聯，非能作一般、抽象式的思維與審斷，而須針對立法者所選用的限制手段、其限制之程度等，進行各別的審查，在此並無所謂的「普世價值」可言。大法官若援引國際條約直接貫串比例原則各次原則的審查，一旦抬出國際條約作為審查準據，必然導出系爭限制性規定合憲的結論，則不僅易犯論證跳躍與說理不足的毛病³¹，甚且可能使國際人權法成為限制內

29 比例原則向來分成「手段適當性（有效性）」、「手段必要性（限制最小）」及「限制合理性（相稱性）」三個次原則。「目的正當性」審查是否為比例原則的內涵之一，學說上見解不一。作者向來認為應包涵之，蓋目的若不正當，縱使手段適當、必要、合理，亦不合憲。抑且，若不先進行目的審查，則在審查手段是否適當、必要、合理時，即欠缺足以對應衡酌的基座。當然，若從語意來看，「比例」一詞指涉的應該是「目的」與「手段」的比例關係，而不是「目的」正當與否的單面問題。嚴格的說，目的審查不是比例原則的要素本身，但基於上述理由，目的審查至少應該是操作比例原則不可或缺的前提要件。參見李建良，基本權利理論體系之構成及其思考層次，收於：憲法理論與實踐（一），2版，頁94（2003年）；李建良，論憲法上保護義務與保護請求權之關係——以「不足禁止原則」的論證構造為中心，收於：人權思維的承與變，頁193-194（2010年）。

30 以下兩號解釋之理由構成，均屬此例：

司法院釋字第689號解釋理由書第3段：「……且依世界人權宣言、公民與政治權利國際公約及歐洲人權公約規定，私人生活領域有不受他人任意干涉之權利，國家負有積極的保護義務，應提供法律保護，以免個人之私人生活領域遭受不當干涉，是系爭規定之目的殊屬正當。」（粗體為作者所強調）

司法院釋字第591號解釋理由書第3段：「聯合國大會決議通過，並推薦各國採用之一九八五年聯合國國際商務仲裁法範本(UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration)規定，當事人聲請法院撤銷仲裁判斷之事由，除『仲裁判斷違反本國之公共秩序者』，涉及實體事項者外，其餘諸如仲裁協議之當事人不適格、仲裁協議無效、仲裁人之選定或仲裁程序之進行未經合法通知或有其他原因致使當事人未獲陳述之機會、仲裁判斷逾越仲裁協議之範圍、仲裁庭之組成或仲裁程序抵觸仲裁協議或仲裁法，及爭議事件不具仲裁容許性等，均為有關程序之重大瑕疵（第三十四條，另第五條參照）。上開規定之目的，在於避免司法機關動輒對仲裁判斷之實質問題為全面之審理，俾維護仲裁制度之自主原則並發揮迅速處理爭議之功能。」（粗體為作者所強調）

31 司法院釋字第678號解釋理由書第3段，即有此問題，其謂：「……立法機關衡酌上情，乃於電信法第四十八條第一項前段規定，人民使用無線電波頻率，採

國人權的「尚方寶劍」，國際潮流下的憲法反成了限制人權的憲法，不啻本末倒置，不可不慎！

三、以國際條約作為宣告方式的參據

法規違憲審查的宣告模式，除合憲認定與違憲宣告外，尚有介於中間的所謂「警告性解釋」，即宣示法規與憲法「尚無牴觸」之意旨，但同時指示立法者「應從速檢討修正」、「應檢討修正」、「宜予（應）通盤檢討修正」或「宜檢討改進」³²。此種宣告模式為大法官解釋所創設³³。綜攬歷來解釋，可以發現在兩號未明白宣告系爭法律規定違憲的解釋中，大法官援引國際條約作為警告性解釋的依據：

司法院釋字第549號解釋³⁴之解釋文第3段：

「……惟為貫徹國家負生存照顧義務之憲法意旨，並兼顧養子女及其他遺屬確受被保險人生前扶養暨無謀生能力之事實，勞工保險條例第二十七條及第六十三條至第六十五條規定應於本解釋公布

行事前許可制，其立法目的尚屬正當。上開規定固限制人民使用無線電波頻率之通訊傳播自由，惟為保障合法使用者之權益，防範發生妨害性干擾，並維護無線電波使用秩序及無線電通信安全（聯合國所屬國際電信聯合會——International Telecommunication Union之無線電規則——Radio Regulations第十八條，及聯合國海洋法公約——United Nations Convention on the Law of the Sea第一百零九條參照）。兩相權衡，該條項規定之限制手段自有必要，且有助於上開目的之達成，與比例原則尚無牴觸，並無違憲法第十一條保障人民言論自由之意旨。」（粗體為作者所強調）本號解釋在論及系爭規定對於人民通訊傳播自由之限制（事前許可制）是否必要、有助於目的之達成時，僅空泛地參照援引國際規範之抽象規定，而未進行細緻之法律論證及法益權衡，例如為維護無線電波使用秩序及無線電通信安全，何以必須採行事前許可制乙節，缺乏實質內涵之論理過程。就此而言，國際條約作為憲法解釋之參據，實不無商榷之餘地。

³² 例如司法院釋字第221、222、250、265、311、318、327、335、356、396、409、417、426、433、441、465、468、472號解釋等，不一而足。

³³ 所謂「創設」，係指此種宣告模式，法無明文，而非大法官所獨創。實則，警告性解釋係取法自德國及奧地利的釋憲實務。參見李建良，論法規之司法審查與違憲宣告——德國聯邦憲法法院裁判之分析，收於：憲法理論與實踐（一），2版，頁485-492（2003年）。

³⁴ 本件釋憲案的爭點：勞保條例就勞保遺屬津貼受領之規定是否違憲？

之日起二年內予以修正，並依前述解釋意旨就遺屬津貼等保險給付及與此相關事項，參酌有關國際勞工公約及社會安全如年金制度等通盤檢討設計。」（粗體為作者所強調）

司法院釋字第578號解釋³⁵之解釋文第3段：「惟立法者就保障勞工生活之立法選擇，本應隨社會整體發展而隨時檢討，勞動基準法自中華民國七十三年立法施行至今，為保護勞工目的而設之勞工退休金制度，其實施成效如何，所採行之手段應否及如何隨社會整體之變遷而適時檢討改進，俾能與時俱進，符合憲法所欲實現之勞工保護政策目標，以及國內人口年齡組成之轉變，已呈現人口持續老化現象，未來將對社會經濟、福利制度等產生衝擊，因此對既有勞工退休制度及社會保險制度，應否予以整合，由於攸關社會資源之分配、國家財政負擔能力等全民之整體利益，仍屬立法形成之事項，允宜在兼顧現制下勞工既有權益之保障與雇主給付能力、企業經營成本等整體社會條件之平衡，由相關機關根據我國憲法保障勞工之基本精神及國家對人民興辦之中小型經濟事業應扶助並保護其生存與發展之意旨，參酌有關國際勞工公約之規定，並衡量國家總體發展，通盤檢討，併此指明。」（粗體為作者所強調）

以上兩號解釋不約而同的提及「國際勞工公約」，惟既未明示條約內容，亦未指出參酌的重點或方向，其規範意義甚微，更夠不上國際法作為國內法的法源。分別觀之，司法院釋字第578號解釋審查的勞動基準法課雇主負擔勞工退休金之規定，除平等權外，主要限制到雇主的契約自由及財產權，關鍵在於是否符合比例原則。大法官基於「國家為貫徹保護勞工之目的」作成合憲之認定，復又責令「相關機關根據我國憲法保障勞工之基本精神及國家對人民興辦之中小型經濟事業應扶助並保護其生存與發展之意旨」，通盤檢討勞動基準法有關勞工退休制度之規定。若著眼於雇主權利受到限制，則所謂「通盤檢討」理應朝有利於「雇主」契約自由及財產權

35 本件釋憲案的爭點：勞基法課雇主負擔勞工退休金是否違憲？

保障的方向修法，但大法官卻指示應參酌「國際勞工公約」，其意指為何，耐人尋味。合理的詮釋允當是：大法官指示相關機關應建立一套兼顧勞工與雇主權益的社會福利制度。然此毋寧又回到大法官所強調的「立法形成自由」，從而脫離違憲審查的規範脈絡，進入立法政策的領域，「國際勞工公約」爰只是眾多可採擇的立法參考資料之一。

反觀司法院釋字第549號解釋，其所涉（舊）勞工保險條例第27條（養子女領取保險給付之限制）³⁶、第63條至第65條（遺屬津貼）規定是否違憲之問題，大法官直指：

「為貫徹國家對人民無力生活者負扶助與救濟義務之憲法意旨，以收養子女經法院認可後，確有受被保險人生前扶養暨其本身無謀生能力之事實為請領遺屬津貼之要件，更能符合勞工保險條例關於遺屬津貼之制度設計。」（粗體為作者所強調）

「鑑於上開規定（按：第63條至第65條）之遺屬得受領遺屬津貼，原為補貼被保險人生前所扶養該遺屬之生活費用而設，以免流離失所，生活陷於絕境，從而其請領遺屬津貼亦應同以受被保險人生前扶養暨無謀生能力之事實為要件，始符前開憲法旨意。」（粗體為作者所強調）

由上可知，大法官雖未明揭系爭規定違憲，然從字裡行間可以清楚地讀出大法官認定系爭規定構成違憲的旨意，從而作出「限期修法」的宣告。在此意義下，所謂「參酌有關國際勞工公約及社會安全如年金制度等通盤檢討設計」，應係課予立法者「修法之義務」暨「參酌國際條約之義務」³⁷。不過，由於大法官未明示應參酌條約的內容，此一「參酌義務」的效力強度亦相對減弱。尋究大

36 內容：「被保險人之養子女戶籍登記未滿六個月者，不得享有保險給付之權利。」

37 勞工保險條例第27條現改為：「被保險人之養子女，其收養登記在保險事故發生時未滿六個月者，不得享有領取保險給付之權利。」同條例第63條至第65條則已依解釋意旨大幅修改，並增訂「年金給付」制度。

法官何以不言明系爭規定違憲的緣由，可以發現本號解釋僅援引憲法第153條、第155條、憲法增修條文第10條第8項有關保護勞工及社會保險制度等基本國策規定作為違憲審查的基準，而未提及任何基本權利的條文。大法官若宣告系爭法律規定違憲，無異承認基本國策對於立法者的規範效力，因此只能模糊以對。窮根究柢，溯本追源，問題實存於「憲法上之社會權」的概念與內涵在臺灣仍有相當開展的空間³⁸，有待學說與實務深究探研³⁹，並建立以本國憲法為基礎之社會權體系及規範內涵。

四、以國際條約作為解釋憲法的參據

相對於上述蜻蜓點水式的提及國際條約，大法官在司法院釋字第392號⁴⁰及第582號⁴¹解釋對於國際條約的引述頗為詳細，無獨有偶，皆涉及刑事人權的問題。

司法院釋字第392號解釋處理的問題之一是：憲法第8條第2項所稱「該管法院」是否包括檢察官在內？在理由書第3段及第18段，大法官指該項規定「乃繼受自外國立法例」，並參酌「歐洲保障人權及基本自由公約」第5條第3項、「聯合國公民及政治權利國際盟約」第9條第3項、「美洲人權公約」第7條第5項、歐洲人權法院於1988年關於「包威爾斯」案之判決，指該管法院「限於狹義之審判法院」。

司法院釋字第582號解釋處理的問題是：共同被告不利己陳述得否作為其他共同被告之罪證？於理由書第2段，大法官援引「歐

38 此一問題，可以參考Christian Starck著，李建良譯，國際條約、憲法及法律中的社會權，收於：Christian Starck著，李建良、范文清、蔡宗珍、陳愛娥、楊子慧譯，法的起源，頁147以下（2011年）。

39 國內不乏探討社會權之文獻，例如：陳新民，論「社會基本權利」，收於：憲法基本權利之基本理論（上冊），4版，頁95以下（1994年）。

40 本件釋憲案之爭點：刑訴法檢察官羈押權、提審法提審要件等規定是否違憲？

41 本件釋憲案之爭點：共同被告不利己陳述得為他共同被告罪證之判例是否違憲？

洲人權及基本自由保障公約」第6條第3項第4款及「聯合國公民及政治權利國際公約」第14條第3項第5款有關「凡受刑事控訴者，均享有詰問對其不利之證人的最低限度保障」之規定，指出「刑事被告享有詰問證人之權利」，乃具普世價值之基本人權。在我國憲法上，不但為第16條之訴訟基本權所保障，且屬第8條第1項規定「非由法院依法定程序不得審問處罰」、對人民身體自由所保障之正當法律程序之一種權利。

司法院釋字第392號解釋所涉爭議，簡單的說，就是憲法第8條第2項所稱「該管法院」概念的憲法解釋問題；司法院釋字第582號解釋指「刑事被告享有詰問證人之權利」為普世價值之基本人權，表面上似乎是標舉出一種「新的人權」，實則如其後續所言，只是憲法第16條訴訟基本權及第8條第1項正當法律程序（權）⁴²之「保障範圍」及「權利內涵」的闡述，二者皆屬「本國憲法條文之解釋」問題。在臺灣憲法規範架構下，理論上，大法官無須引介國際條約或國際裁判，亦可得出相同的結論，國際條約在此僅具有補強論述與理由充實的功能。尤須併予指出者，大法官在本號解釋理由書中特別強調：

「憲法第八條關於行使逮捕、拘禁、審問、處罰權限之規定具有憲法保留(Verfassungsvorbehalt)之性質，同條第二項前段之『法院』究何涵義，既如上述，自無所謂倘已符合正當程序，檢察官亦得擁有刑事訴訟法之羈押權問題。至於檢察官之為公益代表，監督法院裁判為正當之法律適用，非以追求被告有罪判決為唯一目的之諸多職責暨其係屬廣義之司法機關等等，雖屬實在，仍亦非可因此即謂憲法已同時賦予其刑事訴訟法上羈押被告之權。……憲法對人身自由係為直接之保障，其既明定法院以外之司法或警察機關，雖得依法定程序逮捕、拘禁人民；但仍不許逾越二十四小時，則所謂

42 關於正當程序作為一種基本權，參見李建良，論基本權利之程序功能與程序基本權——德國理論的借鑑與反思，收於：人權思維的承與變，頁262（2010年）。

刑事訴訟法上羈押權歸屬係立法裁量之範疇云者，固非有據；而此二十四小時究竟合乎現實之需要與否？應否如同其他部分之國家然，規定為四十八小時、甚或七十二小時，此則屬於修憲之問題。」（粗體為作者所強調）

由上可推，縱使國際條約為合乎現實之需要而規定為48小時、甚或72小時，則應否如同國際規範然，仍屬於修憲之問題，既非立法裁量的範疇，亦非得經由憲法解釋（援用國際條約）逕予改變。

五、以國際條約作為解釋法律的參據

憲法第23條法律保留原則衍生之違憲審查問題，基本上有四種類型：

- （一）限制人民基本權利的公權力欠缺任何法律上之依據而牴觸憲法；
- （二）限制人民基本權利的公權力有法律上之依據，但該法律本身牴觸憲法（例如法律明確性原則或比例原則）；
- （三）限制人民基本權利的公權力行為，係基於法律授權所訂定之行政命令，但該命令牴觸憲法（例如授權明確性原則或逾越法律授權範圍）；
- （四）限制人民基本權利的公權力行為，係對於法律意旨的解釋、適用或具體化（例如判例、決議或函釋），但該法律見解牴觸憲法（例如違反法律的規範意旨）。

以上情形中，第（三）、（四）種的違憲問題，嚴格而言，並非公權力行為直接牴觸憲法，而是因違反法律（違法）而構成違憲。此二種之違憲審查與其說是「憲法解釋」，毋寧側重於「法律解釋」。另外，法律本身是否牴觸憲法（例如法律明確性原則或比例原則），大法官所應審究者，乃「法律」的規範意旨與「憲法」的規範意旨是否合致。此一審查工作的運行，必先究明待審法律規定的意旨，此涉及「法律解釋」問題，而非憲法解釋。法律意旨的探求，基本上應是探尋「立法者」的規範意旨，既非釋憲者的意旨，

亦不是受法律規範之行政機關的意旨。以下兩號提及國際條約或國際組織的憲法解釋，即可在此觀點下加以檢視：

司法院釋字第428號解釋（1997年5月23日）⁴³的釋憲標的有二：1.（舊）郵政法第25條有關各類掛號郵件之補償僅限於遺失或被竊，而不及於毀損之規定⁴⁴，是否牴觸憲法第23條？2.（舊）郵政規則第227條、第228條有關「郵局責任即為完畢」、「事後不得請求補償」規定，是否逾越母法授權範圍或牴觸母法？前者為系爭法律規定是否合乎比例原則的審查問題；後者為郵政規則（法規命令）是否牴觸（舊）郵政法第27條⁴⁵之法律保留問題。

於解釋理由書第3段，大法官提及「萬國郵政公約最後議定書」，指「我國雖非此公約之締約國，仍可視之為國際間通郵之一般規範」，再援引該公約第35條第1項規定，謂：「依該公約之規定，各類郵件如經照章投遞而收件人於領取郵件時並未提出保留權利之聲明者，各郵局即無須負責」，進而得出「郵政規則第二百二十七條及第二百二十八條之規定，與國際公約之規定相符，並未逾越郵政法第二十七條之授權，亦未增加郵政法關於郵件補償規定所無之限制，與憲法尚無牴觸」的結論。（粗體為作者所強調）

仔細閱讀解釋理由，大法官係以（舊）郵政法第3條：「關於各類郵件或其事務，如國際郵政公約或協定有規定者，依其規定。但其規定如與本法相牴觸時，除國際郵件事務外，適用本法之規定。⁴⁶」為據，連結出萬國郵政公約最後議定書。國際條約成為法

⁴³ 本件釋憲案之爭點：郵政法等法規就掛號郵件補償之要件等規定是否違憲？

⁴⁴ 內容：「郵件遇左列情形時，寄件人得向郵政機關請求補償：一、各類掛號郵件遺失或被竊時。二、掛號包裹、報值郵件、保價郵件全部或一部遺失、被竊或毀損時。」現改為郵政法（2011年4月27日）第29條：「郵件有下列情形之一時，寄件人得向中華郵政公司請求補償：一、包裹郵件、快捷郵件、報值郵件、保價郵件全部或一部遺失、被竊或毀損時。二、其他各類掛號郵件全部遺失或被竊時。」內容並無重大差異。

⁴⁵ 內容：「郵件補償之金額及其方法，於郵政規則中定之。」

⁴⁶ 此一規定現移列為郵政法（2011年4月27日）第13條：「關於各類郵件或其事務，國際郵政公約或協定有規定者，依其規定。但其規定與本法牴觸者，除國

律解釋及適用的依據，乃是基於「立法者」的指示而來。因此，萬國郵政公約最後議定書僅具有「法律」位階，所謂郵政規則「與國際公約之規定相符」，亦不過是確認郵政規則的「合法性」。至於（舊）郵政法第25條有關各類掛號郵件之補償僅限於遺失或被竊而不及於毀損之規定的「合憲性」問題，解釋理由書第2段指「郵政法第二十五條排除一般掛號郵件毀損之補償，乃就其所收取費用、服務性質、經營成本、人民權益所受侵害之程度等因素為衡平考量，並為維持郵政事業之經營所必須，增進公共利益所必要，尚未逾越立法權自由形成範圍，符合憲法第二十三條之比例原則」，顯見萬國郵政公約最後議定書與違憲審查並無直接關聯，至多作為法律解釋的補充。

再查司法院釋字第690號解釋，其主要爭點是2002年1月30日修正公布之傳染病防治法第37條第1項規定曾與傳染病病人接觸或疑似被傳染者，主管機關得為「必要之處置」包含強制隔離在內之部分（系爭規定）⁴⁷，是否違反法律明確性原則、牴觸憲法第23條之比例原則及憲法第8條正當法律程序之意旨（特別是法官保留原則）？在這則涉及法律是否牴觸憲法之違憲審查案件中，大法官於解釋理由書第4段表示：

「……雖系爭規定並未就強制隔離之期間詳為規定，惟必要處置期間之長短，事涉傳染病之病源、傳染途徑、潛伏期及其傷害之嚴重性，自應由該管主管機關衡酌各種情況，並參酌世界衛生組織 (World Health Organization, WHO) 之意見而為符合比例原則之決定（以前述SARS疫情為例，該管主管機關臺北市政府於衡量當時世界

際郵件事務外，適用本法之規定。」內容不變。

⁴⁷ 內容：「曾與傳染病病人接觸或疑似被傳染者，得由該管主管機關予以留驗；必要時，得令遷入指定之處所檢查，或施行預防接種等必要之處置。」現行（2009年1月7日修正公布）傳染病防治法移列第48條第1項：「主管機關對於曾與傳染病病人接觸或疑似被傳染者，得予以留驗；必要時，並得令遷入指定之處所檢查、施行預防接種、投藥、指定特定區域實施管制或隔離等必要之處置。」

各國對該疫情尚無處理之經驗、醫界處理之方法亦無定論，及該疫情已造成國內外民眾嚴重之傷亡等情況，暨參酌世界衛生組織之意見，因而決定受隔離處分者之隔離期間為十四日，見臺北市政府衛生局一〇〇年一月十八日北市衛疾字第〇九九四五六八六四〇〇號函。」（粗體為作者所強調）

大法官原本應該審究的是，系爭規定是否因未規定必要處置（隔離）之期間而違反比例原則（法律規定是否違憲），卻把箭頭轉向主管機關，要求主管機關應視個案情況為符合比例原則之決定（行政決定應符合比例原則），在論證邏輯上已不無可議之處（個案決定的合比例性不等於抽象規範的合比例性）⁴⁸。復就主管機關應「參酌世界衛生組織之意見」而言，更難謂允當周妥。蓋「必要處置期間之長短」屬於法律解釋、適用的層次，其是否符合比例原則，須依具體個案情節而定，世界衛生組織之意見雖有參酌之價值，卻非判斷個案決定是否符合比例原則之絕對標準。大法官原本想藉個案決定的合比例性要求，「挽救」法律不合比例的疑義，無意間卻使個案決定之合法性審查繫於國際組織之意見。

六、小結

綜觀以言，截至目前為止，大法官雖數度在解釋中援引國際條約，惟其運用之道，或是補充違憲審查論理，或是依附於憲法條文，或僅作為參考依據，或屬法律規定意旨的延伸等，總之，國際條約並未構成憲法解釋的直接法源。此種審慎的態度與猶豫的立場，應值肯定，並且印證本文之前設命題。國際條約的內國法化，牽涉立法與司法之間的權力分際與法秩序的民主底蘊，於基本人權的增補或人民權利之限制，尤不能忽略民主正當性與權力分立的嚴肅課題，與臺灣的特殊國際地位無關，亦非只是「學理上單純之民

⁴⁸ 關於本號解釋的論證瑕疵及曲解法官保留原則等問題，詳見李建良，人身自由的憲法保障與強制隔離的違憲審查——釋字第690號解釋，台灣法學雜誌，186期，頁60-79（2011年）。

主正當性或權力分立之思考」⁴⁹。臺灣無法參與國際組織，締結國際條約，有其政治現實上的主客觀外在因素，除須國人齊力抵禦外侮外，立法機關非不得主動將國際條約的內容轉換成法律條文。因此，除國際條約的內涵蘊藏於憲法規範意旨外，大法官應尊重立法機關的職權，不宜任意透過司法解釋將國際法納為國內法，並賦予與內國法律同等位階之拘束力，否則無異僭越立法權，自居為「太上立法者」⁵⁰。大法官不能因為國家的外在處境而「自動地」取得高於立法機關的「國際法內國法化」的權力，而須設法找到憲法的立基點，詳予論證，方能使國際規範與內國法秩序兼容並蓄、相得益彰。由於國際條約並未真正成為憲法解釋的直接法源，故國際條約的法效力與法位階問題之索解，自無法乞靈於前揭大法官解釋，容須另闢探究的蹊徑。

肆、轉接模式：國際條約之形式合憲性與國內法效力

國際條約，究其制度本質，乃國與國之間（國際）為規範彼此權利義務關係所締結的一種「契約」⁵¹，以國家（或國際法人）為締結主體（契約當事人）及規範對象（義務人）。人民（自然人或

49 持此見解者，例如張文貞（註20），頁267。

50 黃越欽大法官針對司法院釋字第549號解釋提出之協同意見書表示：「本院釋憲之態度，向來對國會保留及立法裁量權極為尊重，蓋以我國憲政秩序中立法與司法之界限分明，本院對此極為自制。然此乃就國內法律秩序而言，如以國際之格局視之，則在以普世價值之實現為宗旨之公約要求下，各公約會員國國會之任務，無非即在忠實表達公約之意旨，所謂立法裁量空間實極有限，為確保立法裁量權之正確行使，釋憲機關以公約為法源，檢視立法機關所制定之法律，毋乃正是憲法原則忠實詮釋之表現。」此項見解即值得商榷。蓋若可從國際法「普世價值之實現」直接推導出國際條約之「憲法法源性」，則立法院之批准程序將形同具文，立法權也會在無形中屈居於司法權之下。

51 在德國，條約與契約之概念，皆以„Vertrag“一詞稱之。

私法人)與國家(公法人)分屬不同的權利主體,基於契約的「相對性」⁵²,除有特別約定或特殊規定外,國際條約原則上僅能拘束國家,而不能穿透國家主權直接及於人民。固然,國際條約非不得直接賦予人民一定之權利,例如賦予人民得向國際法院提起訴訟之權利。然此種權利屬國際法上之權利,與人民在一國之內所得享有之憲法上或法律上權利,仍有不同,故國際條約(契約)通常需有一定的承接或轉換機制,始能發生「第三人效力」,非能長驅直入內國法領域。如前所述,條約作為國際法的法源,悉依國際規範或裁判為準據;相對而言,條約如何成為一國的法制度,取得並產生內國法效力,則屬國內法的問題。基本上,各國對於「條約」概念可以有不同的理解,亦得設定異於其他國家的處理程序與效力要件,並無所謂國際條約法效力之「一般理論」。因此,探討國際條約的法效力問題,須以國內法為基準。在臺灣,除憲法設有若干規定外,目前尚無「條約締結法」的制定⁵³,僅有行政命令層級的「條約及協定處理準則」。以下試從憲法的規範出發,參酌相關解釋、法令規定及學說見解,探討國際條約在臺灣的法效力問題。

⁵² 本文在此使用之「契約」概念,非指狹義之民事契約,而係採廣義的理解方式,泛稱由特定主體共同建立相互約束之規範而言。契約在本質上固具有「相對性」,但不排除在一定條件下亦可以發展出「一般效力」。勞動法上之「團體協約」,即是典型的例證。因此,國際法上之「強行法」(*jus cogens*)概念,以及目前可見以條約建立一般性規範或所謂「對世義務」(*obligations erga omnes*)的發展趨勢,均不影響國際條約所具之契約本質。關於國際法上「強行法」與「對世義務」之概念及其發展,參見LAURI HANNIKAINEN, PEREMPTORY NORMS (JUS COGENS) IN INTERNATIONAL LAW 161-62 (1988); OPPENHEIM'S INTERNATIONAL LAW, VOL. 1: PEACE, INTRODUCTION & PART I, 528 (Robert Jennings & Arthur Watts eds., 9th ed. 1992); Karl Zemanek, *New Trends in the Enforcement of Erga Omnes Obligations*, in 4 MAX PLANCK YEARBOOK OF UNITED NATIONS LAW 1, 1-52 (Jochen A. Frowein & Rüdiger Wolfrum eds., 2000); Stefan Kadelbach, *Jus Cogens and Obligations Erga Omnes and Other Rules-The Identification of Fundamental Norms in THE FUNDAMENTAL RULES OF THE INTERNATIONAL LEGAL ORDER: JUS COGENS AND OBLIGATIONS ERGA OMNES* 21, 21-40 (Christian Tomuschat & Jean Marc Thouvenin eds., 2006).

⁵³ 目前只有「條約締結法」草案之研議,於2011年4月7日經行政院院會決議通過,送立法院審議中。

一、憲法上之條約與形式合憲性問題：從司法院釋字第329號解釋談起

憲法對於條約之規範，分見於第38條、第57條第3款、第58條第2項、第63條及第141條。不同於「國際法上之條約」概念於維也納條約法公約設有定義⁵⁴，憲法未有明文，故憲法上「條約」概念的意涵為何，屢生爭議。外交部為釐定條約的處理程序，於1992年2月19日，本於職權發布（舊）「條約及協定處理準則」，將條約限定在「具有條約之名稱或雖無條約之名稱但定有批准條款之國際書面協定」，至於其他的國際書面協定則統稱為「協定」，並規定僅前者（條約）須送立法院審議（第8條）。此外，該準則第7條賦予主管機關在時機緊迫之際，得不經行政院核可及立法院同意，逕行簽訂條約或協定草案之協議；第9條第1項規定，協定內容涉及國家機密或有外交顧慮者，得不送立法院查照。

由於憲法第63條規定：立法院有審議條約之權，上開「條約」概念的界定及簽訂程序是否合於憲法意旨，時而引發立法院的質疑。1993年4月27日至4月29日，第一次辜汪會談簽署「辜汪會談共同協議」、「兩會聯繫與會談制度協議」、「兩岸公證書使用查證協議」及「兩岸掛號函件查詢、補償事宜協議」等四項協議，於立法院爆發條約審議權之爭議。部分立法委員爰向大法官聲請解釋⁵⁵。

54 國際法上條約的名稱不一，非皆以「條約」名之。

55 聲請主旨為：「立法委員陳建平等八十四人，為（一）憲法第三十八條、第五十八條第二項、第六十三條及第一百四十一條之條文中，有關『條約』一詞之內容及範圍如何，迭起爭議，亟待釐清，以弭憲政上之紛爭；（二）條約以外之國際書面協定，究竟何種協定應送立法院審議，何種協定僅須送立法院備查，係長期存在於立法院與行政院間之憲政爭議，此一爭議隨立法委員全面改選後，有愈演愈烈之趨勢，有必要儘速予以明確界定；（三）有關何種協定應送立法院審查或備查之分類標準，其有權認定機關應為立法院或行政院，攸關此一憲政爭議之解決，應一併予以釐清；（四）外交部訂定發布之『條約及協定處理準則』第七條及第九條第一項，明顯侵犯憲法第六十三條賦予立法院之條約審議權，而其中第九條亦違反中央法規標準法第七條，依憲法第一百七十二條之規定，該準則第七條及第九條應屬無效。爰依司法院大法官審理案件法

1993年12月24日，司法院公布司法院釋字第329號解釋，謂：「憲法所稱之條約係指中華民國與其他國家或國際組織所締結之國際書面協定，包括用條約或公約之名稱，或用協定等名稱而其內容直接涉及國家重要事項或人民之權利義務且具有法律上效力者而言。其中名稱為條約或公約或用協定等名稱而附有批准條款者，當然應送立法院審議，其餘國際書面協定，除經法律授權或事先經立法院同意簽訂，或其內容與國內法律相同者外，亦應送立法院審議。」

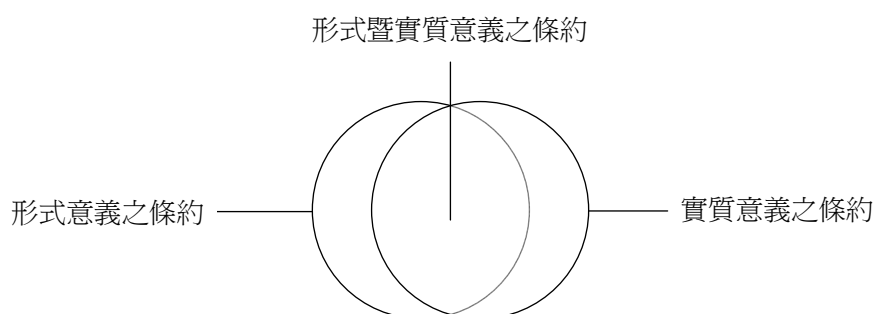
上述解釋文將「條約」定義為「中華民國與其他國家或國際組織所締結之國際書面協定」，與維也納條約法公約的定義相仿，惟其後所附加「直接涉及國家重要事項或人民之權利義務且具有法律上效力」等條件，卻為國際法所無。細究大法官對條約的界說，主要著眼於「是否送立法院審議」乙節，其關注的焦點自然不同於國際法學，可稱之為「憲法上之條約」概念。觀其內容，又可細分為四種概念：

- (一) 名稱為條約或公約。
- (二) 用協定等名稱，並附有批准條款。
- (三) 用協定等名稱，且直接涉及國家重要事項。
- (四) 用協定等名稱，且直接涉及人民之權利義務。

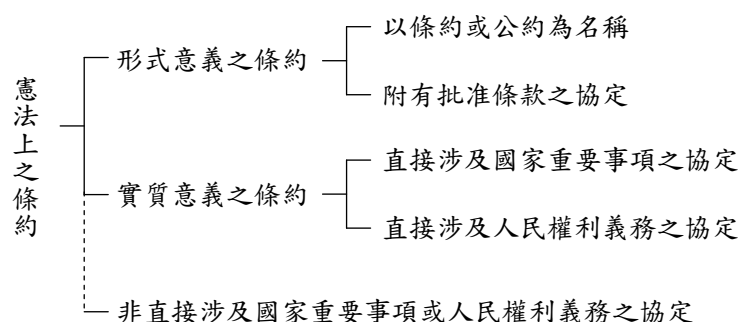
姑不論「直接涉及國家重要事項或人民之權利義務」如何認定⁵⁶，以上四種條約概念，前二者（一、二）係從名稱與有無批准條款等外觀形式予以判定，可稱之為「形式意義之條約」；後二者（三、四）係從內容作實質認定，故可稱為「實質意義之條約」。由於形式意義之條約在內容上頗多涉及國家重要事項或人民權義者，故此二概念一如法律概念，亦呈部分相交的兩個圓圈（參見下圖）。

第五條第一項第三款，聲請解釋。」

⁵⁶ 參見張特生大法官所提一部不同意見書。



至於「用協定等名稱，但未直接涉及國家重要事項或人民之權利義務」者，若採大法官所作的限縮性定義，自不在條約的概念範疇之內（參見下圖）。



由上述解釋理由之構成可知，大法官係透過憲法上「條約」概念的界定，來處理是否送立法院審議之問題。實則，憲法上條約的概念界定，與條約是否送立法院審議，應屬二事。後者屬於條約是否形式合憲的規範性問題，大法官將之納入條約定義的要素，不無將「何謂條約」與「條約是否合憲有效」二種不同層次之觀念混為一談之嫌，且有涵蓋過狹之弊⁵⁷。申言之，憲法有關條約之規定，

⁵⁷ 在邏輯觀念上，條約的「界定」與條約的「是否須經立法院審議」有別，後者為條約的形式合憲要件，不宜放入條約的概念要素中。此一觀念上之區辨，實

計有：總統行使締結條約之權（憲法第38條）、行政院對於立法院決議之條約案的覆議權（憲法第57條第3款、憲法增修條文第3條第2項第2款）、行政院會議議決條約案（憲法第58條第2項）、立法院對於條約案之議決權（憲法第63條）及外交應尊重條約（憲法第141條）。其中與立法院審議有關者，為行政院對於立法院決議之條約案的覆議權、行政院會議議決條約案與立法院對於條約案之議決權，從文義解釋與體系解釋以言，總統締結之條約應包含「非直接涉及國家重要事項或人民權利義務之協定」；而外交應尊重之「條約」，亦不以須經立法院審議者為限⁵⁸。

對照解釋理由書，大法官界定憲法上條約概念及須經立法院審議的論證基礎是：依憲法第38條、第58條第2項、第63條「所締結之條約，其位階同於法律」。而從解釋理由書第1段謂：「……依上述規定所締結之條約，其位階同於法律。故憲法所稱之條約，係指……」以觀，大法官以「故」字為連接詞，顯見前後有推論關係。換言之，大法官係使用「若P則Q」的語句陳述，其論證基礎及其推演過程，即有以下值得商榷之處：

（一）大法官並未說明何以依上述規定締結之條約，具有與法律相同的位階。若因該等條約須經立法院審議之故，則不無倒果為

則牽涉到「法律概念」（或法律制度）定義之基礎方法論問題。簡要言之，某一法律概念（或法律制度）之概念要素為何？是否存在？如何認定？與該法律概念（或法律制度）所涉及的合法與否及其效力等規範問題，分屬不同層次，不宜混同。某一法律概念（或法律制度）縱使違法（包括違反程序要件），只能說是「違法」（甚至可能無效）之法律概念（或法律制度），而不是「非」法律概念（或法律制度）。以「行政處分」概念為例，何謂行政處分？如何認定？取決於行政處分之概念要素（參見行政程序法第92條），無涉乎行政處分之「是否合法」，二者應加區分。例如行政程序法第102條規定：行政處分的作成，應聽取當事人的意見，始為合法（程序要件）。設若行政處分的作成未給予當事人陳述意見之機會，則該行政處分仍為（違法之）行政處分，而不能將「行政處分」說成「應聽取當事人意見的行政行為是行政處分」。由此以證，條約須經立法院審議始為合憲有效之說法，僅說明「條約」與「須經立法院審議」二者具有條件關係，而非同一概念。

58 但須注意者，「應尊重條約」不等於「應受條約拘束」，更不能由此得出條約的效力必然優於國內法之推論（後詳）。

因之病。

(二) 解釋文中「憲法所稱之條約係指……，包括……，或用協定等名稱而其內容……且具有法律上效力者而言」之論述，將「具有法律上效力」列為憲法上條約的概念要素之一，亦有套套邏輯的問題，由此將產生「因為具有法律上效力，所以是憲法所稱之條約」，抑或「因為是憲法所稱之條約，所以具有法律上效力」之疑問。

(三) 從條約具有法律的位階，無法推導出條約應包含「直接涉及國家重要事項或人民權利義務」之要素。蓋非直接涉及國家重要事項或人民權利義務之事項，法律亦得規範之。

姑且不論概念邏輯及推導謬誤的問題，司法院釋字第329號解釋提出「條約（位階）等同法律⁵⁹」的說理模式，無疑是要闡釋以下意旨：

(一) 法律係由立法院議決通過，則與法律相同位階的條約，當然也要由立法院審議通過。

(二) 臺灣與其他國家或國際組織所締結之條約，並非皆須經立法院審議。

(三) 凡直接涉及國家重要事項或人民權利義務之協定，不問名稱，皆須經立法院審議。

可惜大法官未能將此意旨一以貫之，竟在解釋理由書末尾表示：「臺灣地區與大陸地區間訂定之協議，因非本解釋所稱之國際書面協定，應否送請立法院審議，不在本件解釋之範圍。」依前所述，本件釋憲聲請案起因於辜汪會談簽署四項兩岸協議而引發應否送立法院審議之爭議，釋憲聲請書記載甚詳⁶⁰，寧有「不在本件解

59 司法院釋字第329號解釋中雖未明白表示「條約等同法律」，但從「其（按：條約）位階同於法律。故憲法所稱之條約，係指……」的行文脈絡來看，其說理模式大抵建立在條約與法律同位階的基礎上。

60 本聲請書所聲請之事項有四，其一涉及立法院曾於1992年6月18日以「建請行政院研處」方式通過決議，要求「我國對外簽訂之協議，實質上具有條約性質

釋之範圍」之理！鑑於兩岸關係的高度政治敏感性，大法官不願表態，以免捲入政治漩渦，誠可理解⁶¹。不過，本號解釋既已揭櫫「凡涉及國家重要事項或人民權利義務事項皆須經立法院審議」之基本原則，則不問臺灣與中國訂定之協議是否為本解釋所稱之國際書面協定，至少只要是直接涉及國家重要事項或人民權利義務者，均應送請立法院審議，始符憲制，殆無疑義。準此以推，從憲法第63條規範意旨出發，凡國際條約均須經立法院審議始具憲法上之形式正當性，為國際條約具有國內法效力之前提要件(precondition)⁶²。

二、國際條約的內國法化模式與問題

國際條約須經國會同意始能成為國內法，尚未說明國際條約如何成為國內法，後者涉及條約「內國法化」的方式⁶³，或者說國際

者，均應送立法院審議」，結果：「今年四月二十七日至二十九日，由行政院大陸委員會授權之財團法人海峽交流基金會董事長辜振甫與大陸方面的海峽兩岸關係協會會長汪道涵在新加坡進行會談，並簽署『辜汪會談共同協議』、『兩會聯繫與會談制度協議』、『兩岸公證書使用查證協議』及『兩岸掛號函件查詢、補償事宜協議』等四項協議，部分朝野立委要求大陸委員會必須將上述四項協議送立法院審議，再度引發有關條約審議權之爭議。對於何種協定應送立法院審議，何種協定僅須送立法院備查，涉及憲法第五十八條第二項及第六十三條有關『條約案』之意義與範圍之釐清，故聲請解釋。」（粗體為作者所強調）

61 本號解釋分別有一份「一部不同意見書」、三份「不同意見書」，大法官意見分歧之程度，由此可見一斑，其中張特生大法官及李鐘聲大法官主張應不受理本件聲請案，特別是李鐘聲大法官以「政治問題原則」為據，力主不應受理的理由。相關分析，參見李建良，政治問題與司法審查——試評司法院大法官相關解釋，收於：憲法理論與實踐（一），2版，頁421（2003年）。

62 國際條約須經國會之同意，始能具有內國法之效力，已是目前各國普遍之趨勢，但「事前同意」或「事後追認」，則各國情形不一。至於所謂「行政協定」(executive or administrative agreements)，部分國家允許行政部門不經國會同意而簽訂。例如義大利、德國、波蘭、美國、奧地利等。參見Dinah Shelton, *Introduction, in* INTERNATIONAL LAW AND DOMESTIC LEGAL SYSTEMS, INCORPORATION, TRANSFORMATION, AND PERSUASION 1, 8-9 (Dinah Shelton ed., 2011).

63 國際法內國法化模式之問題，其背後涉及國際法與國內法之關係的理論爭辯，在國際法學上素有「一元論」(Monistic Theory)與「二元論」(Dualistic Theory)之分。一元論者基本上是把國際法與國內法視為同一之法體系，屬於整體的法秩序，如同一樹幹之二株分支，故國際法或國內法均直接適用於人民身上。相對於此，二元論者則是以國際法與國內法為分立之法秩序為前提，國內法之規

條約「國內法適格性」的判定準據，為內國機關（尤其是法院）能否及如何適用條約的前提性問題。此一側重於「立法層次」的法規適格課題，可以有兩個觀測角度與思考路徑，一是從國際法的層面出發，觀察國際間是否就條約之內國履行建立一套機制或設有特定之指示（國際實踐）⁶⁴；另一是從各國之法制實踐及學說發展切入，檢視各國條約內國法化的模式（國家實踐）。由於各國法制傳統與規範體制（尤其是憲法秩序）不盡相同，條約內國法化的模式及理論參差不齊、互有差異⁶⁵，可想而知。不過，由於國際條約是

範對象為個人；反之，國際法的規範對象是國家。主一元論者，二十世紀，以 Hans Kelsen、Philip Quincy Wright 為主要代表；主二元論者，有 L. F. L. Oppenheim、Heinrich Triepel 等人。此二說的爭論重點不僅只在界分國際法與國內法之體系關係，其更進一步延伸到國際法與國內法之位階關係的問題上。主二元論者強調國際法與國內法二者並無必然之上下位階關係。換言之，國際法之位階並不必然高於國內法，反之亦然，悉取決於內國之法秩序；不同於此，主一元論者在二者同屬單一法體系的前提下，採取「國際法優位」的觀點，認為國際法之位階高於國內法，在論理上又可分為「一元實證法論者」（monist-positivist）與「一元自然法論者」（monist-naturalist）二種，前者以 Hans Kelsen 為代表，主張國際法是所有法規範之「基本法」（Grundnorm），源自內國法之實踐，故在規範體系上具有優位性；主後說者，如 Hersch Lauterpacht（前國際法庭法官），其認為國際法之所以具有優位性，係因其較能提供個人之人權保障。簡要介紹，參見 OPPENHEIM'S INTERNATIONAL LAW, VOL. 1 *supra* note 52, at 53-54; MARTIN DIXON, TEXTBOOK ON INTERNATIONAL LAW 88-91 (6th ed. 2007). 學理論爭的基礎文獻，參見 Heinrich Triepel, Völkerrecht und Landesrecht, 1899; Max Wenzel, Juristische Grundprobleme, 1920, S. 359-421, 444-459; Philip Quincy Wright, The Enforcement of International Law Through Municipal Law in the United States 1-20 (Mar. 15, 1915) (unpublished Ph.D. thesis, University of Illinois) (on file with IIAS); Hans Kelsen, Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts, 1929, S. 102-241. 關於 Hans Kelsen 國際法觀點的探討，另可參見 François Rigaux, Hans Kelsen on International Law, 9 EUR. J. INT'L L. 325, 325-43 (1998).

以上二說，各有所據，迄無定論。於此必須指出者，學理爭辯與法制實踐乃屬二事，尤其國際實踐與學理發展雖相依互補，實則彼此兩立，加之各國採擇與法制建構，亦復各有不同，不宜等同視之、一概而論。參見 DIXON, *supra*, at 94. 關於一元或二元理論之內國實踐，參見 OPPENHEIM'S INTERNATIONAL LAW, VOL. 1 *supra* note 52, at 54-86.

⁶⁴ 例如在條約中明定「自動履行」（self-executing）條款。

⁶⁵ 參見 INTERNATIONAL LAW AND DOMESTIC LEGAL SYSTEMS, INCORPORATION, TRANSFORMATION, AND PERSUASION (Dinah Shelton ed., 2011) 一書中收錄 28 個國家的法制規範與司法實踐之論文。

否成為一國之法律而得以適用於個案中，嚴格而言，應屬「內政問題」，特別是內國的「憲法問題」，故國際條約的內國法化方式的探究，允宜設法循後一路徑摸索出國際條約與國內法之轉接模式。

略觀各國學說與司法實踐，基本上可以歸納出二種對立模式：「接納模式」⁶⁶與「轉換模式」⁶⁷。簡要言之⁶⁸，前者係將已生效之國際條約直接視為內國法，內國機關（法院）得以直接適用，無須任何轉換程序⁶⁹。於此模式下，國際條約具有直接之內國效力。國際條約等同於內國法，故該國際條約一旦失效，即同時喪失作為內國法之效力；後者（轉換模式），指國際條約須經轉換成國內的法律條文，始能成為國內法而予以適用⁷⁰。於此種模式下，國際條約與國內法分屬不同之法律文件，儘管內容一致，二者之效力及適用對象各不相同，國際條約失效並不當然影響國內法之效力⁷¹。綜言

66 英國學說稱之為“doctrine of incorporation”，參見DIXON, *supra* note 63, at 94.

67 一般稱為“doctrine of transformation”或“Transformationsstheorie”。

68 本文之重點非在探討各國如何將國際法內國法化之問題，故僅作簡要之說明，詳可參見姜皇池（註5），頁298以下。

69 例如希臘、保加利亞、塞爾維亞。另，美國聯邦憲法第6條第2項規定：「本憲法與依據本憲法所制定之美國法律，及以美國之權力所締結或將締結之條約，均為全國之最高法律，縱與任何州之憲法或法律有所抵觸，各州法院之法官，均應遵守而受其約束。(This Constitution, and the laws of the United States which shall be made in pursuance thereof, and all treaties made, or which shall be made, under the authority of the United States, shall be the supreme law of the land; and the judges in every state shall be bound thereby, anything in the Constitution or laws of any State to the contrary notwithstanding.)」亦可歸類為此一模式。

70 例如大英國協。儘管「接納模式」之理論基礎是建立在該國Blackstone於1769年發展的「國際法是本國法之一部分(International law is ... a part of the law of the land)」的觀念之上。但此一模式僅適用於國際習慣法，大英國協迄今仍採嚴格之「轉換理論」。

71 不過，在國家實踐上，為避免產生國際規範與內國法脫鉤之現象，於法律中明定內國法效力繫於國際法之效力，一般稱為「折衷之轉換理論」(gemäßige Transformationstheorie)。此外，於學理上，另有所謂「施行模式」或「施行說」(Vollzugslehre)，指已生效之國際法須經內國之「施行令」(Vollzugsbefehl)後，始得成為國內法，直接適用於內國，但不須轉換成法律條文。此一模式與「接納模式」頗為接近，差別僅在是否須經過特定之「國家行為」，始能打開內國適用之門。參見Michael Schweitzer, *Staatsrecht* III, 5. Aufl., 1995, Rn. 312, 321 ff.

之，「接納模式」與「轉換模式」之基本差異在於，前者之情形，除國內立法排除外，國際條約當然為內國法；反之，於後者之情形，除國內立法納入外，國際條約非屬內國法⁷²。

我國憲法究採何種模式，未盡明確，有待解釋。司法院釋字第329號解釋雖未直接明示我國憲法採取何種立法模式，然從「所締結之條約，其位階同於法律」等語似乎可以反推我國係採「接納模式」，亦即無須轉換成國內法律條文，即可適用於國內⁷³。蓋將條約與法律的位階等同視之，基本上是建立在條約與法律乃屬不同法律文件的前提上。設若國際條約須轉換成法律條文，始成為國內法，則條約既成為法律條文，其本即屬一種（形式意義之）法律，如何又謂條約位階同於法律⁷⁴？！不過，如前所述，司法院釋字第329號解釋之作成，係緣於兩岸協議是否應送立法院審議之爭議，故嚴格而言，該號解釋僅處理條約生效之正當憲法程序問題，至於條約如何成為國內法及其法效力，原非大法官作成該號解釋之所問，若以此斷言國際條約內國法化的模式業已因該號解釋而定調，似乎還言

72 須指出者，「接納模式」與「轉換模式」乃是兩種理論，其共通之旨趣在於為國際法與國內法之互動建立一套合理的接軌之道。在各國的實踐上，未必非此即彼，毋寧可能兼容採之或俱收並蓄。即以大英國協為例，其於1998年制定人權法(Human Rights Act)，將歐洲人權公約之人權規定及相關判例納入國內法，既非採「接納模式」，亦非循「轉換模式」，而是基於使公約人權規定得以適用於個案之考量，審慎衡酌既有之司法制度與權利體系而為立法，以確保國際規範之可適用性。參見DIXON, *supra* note 63, at 96-97.

73 國內學說有認為司法院釋字第329號解釋係採「一元論」。參見張文貞（註20），頁248。實則，國際法內國法化之方式與「一元論」或「二元論」之爭論，非屬於同一之問題。某一國家採取「接納模式」或「轉換模式」，僅表示該國選擇讓國際法取得國內法「效力」之「方式」，並不同時處理國際法與國內法之關係問題，尤其是位階問題。司法院釋字第329號解釋設若認為條約於我國無須轉換成法律條文即可適用，並不表示該號解釋認為國際條約與國內法屬於單一之法體系，從而國際條約之位階高於國內法律。關於「接納模式」與「轉換模式」並不當然等同於「一元論」與「二元論」之問題，參見DIXON, *supra* note 63, at 95.

74 大法官以如此簡單的文句涵蓋條約的生效方式，是否過於簡化條約內國法化的複雜問題，則屬另一問題。相關批評，參見羅昌發，立法機關參與締約過程之研究，收於：貿易關係之法律問題——國際經貿法研究（二），頁154以下（1994年）。

之過早。況且，徵諸國家實踐，我國簽訂條約後，制定法律作為施行之依據者，不乏其例。遠者如於1951年簽署「防止及懲治滅絕種族罪公約」(Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, CPPCG)，於1953年5月22日制定公布「殘害人群治罪條例」；近者如批准兩公約後，同時制定公布兩公約施行法，以為施行之依據。

尤須指出者，國際條約取得內國法的適格性，未必即能成為個案適用之法律依據，例如行政處分之依據，或法院判決（尤其刑事判決）之依據，於此不僅牽涉條約之用語、規範方式及明確程度⁷⁵，更關乎內國之憲法秩序與法治框架，前者如法律明確性原則、法安定性原則；後者如罪刑法定原則、處罰法定於則、法律保留原則（尤其是干預保留）等，乃至於更層次司法權與立法權間之權力分立原則。此外，條約之內容若涉及受益性或給付性之規定者，其履行往往牽動到一國財政預算及資源分配之問題，若乏內國有權機關（主要是民意機關）斟酌損益主客觀因素、建立一套嚴謹、公平之法則，恐難順遂落實。換言之，縱使採所謂的「接納模式」，已被接納之國際條約是否足以適用、落實於個案(implementation)，仍是一個有待解釋、探究之獨立問題。蓋並非所有國際條約（或條約之每一規定）皆課予國家有將條約內容具體化並賦予拘束力之義務。尤其國際條約多半不是規制特定國家之機關或其人民，而是以「國家」整體作為規範對象，內容且多空泛、抽象，類此條約之規定若未經轉換、建構或形成含有規範要素且具法效性之法條⁷⁶，實無以施行並適用於內國之具體個案。是以，除憲法定有明文外，各國司法實務多半嘗試從條約之文義、體系、目的、有無設定特殊之

75 國際條約之條文通常以國家作為規範之對象，其並不當然可以成為適用於人民身上之法律規定。

76 例如波蘭憲法第91條第1項規定：「經批准之國際條約於波蘭共和國法律公報公布後，即構成國內法秩序之一部分，並得直接適用。但其適用須經制定法律者，不在此限。」對於國際條約內國法化之方式係採「接納模式」，惟仍保留須經制定法律之例外規定，即考量到國際條約的可適用性問題。

權利或義務等方面，發展出可資適用之法則⁷⁷。例如美國司法實踐上發展出「自動履行條約」(self-executing treaties)與「非自動履行條約」(non-self-executing treaties)之區分理論，其原因所在⁷⁸。透過此種理論之運作，一方面得以從條約中梳理出可資適用於個案之規範，另方面藉此縮小在「接納模式」下可能產生網羅過寬之問題。

三、國際條約在臺灣的內國法化模式

在司法院釋字第329號解釋的基礎下，國際條約內國法化既未定於一尊，無特定模式，則國際條約在臺灣的內國法化模式，在憲法解釋上，仍屬開放性的問題。不過，從立法的實踐層面來看，還是可以歸納出以下4種基本模式：1. 立法程序模式。2. 成文法化模式。3. 法律援引模式。4. 行政程序模式。茲分述如下：

(一) 立法程序模式

司法院釋字第329號解釋明揭「部分條約」之位階與法律相同，則該等條約之內國化的程序即須同於法律的制定程序。參照條約及協定處理準則（最近一次修正發布：2012年5月31日）之規定，具法律位階之條約的內國法化的程序大致如下⁷⁹：

1. 具有條約或公約之名稱者，或定有批准條款者，經簽署後，主辦機關應於三十日內報請行政院核轉立法院審議⁸⁰，經立法院議決、總統公布後，具有與法律相同之效力。例如：消除各種形式種族歧視國際公約、領海及鄰接區公約、公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約等。針對後二公約，立法院並制定「公

77 詳參Shelton, *supra* note 62, at 11-12.

78 關於「自動履行條約」(self-executing treaties)與「非自動履行條約」(non-self-executing treaties)之理論與實務，參見姜皇池（註5），頁311-312；JOHN E. NOWAK & RONALD D. ROTUNDA, CONSTITUTIONAL LAW 253-55 (8th ed. 2010).

79 「兩岸協議」，在性質上亦應屬於條約的一種（中華民國與其他國家或國際組織所締約之國際書面協定），特殊之處，僅在於簽訂的方式係透過「具有國家代表權的私法組織」所為，故其內國法化的程序，理論上亦應同此。

80 條約及協定處理準則第9條本文前段。

民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法」(2009年4月22日公布)。

2. 用協定等名稱，而其內容直接涉及國家重要事項或人民權利義務者，若未經法律授權或事先經立法院同意簽訂，且其內容與國內法律不同，應依前述程序為之，亦即經簽署後，主辦機關應於三十日內報請行政院核轉立法院審議，經立法院議決、總統公布。

3. 用協定等名稱，而其內容直接涉及國家重要事項或人民權利義務，且經法律授權或事先經立法院同意簽訂，或其內容與國內法律相同者，於簽署後30日內報請行政院核備，除內容涉及國家機密或有外交顧慮者外，並應於生效後，送立法院查照⁸¹。

(二) 成文法化模式

上述之內國法化模式，係以經簽署（具有條約或公約之名稱者，或定有批准條款者）或簽訂（用協定等名稱）者為對象。由於臺灣的特殊國家地位與國際的特殊處境，少有機會直接參與國際條約的締結，上述內國法化的立法模式，運用時機有限。比較務實的內國法化方式是，透過立法程序直接將國際條約（不問是否參與簽署）的內容轉換置入法律條文之中。與所謂的「轉換模式」不同，立法機關選擇成文法化的國際條約，不以本國參與簽署者為限。我國法律中常見參考國際條約而制定或修改的規定，多為此例。前述大法官以解釋要求相關機關應參酌國際條約檢討修法（例如司法院釋字第549、578號解釋），亦屬此種內國法化的模式。國際條約的成文法化，不限於法律條文化，亦可直接透過修憲或制憲程序，使之成為憲法條文，東歐民主轉型的新憲運動，不乏其例⁸²。

另外，貿易法第7條第4項規定：「協定或協議之內容涉及現行法律之修改或應另以法律定之者，需經完成立法程序，始生效力。」亦屬成文法化模式。

⁸¹ 條約及協定處理準則第9條但書。

⁸² 參見張文貞（註20），頁231-236。

(三) 法律援引模式

除了將國際條約直接成文法化之外，尚有一種與國際條約連結的方式，係透過條約在法律中的援引或指示，概括性地將國際條約納入內國規範體系之中。類此規定，數量繁多⁸³，歸類如下⁸⁴：

1. 平等互惠條款（例如土地法第18條）。
2. 涉及外國人在本國、本國人在外國或國際事務之規定（例如引渡法第1、6條）。
3. 例外或除外規定（例如民用航空法第47條之3、政府採購法第105條）。
4. 補充性規定（例如文化資產保存法第25條）。
5. 限制或處罰之法定要件（例如民用航空法第115條、植物品種及種苗法第43條）。
6. 特別法之規定（例如所得稅法第124條、政府採購法第43條）。
7. 行政程序規範（例如政府採購法第75條）。

觀察以上規範模式與內容，平等互惠條款所連結的國際條約，嚴格而言，並非國際法的內國法化，毋寧是本國人是否因國際條約或協定而享有「國外」待遇的問題。其餘連結國際條約之規定，類型雖有不同，其內容須法律適用者（行政機關、司法機關）予以具體化則一。比較需要注意的是，直接以國際條約作為限制或處罰之法定要件之情形。由於國際條約之內容行政或司法機關未必知悉（甚至多半不知），遑論一般人民⁸⁵，故此等規定是否違反法律明確性原則與處罰法定原則⁸⁶，不無疑問⁸⁷。

83 參見「附錄三：援引國際條約之法律規定（一）」。

84 參見「附錄四：援引國際條約之法律規定（二）」。

85 更不用說，於此尚涉及應以何種語言的條約版本為解釋、適用對象的問題。若採中文版本，可能還有翻譯是否正確的問題。

86 關於國際條約與法律明確性原則之關係，參見Theo Öhlinger, Verfassungsrecht, 7. Aufl., 2007, Rz. 119.

（四）行政程序模式

司法院釋字第329號解釋理由書第1段結尾提及：「其無須送立法院審議之國際書面協定，以及其他由主管機關或其授權之機構或團體簽訂而不屬於條約案之協定，應視其性質，由主管機關依訂定法規之程序，或一般行政程序處理。」若對照本號解釋的基調：「條約＝法律＝立法院審議」，則透過「條約≠法律≠立法院審議」可以推導出「不須經立法院審議之不具法律位階之國際書面協定」的概念。此種國際書面協定之屬性及其法位階為何，暫置不論，其內國法化的模式顯非須經過立法程序，而係以行政程序方式為之。條約及協定處理準則第10條所定：「協定經簽署後，主辦機關應於三十日內報請行政院備查；……並應於生效後，送立法院查照。」即屬此種行政程序模式之明文。

伍、適用原則：國際條約之法位階與法適用問題

國際條約的內國法化，使國際條約取得國內法的效力，至於該國際條約在內國法的法地位為何，尚須探究。其一，關於國際條約與內國法之間的位階關係，學說與實務時有爭議，意見紛歧。2009年至2010年間，臺美牛肉進口議定書引發之「對外協議與國內法孰高孰低」的爭議，只是近例之一。又，基於國際條約之「普世性格」，其規範內容多半較為概括、籠統，如何於具體個案中予以適用，易生疑義。例如公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法第2條雖規定：「兩公約所揭示保障人權之規定，具

87 司法院釋字第428號解釋提及之（舊）郵政法第3條「關於各類郵件或其事務，如國際郵政公約或協定有規定者，依其規定。但其規定如與本法相牴觸時，除國際郵件事務外，適用本法之規定。」基本上亦涉及以國際條約限制人民權利之問題。惟因系爭限制於郵政法中定有規定，故不生違反法律明確性原則之問題，大法官對此亦未提出質疑。

有國內法律之效力。」但兩公約如何解釋、適用，其與憲法、法律之間的關係如何⁸⁸，仍待究明，此等問題顯然不是單靠上舉施行法第2條此一規定所能解決，亦非可以憲法第141條「尊重條約及聯合國憲章」為據，跳躍式地導出凡條約經過立法院批准即優先法律而適用的結論⁸⁹。國際條約與內國法「接軌」之真正關鍵及棘手難題，存乎於此，有待詳析深究。

一、國際條約之法位階定序

國際條約進入內國法規範體系之後，與既有法規範產生或相容或排斥的關係，基本上屬於國內法問題，故國際條約的法位階定

⁸⁸ 兩公約施行後，相關討論文獻甚多，舉其要者：陳清秀，兩公約實踐與賦稅人權保障，法令月刊，62卷2期，頁67-82（2011年）；王自雄，人權兩公約之國內法化暨其施行法之實施——從國際法的內化與人權在我國憲政體制下之法律地位論起，台灣法學雜誌，164期，頁113-122（2010年）；廖福特，法院應否及如何適用公民與政治權利國際公約，台灣法學雜誌，163期，頁45-65（2010年）；張文貞（註20），頁1-26；陳怡凱，國際人權公約之內國效力——以公民與政治權利公約暨經濟社會文化權利公約施行法為例，收於：社團法人台灣法學會編，台灣法學新課題（八），頁27-68（2010年）；郭書琴，多元家庭與家事事件之實體與程序——自「經濟社會文化權利國際公約」第10條的內國化談起，收於：社團法人台灣法學會編，台灣法學新課題（八），頁69-100（2010年）；謝靜慧，公民權利和政治權利公約暨經濟社會文化權利公約下之兒童及少年人權——以法官保留原則與專業法庭（院）之運作現況為中心，收於：社團法人台灣法學會編，台灣法學新課題（八），頁101-150（2010年）；陳耀祥，從兩公約之批准論經濟管制與財產權之保障——以通訊傳播產業為例，收於：社團法人台灣法學會編，台灣法學新課題（八），頁151-180（2010年）；徐揮彥，從國際人權規範論我國對文化權之實踐，收於：社團法人台灣法學會編，台灣法學新課題（八），頁181-256（2010年）；黃明展，論兩公約施行法之生效對判決與執行死刑之影響（上），司法周刊，1492期，頁2-3（2010年）；黃明展，論兩公約施行法之生效對判決與執行死刑之影響（下），司法周刊，1493期，頁3（2010年）；翁國彥，給一個說法——兩公約實施與律師執業的嶄新挑戰，在野法潮，5期，頁10-11（2010年）；朱楠，推動「廢除死刑」之新契機——立法院通過兩國際人權公約施行法之實務分析，法學新論，19期，頁57-69（2010年）；林佳範，論兩公約對憲法人權保障的補充——一個初步架構的探討，全國律師雜誌，14卷3期，頁23-41（2010年）；黃文雄，台灣如何成為人權大國？——簽署兩公約批准書之後的省思，司法改革雜誌，72期，頁54-55（2009年）。

⁸⁹ 參見黃昭元（註8），頁63-65。

序，亦須放在內國法位階秩序底下來觀照。一國之法規範秩序，於公法領域，由上而下，由抽象到具體，大抵分為憲法、法律、命令、裁判／行政處分／行政契約等4個層次，臺灣亦不例外。國際條約屬於抽象規範，其法位階定位有憲法、法律、命令三種選項⁹⁰。

雖說國際條約的法效力與法位階，在觀念上分屬不同層次，但二者間仍有相互連動之關係，尤其在司法院釋字第329號解釋建立的「條約＝法律＝立法院審議」的基調之下，標定國際條約之法位階，還是必須從內國法化的程序著手。姑不論大法官先將憲法上「條約」概念賦予法律的位階，再要求該等條約須經立法院審議的論斷不無倒果為因之病，至少可資確定的是，凡經立法院依法律制定程序審議通過的條約，具有法律的位階。同理，國際條約依前述「成文化模式」及「法律援引模式」而內國法化者，亦同具法律的位階。相對而言，依「行政程序模式」而內國法化的條約，因欠缺立法程序的提階，至多僅能具有相當於行政命令的位階。

於學理上饒負爭議的是，內國法化之國際條約是否具有憲法的位階？尤其是具有「普世價值」之國際人權條約或公約？針對此一問題，國內學者間不乏主張兩公約具有憲法或準憲法之位階或效力者⁹¹。就此，本文持保留立場。蓋修憲程序的門檻高過法律制定或修改的程序⁹²，單從程序的角度來看，以立法程序審議通過之國際條約即已不可能具有憲法位階，除非憲法特別規定或可以在憲法上找到立基點⁹³。至於透過「解釋模式」賦予國際條約憲法或準憲法

90 從憲法及國內法體系的觀點，國際條約一般屬於「中央法規」（國家法規），故無相當於地方自治規章的層次，此亦應為其他國家的通例。另參Öhlinger (Fn. 86), Rz. 121.

91 例如有認為：「法律上之拘束力仍不足以達成國際人權法在憲法層次上的匯流，還必須使這些具有國內法律位階效力的國際人權條約享有準憲法位階的地位或功能，而這一點就要透過解釋模式才能克竟其功。」參見張文貞（註20），頁253以下。

92 尤其是加入公民複決之修憲程序，已使臺灣憲法成為「超級剛性」的憲法。

93 以1953年9月3日生效之「歐洲保障人權及基本自由公約」（一般簡稱「歐洲人

位階，亦須在憲法上找到規範的支撐點，否則有違權力分立及民主原則。實際上，截至目前為止，大法官亦未曾直接透過解釋賦予條約憲法位階⁹⁴。

二、不同位階之法適用問題

承上所述，內國法化的國際條約，基本上可分為憲法、法律、命令三種位階層次。姑且不論本文認為我國目前尚乏具憲法位階之國際條約，不同位階之國際條約之適用關係，依憲法第171條、第172條所揭示的「法律牴觸憲法無效」、「命令牴觸憲法或法律無效」之規範階層原則定之。此所謂之國際條約的內涵，除抽象之規定外，尚應包括國際法院解釋、適用該條約表示法律見解之裁判。此等司法裁判隨其所適用條約而取得該條約之法位階，從而國際法院裁判足以影響一國的法秩序與法解釋⁹⁵，甚至形成某種跨國性的法繼受⁹⁶。

權公約」) 為例，該公約揭示的人權與基本自由具有普世性的價值，為一般所公認，對於歐洲國家（尤其是簽約國）卻非當然具有憲法位階。奧地利於1958年加入該公約，最初該國憲法法院對該公約的憲法位階即有所質疑。1964年3月4日，奧地利通過「包裹修憲」(BVG vom 4. 3. 1964, BGBl. Nr 59)，於第二大條(Artikel II)將13種國際條約（其中包括歐洲人權公約）明定為「具有修憲性質之國家條約」(verfassungsänderende Staatsverträge)。自此之後，歐洲人權公約於奧地利始具有憲法位階，而該公約所保障之權利，即自動成為奧地利聯邦憲法第144條所稱「憲法上保障之權利」(verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte)。參見Öhlinger (Fn. 86), Rz. 131, 681.

94 參見本文「參」之整理分析。

95 司法院釋字第392號解釋在解釋憲法第8條第2項所稱「該管法院」的意涵時，於理由書參酌「歐洲保障人權及基本自由公約」第5條第3項、「聯合國公民及政治權利國際盟約」第9條第3項、「美洲人權公約」第7條第5項規定，並援引歐洲人權法院於1988年關於「包威爾斯」案之判決，以論證該管法院「限於狹義之審判法院」，即屬一例。不過，嚴格而言，歐洲人權法院判決並不具有「憲法位階」，蓋臺灣並非「歐洲保障人權及基本自由公約」的成員國。因此，縱使歐洲人權法院判決認為前開公約第5條第3項所指之「依法執行司法權力之其他官吏」包括檢察官在內，就我國憲法之解釋而言，亦無憲法上之拘束力。

96 例如歐陸憲法法院，尤其德國憲法法院，係以奧地利模式為基礎。1920年，在Hans Kelsen強力影響之下，奧地利設立憲法法院，同樣也受到Kelsen的影響，

除了國際條約本身之法位階外，尚須說明國際條約與內國法之間的法位階排序關係。具法律位階之國際條約，其位階與國內法之法律相同。至於國際條約是否優先於國內法之法律而適用，則屬相同位階之法適用問題（詳見後述）。因此，基於內國法律之授權而訂定之行政命令，其位階低於國際條約。例如郵政法第13條：「關於各類郵件或其事務，國際郵政公約或協定有規定者，依其規定。但其規定與本法牴觸者，除國際郵件事務外，適用本法之規定。」則依郵政法第48條⁹⁷授權訂定之郵件處理規則，其效力即低於萬國郵政公約⁹⁸。此外，主管機關本於法定職權就相關法律所為之闡釋（函釋），除應遵守一般法律解釋方法及秉持憲法原則外，應通盤考量相關法律之立法意旨及國際條約之規範意旨。行政函釋若牴觸內國法化之條約及其相關國際裁判與解釋，即有違「法律優位原則」，若增加國際條約所無之限制，則進一步牴觸「法律保留原則」，二種情形之函釋均因構成違法而違憲。

三、相同位階之法適用問題

屬於同一位階之國際條約或內國法規，如因內容相互衝突而生法適用之問題，基本上無涉「位階上下」關係的排序，而是「新法

該憲法法院的職權僅侷限在以憲法上權限及程序規定為準據，進行法律的違憲審查。至於基本權利的法律保留，意味授權法律得任意限制基本權利，也就是承認立法者是唯一且不受審查之基本權利解釋者。此種見解持續至二次戰後，仍未改變。遲至1984年之後，因歐洲人權法院廣泛適用比例原則審查法律是否符合歐洲人權公約（此點主要又受德國憲法法院裁判的影響），而歐洲人權公約於奧地利又具有憲法位階，始促使奧地利憲法法院援引比例原則對於法律的「實質」內容進行審查。參見Christian Starck著，李建良譯，全民基本共識與憲法法院裁判權，收於：Christian Starck著，李建良、范文清、蔡宗珍、陳愛娥、楊子慧譯，法的起源，頁294-295（2011年）。

97 內容：「郵件種類、定義、處理程序、交寄、資費之交付、載運、投遞與查詢補償確定之程序、金額與其方法、禁寄物品之種類與其處分方法、受委託遞送郵件者之資格條件、委託程序與責任及其他相關事項之規則，由主管機關擬訂，報請行政院核定之。」

98 參見司法院釋字第428號解釋。

優於舊法」或「特別法優於普通法」之法規範效力的解釋（選法）問題，應回到一般法律解釋方法，進行法規意旨之解讀與適用。換言之，同一位階法規適用之優先順序的判定，並無放諸四海之一般性準則，除憲法明定外，基本上並無所謂「國際法優於國內法」之原則⁹⁹，而須在各該法規脈絡中找到優先適用的準據，法律適用者且應提出何以優先適用之法律上理由。

司法實務上，早年的最高法院23年上字第1074號刑事判例要旨曾謂：「上海公共租界內設置之法院，其土地管轄應以案件在各該法院管轄區域內發生者為限，此徵之關於上海公共租界內中國法院之協定第五條第二項所載，其他案件在各該法院管轄區域內發生者，應由工部局捕房起訴云云，至為明顯。國際協定之效力優於國內法，該協定關於土地管轄，既有此特別規定，自無適用刑事訴訟法第十三條之餘地。」（粗體為作者所強調）

這則判例只有結論，欠缺說理，應不足憑。最高法院99年度第1次刑事庭會議雖以「本則判例不合時宜」為由，決議不再援用。然所謂「不合時宜」，係指「國際協定之效力優於國內法」之一般法則，抑或僅指「上海公共租界內中國法院之協定」之「公共租借」的時過境遷，或該針對「中國法院」之協定不適用於臺灣法院，或臺灣法院對於發生在上海的刑事案件已無管轄權，不得而知¹⁰⁰。

99 東歐新興國家賦予國際人權法優於國內法律效力，係基於憲法的明文。例如1992年捷克憲法第10條規定：「經簽署及公布之人權及基本自由公約，捷克共和國受其拘束者，直接具有效力且優先於法律。」此條規定於2001年修改為：「經公布之條約，其簽署經國會同意，捷克共和國受其拘束者，屬於法秩序之一部分；條約之規定與法律規定不同者，優先適用條約之規定。」

100 不過，無論如何，引用此則判例的裁判，其法律見解亦應「不再援用」。例如：最高法院72年度台非字第228號刑事判決：「非常上訴理由稱：按條約之簽訂，須由立法機關審議通過，經國家元首批准並公布，締約之程序，與法律案須經立法機關審議通過國家元首公布施行者，大致相同，故條約與國內法有同等效力，且條約係就締約國間之特別事項而為規定，依國際法應遵守國際信義之慣例，世界上絕大多數國家均認條約具有特別法之性質，其效力

實際上，「國際協定之效力優於國內法」的觀念仍散於司法裁判中（參見「附錄五：關於國際條約效力位階之裁判」）。例如最高法院74年度台非字第137號刑事判決：「本件原判決既認國際協定之效力優於國內法，中美友好通商航海條約又已於民國三十七年十一月三十日生效，雖中美兩國於六十八年一月一日終止外交關係，但據雙方達成之協議，……自應繼續有效，……此項條約之規定，其效力既應優於國內法，則本件美商永備聯合電石公司……，提起第二審上訴，原第二審判決竟亦以同一理由予以維持，駁回其第二審上訴而確定，自有不適用國際協定優於國內法法則之違法，……。」（粗體為作者所強調）

又如最高法院72年度台上字第1412號民事判決謂：「中華民國與美利堅合眾國友好通商航海條約，於民國三十五年十一月四日簽訂，經立法院議決批准公布，並於三十七年十一月三十日互換，同日生效，依我國憲法第一百四十一條所定『尊重條約』及同法第六十三條所定條約定須經立法院議決之規定以觀，該友好通商航海條約，實已具有國內法之同等效力，法院自應予適用。」（粗體為作者所強調）

此外，行政函釋亦不乏持此見解，例如：法務部1983年2月21日法律字第1813號函：「條約在我國憲法及有關法律中均未明文規定其具有國內法的效力，但立法院審查條約案時，與審查法律案的程序完全相同，條約亦和其他立法院通過的法律一樣，均刊登在立法院公報及立法專刊中，是條約在我國應具有國內法之效力。復從憲法第一百四十一條精神以觀，條約與國內法牴觸時，似宜優先適用條約。」行政院（60）台內字第7317號函：「依國際法適用原

尤優於國內法，我國司法院民國二十年七月二十七日致前司法行政部第四五九號訓令，略謂：『原則上法律與條約牴觸，應以條約之效力為優，若條約批准在後或與法律頒布之日相同，自無問題，若批准在頒布之前，應將牴觸之點隨時陳明候核。』最高法院二十三年上字第一〇七四號判例，亦謂：『國際協定之效力，優於國內法。』」

則，凡經一國國會通過並經批准之國際公約，其效力應優先於各該國內法而適用，本案我國國籍法第十六條對於申請回復國籍者，雖加以若干條件之限制，惟上開國際聯合會國籍法公約第七條明定在取得另一國籍前不應有喪失國籍之效果，其規定之效力，自應優先於我國國籍法而適用，關於旅菲華僑陳天保及陳秀珍等五人申請回復國籍乙節，可依該部與有關單位會商之結論第一項照上開國籍法公約第七條規定辦理。」（粗體為作者所強調）

以上之法律見解，多屬「結論式」的說法，欠缺理據，偶有援引憲法第141條「尊重條約」規定為依據。惟如前所述，憲法第141條所稱之「條約」，從體系解釋來說，未必皆是（須）經立法院審議通過之國際書面協定，且該條係規定「外交」應尊重條約，實難推導出內國法院應優先適用條約之論斷。蓋內國法院是否應優先適用條約，乃是一項規範性課題，尤其涉及法院（法官）應依何種規範審判，以及法院（法官）是否受該規範拘束之問題，必須在憲法上找到規範上之依據。憲法第80條規定：「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」其中所稱「法律」者，固不以立法院通過、總統公布者為限，尤應包括憲法在內¹⁰¹。而「條約」是否屬憲法第80條所稱之「法律」，須從憲法整體規範秩序判斷之，非僅得以形式之外觀（凡有條約之名稱者）為據。是以，憲法第141條所稱之「條約」是否屬憲法第80條所稱之「法律」，即非能單從文義判斷。況且，憲法第141條係規定「外交」應尊重條約，其規範對象並非「法院」，故由此規定無法推導出內國法院應優先適用條約之結論。

近期，司法實務對於「國際法之效力應優先於國內法」之「鐵則」似乎有鬆動的跡象，以最高行政法院93年度判字第281號判決為例，其謂：「本院按國際法與國內法為平行之法律體系，且均為行政法之法源；惟國際法要成為行政法之法源，並非毫無限制，必須

¹⁰¹ 參見司法院釋字第371號解釋。

條約或協定明定其內容，始可直接引用作為法規適用。或將條約、協定內容，透過國內法規之訂定，訂定於相關法規，才能有效執行外，必須司法審判機關採用，作為判決先例。一般而言，於國際法與國內法衝突時，國際法之效力應優先於國內法；但其應具上開要件，始有優先於國內法適用之餘地，……。我國與美國固簽訂友好通商航海條約，該條約第九條固規定：『締約此方之國民、法人及團體，締約彼此領土內，其發明、商標及商號之專用權，依照依法組成之官廳現在或將來所施行關於登記及其他手續之有關法律規章（倘有此項法律規章時），應予以有效之保障；……。』惟此『有效之保障』並未明訂於該條約，亦未訂定於相關法規，更未經本院判決先例採用，各級行政法院自無依上訴人之主張，直接適用美國專利法第四十一條第(c)項第(1)款之規定：『若因不可避免之事由致無法於(b)所定之六個月緩衝期內繳納權利維護費用時，得於緩衝期滿後二十四個月內繳納維護費用，該專用權年費視為未逾期繳納』之餘地。」（粗體為作者所強調）

從「國際法……應具上開要件，始有優先於國內法適用之餘地」等語，可知國際法之效力應優先於國內法須具備一定的「要件」。就此而言，國際法之效力應優先於國內法的原則似乎已被相對化而非必然。不過，細究最高行政法院所設定的「優先適用要件」：

1. 必須條約或協定明定其內容，始可直接引用作為法規適用，
或
2. 將條約、協定內容，透過國內法規之訂定，訂定於相關法規，且
3. 必須司法審判機關採用，作為判決先例。

上開要件的內涵，實非證成國際條約具有「優先效力」的理由，而是國際條約內容「具體化」與「內國法化」的問題。以本件爭點來看：美國專利法第41條第(c)項第(1)款規定是否（優先？）適用於我國，關鍵在於中美友好通商航海條約第9條所定「有效之

保障」是否將「美國法律」包含在內，而非該「條約」的效力高於「國內法」。況且，國際條約須經司法審判機關採用，作為判決先例，始具有優先效力，亦與條約本身的效力無關，此毋寧是法院見解的權威性使然。總而言之，最高行政法院意識到國際法之效力未必優先於國內法，固值肯定，然如何正確認知國際法與國內法之適用關係，並詳予論證，仍有相當長的路要走¹⁰²。

陸、案例研究：液晶顯示器課徵關稅之法適用爭議

茲以近日因液晶顯示器課徵關稅而引發之國際條約與內國法之位階關係及法適用爭議為例，探討國際條約之法適用問題。

¹⁰² 兩公約成為國內法之後，實務上時有援引兩公約作為訴訟主張依據之情形，尤其在環境行政訴訟上常見環保團體引據兩公約作為權利主張之例。目前行政法院的基本立場多半是兩公約的內容須經本國相關法規之具體化，始能適用。茲以爭議多年、眾所矚目的「中科三期二次環評撤銷訴訟案」為例，略作說明。緣中科三期開發案所在地之當地居民對於環保署於民國99年9月2日公告之開發計畫環境影響說明書有條件通過之審查結論（下稱「99年審查結論」），依法循序提起行政爭訟，其中之一項法律主張為：99年審查結論之作成，忽視原告及其他當地居民受兩公約保障之適當住居權、健康權、農業灌溉及民生用水權。就此主張，臺北高等行政法院的回應是：「我國雖通過兩公約施行法，各級政府機關行使職權，應符合兩公約有關人權保障之規定。惟兩公約須由本國憲法及相關法規使之具體化，有關環境保護之問題則有賴環境基本法等法規予以規範。本件有關99年審查結論是否合法，仍須視有無違反環評法之規定，亦即應以本國法審視其違法性。原告以99年審查結論有條件通過第一階段環評，未進入二階環評，不論其有無違反環評法，即認為係屬忽視原告及其他當地居民受兩公約保障之適當住居權、健康權、農業灌溉及民生用水權，自非可採。」（參見臺北高等行政法院100年度訴字第118號判決）行政法院不以「國際法之效力應優先於國內法」為前提之基本立場，可資贊同，而其認為「兩公約須由本國憲法及相關法規使之具體化」之審慎態度，亦可支持。然於環境影響評估法規意旨之解釋適用時，是否全然排斥「當地居民受兩公約保障之適當住居權、健康權、農業灌溉及民生用水權」而不用？換言之，此等權利是否亦得納入現行法規體系脈絡中予以詮釋？非無探討研酌之餘地。

一、事實背景與爭點整理

奇美電子股份有限公司（下稱奇美公司）於2005年12月15日至2006年4月31日間向財政部高雄關稅局報運進口具有數位視訊介面(digital visual interface)之液晶顯示器共29批，並以稅則號別8471.60.90.90-3號「其他輸入或輸出單元，在同一機殼內不論其是否含有儲存單元者」申報通關，其適用關稅稅率為0%。嗣經財政部高雄關稅局事後審查，依財政部關稅總局2004年10月6日台總局稅字第0931017520號函¹⁰³及2005年11月3日臺總局稅字第0941023157號函¹⁰⁴，2006年2月7日臺總局稅字第0951002367號函，認定該批顯示器因具有DVI端子，能接受影像信號，應改列稅則號別8528.21.90號「其它彩色影像監視器」而適用10%之關稅稅率，並據以補徵進口稅款共計新臺幣（下同）37,622,603元。奇美公司不服高雄關稅

103 財政部關稅總局函，內容如下：

「主旨：關於貴局函詢『液晶（電漿）顯示器』及『液晶（電漿）電視』等二項貨品可歸屬之貨品分類號列一案，復請查照。

說明：

一、復貴局九十三年九月二十九日貿服字第09300111330號書函。

二、本案貨品依所檢附資料，『液晶（電漿）顯示器』若僅能接受自動資料處理機中央處理單元所傳送之信號者，宜歸列稅則號別第8471.60.10號；若可接受影像信號而來具影像調節器者，宜歸列稅則號別第8528.21.90號；『液晶（電漿）電視』不論是否並含接電腦介面，宜歸列稅則號別第8528.12.90號。請卓參。

正本：經濟部國際貿易局」

104 財政部關稅總局函，內容如下：

「主旨：關於貴局函詢『電漿顯示器型號：MP-42EN-S』1項之貨品分類號列乙案，復請查照。

說明：

一、復貴局94年11月1日貿服字第09400132750號書函。

二、本案貨品具有DVI（數位視訊介面）輸入端子，可支援高寬頻數位電視（HDTV）解析度，為數位或高畫質多媒體顯示器，宜歸列稅則號別第8528.12.90號。

三、另本總局93年10月6日台總局稅字第0931017520號函說明二、……『液晶（電漿）顯示器』若僅能接受自動資料處理機中央處理單元所傳送之信號者，宜歸列稅則號別第8471.60.10號；……乙段，其中『8471.60.90號』筆誤，應請予更正為『8471.60.10號』并此敘明。

正本：經濟部國際貿易局」

局上開核定，而循序提起復查、訴願、行政訴訟等程序，仍遭最高行政法院99年度判字第151號判決（以下稱系爭判決）駁回確定¹⁰⁵。上開函釋是否違法、違憲，值得探討。

系爭函釋是否牴觸憲法之主要爭點在於，其對稅則號別第8528節及第8471節之解釋及適用範圍之認定標準，是否違反「海關進口稅則」及「國際商品統一分類制度註解（HS註解）」，而牴觸租稅法律主義？

海關進口稅則，係關稅法第3條第1項明文規定並由立法院制定公布之課稅依據，而「國際商品統一分類制度註解（HS註解）」¹⁰⁶則是海關進口稅則總則明定得予參據之國際文件，同時構成關稅課徵之法律依據，故系爭函釋若牴觸上開規定，即構成租稅法律主義之違反。

關稅之課徵與國際貿易之自由化互有關聯，國際間基於貿易自由化之考量，常透過公約與協定進行關稅減讓，尤其在WTO的規範架構之下，故國際條約或協定往往構成一國關稅課徵的法源之一，從海關進口稅則援引國際文件，可知一斑。系爭液晶顯示器，性質上屬資訊科技產品，針對資訊科技產品之關稅課徵問題，世界貿易組織會員國共同簽訂「資訊科技協定」(Information Technology Agreement, ITA)，約定各會員國應就其附件所列特定資訊產品提供「零關稅」待遇，我國亦為WTO成員，從而ITA之性質及法位階為

105 主要理由為：一、系爭顯示器雖不能接受音頻訊號，但因具DVI端子，可接受數位影像訊號，即能連接、顯示來自閉路電視系統、DVD播放機或網路攝影機等之影像訊號，支援高頻寬數位，已溢出稅則號別第8471節強調「僅能接收自動資料處理機中央處理單元所傳送之信號」之範圍。二、系爭顯示器因具DVI端子而得以擴展其影像信號之傳送來源，已具多媒體顯示器之功能，故屬稅則第8528節「基本上係由能產生光點並與信號源影像同步顯示於螢幕上之裝置所組成」之影像監視器。

106 HS為The Harmonized Commodity Description and Coding System (Harmonized System)的簡稱，係由關稅合作理事會(the Customs Co-operation Council, CCC)，現改稱為世界關務組織(The World Customs Organization, WCO)制定的一套國際性商品分類制度，旨在使貨品說明與分類統一，由5019組商品組成，共分21類(Section)、99章(Chapter)、1241節(Heading)。

何？系爭函釋是否牴觸ITA？亦屬審查系爭函釋是否牴觸租稅法律主義必須釐清與探究之問題。在此基礎下，本案之爭點及問題層次，依序如下：

1. 我國關稅課徵之法律規範構造為何？即關稅法、海關進口稅則及HS註解之間的規範構造及位階關係？
2. ITA之性質及其與海關進口稅則暨HS註解之關係？即ITA於我國法體系之法位階為何？得否作為我國課徵關稅之法源？
3. 系爭函釋是否違反租稅法律主義？此一問題又可細分為：
 - 1) 系爭函釋本身得否作為課徵關稅之依據？
 - 2) 系爭函釋是否牴觸上位階之法規範（包括ITA），從而違反法律優位原則？否違反租稅法律主義？

二、關稅法的課徵規範構造與法位階

關稅，指對國外進口貨物所課徵之進口稅（關稅法第2條），除關稅法另有規定外，依海關進口稅則徵收之（關稅法第3條第1項前段）。海關進口稅則，另經立法程序制定公布之（關稅法第3條第1項後段）。

據上可知，關稅的課徵，係依立法院制定公布的「海關進口稅則」為之。換言之，何種進口貨物應課徵關稅，係由立法機關自行決定，並未授權行政機關定之。經立法院制定公布之「海關進口稅則」，具有法律位階。

海關進口稅則分成「各類章內容」、「解釋準則」及「總則」三部分。各類章內容係以類、章兩種層次，列舉應課徵關稅之項目，共有二十類、九十八章。解釋準則，係辦理應課徵貨物分類之依據，其主要內容：「海關進口稅則貨品之分類應依下列原則辦理：一、類、章及分章之標題，僅為便於查考而設；其分類之核定，應依照稅則號別所列之名稱及有關類或章註為之，此等稅則號別或註內未另行規定者，依照後列各準則規定辦理。……三、貨品因適用準則二（乙）或因其他原因而表面上可歸列於兩個以上之稅則號別

時，其分類應依照下列規定辦理：(甲)稅則號別所列之貨品名稱說明較具體明確者，應較一般性說明者為優先適用。當兩個以上之稅則號別，而每個稅則號別僅述及混合物或組合物所含材料或物質之一部分，或各僅述及供零售之成套貨物所含部分貨品，則前述之各稅則號別對該等貨品可認為係具有同等之具體明確性，縱使其中之一稅則號別較他稅則號別所載者更為完備或精確。」其中所稱「稅則號別」及「貨物名稱」，係以附表方式與海關進口稅則一併公布，屬於海關進口稅則不可分割的部分。

海關進口稅則「總則」，係說明海關課徵關稅之準據，其第一點規定：「一、本稅則各號別品目之劃分，除依據本稅則類、章及其註，各號別之貨名及解釋準則之規定外，並得參據關稅合作理事會編纂之『國際商品統一分類制度(HS)註解』及其他有關文件辦理。」

綜上所述，關稅法、海關進口稅則（含總則、解釋準則、稅則號別、貨物名稱）及HS註解，乃共同構成我國關稅法制上海關判定貨物進口稅則的法律依據¹⁰⁷，均具有「法律」的位階。尤其值得指出者，立法機關將關稅合作理事會編纂之「國際商品統一分類制度註解（HS註解）」及其他有關文件直接納為稅則號別品目之認定準據，顯示國際法暨國際條約為判定關稅課徵項目的重要準據。

三、資訊科技協定(ITA)之性質與位階

ITA源於1996年12月WTO新加坡部長會議宣言，其後經多國聲明加入，達全球資訊科技產品貿易總額之90%，於1997年7月1日正式生效。ITA性質上屬於一種關稅減讓機制。參與國應將ITA有關降稅的規範轉換於該國關稅減讓表中，即須涵蓋ITA清單所列產品

¹⁰⁷ 至於中華民國海關進口稅則及輸出入貨品分類表合訂本之總說明規定：「……關於貨品號列及品目之劃分，及稅則號別之認定，應依據海關進口稅則總則及解釋準則所載有關規定辦理。」僅具說明性質，其本身並非課徵關稅的法源依據。

項目，並分階段將關稅調降至零。要言之，ITA針對資訊科技產品規範零關稅之貿易待遇，為部門別的自由化方案之一。ITA不同於僅適用於簽署該協定會員國之間的多邊協定，而係所有WTO會員國履行其承諾的關稅減讓義務¹⁰⁸，該等優惠除及於所有ITA參與國外，未簽署ITA的其他WTO的會員也同享此優惠。ITA雖僅為WTO部長會議宣言，但該宣言的WTO會員將該其所揭示的資訊科技產品貿易自由化目標納入WTO關稅減讓表，成為關稅承諾的一環，受「關稅暨貿易總協定(General Agreement on Tariffs and Trade, SATT)」有關關稅減讓之規範，對於WTO會員具有法律上之拘束力，我國自不例外。

四、資訊科技協定(ITA)與HS註解之關係

ITA固然確立資訊科技產品規範零關稅之貿易待遇基本原則，但哪些產品項目應列入附件A及附件B所列之產品清單，尤其新興科技產品，卻屢生爭議，即所謂產品範圍之爭議，其主要涉及產品範圍擴大、新興產品認列及產品稅則歧異等問題。就此，ITA附錄第3段規定：各參與國應在貨物貿易理事會架構下，定期檢討本協定附件A及附件B所列之產品項目，以共識決之方式決議相關之附件是否應配合修訂增列他類產品項目。根據此一規定，WTO貨品貿易理事會於1997年3月26日通過「ITA執行方案」，強調ITA委員會在檢討過程應考量資訊科技產品貿易型態之改變。各參與國同意考量世界關務組織有關「國際商品統一歸列代碼(HS CODE)」之解釋與見解，達成所有資訊科技產品均賦予HS CODE號列之共同目標¹⁰⁹。

108 INTERNATIONAL TRADE CENTER (ITC), TRADE IN INFORMATION TECHNOLOGY PRODUCTS AND THE WTO AGREEMENTS: CURRENT SITUATION AND VIEWS OF EXPORTERS IN DEVELOPING COUNTRIES (1999); Luzius Wasescha & Markus Schlagenhof, *Information Technology Agreement (ITA): Towards a New Area of Sectorial Market Liberalisation in WTO*, 53 AUSSENWIRTSCHAFT 113, 113-27 (1998).

109 WTO, Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products, WT/MIN (96)/16, para. 5 of ITA.

貨品貿易之歸列標準，係依據世界關務組織所定之HS CODE，提供一套標準化的貨品歸列，主要用於貨品物理外觀與特徵歸列上的實體貿易，提供徵收關稅、採行進出口措施與從事貿易統計等工作之依循。世界關務組織並訂有一份關於HS CODE的通用規定，提供各國海關於面臨歸列爭議時之判斷依據，我國亦參照辦理，訂有「中華民國商品標準歸列解釋準則」。

ITA附件A以HS CODE稅號臚列產品，附件B項目並未明定HS CODE，而係採產品名稱描述方式表列。WTO關稅減讓表所列之產品稅則號列，主要是依據HS CODE，故為各國修訂其海關進口稅則的主要依據，並為ITA產品範圍認定的重要依據。

五、系爭函釋違反租稅法律主義

基於上述觀點，探討財政部關稅總局93年10月6日臺總局稅字第0931017520號函及94年11月3日臺總局稅字第0941023157號函，即涉及「函釋」是否違憲之問題。

關於函釋與租稅法律主義之關係，歷來大法官解釋之基本態度是：憲法第19條規定，人民有依法律納稅之義務，係指國家課人民以繳納稅捐之義務或給予人民減免稅捐之優惠時，應就租稅主體、租稅客體、租稅客體對租稅主體之歸屬、稅基、稅率、納稅方法及納稅期間等租稅構成要件，以法律定之。惟主管機關於職權範圍內適用之法律條文，本於法定職權就相關規定予以闡釋，如係秉持憲法原則及相關之立法意旨，遵守一般法律解釋方法為之，即與租稅法律主義無違¹¹⁰。

姑且不問何謂「秉持憲法原則及相關之立法意旨，遵守一般法律解釋方法為之」，函釋若要與租稅法律主義無違，其前提要件是，該函釋必須由主管機關所為，且在法定職權範圍，同時涉及法

¹¹⁰ 參照司法院釋字第607號、第625號、第635號、第660號、第674號、第685號解釋。

律條文之適用。換言之，函釋乃法律意旨之闡釋，其本身不具法規創造力。也因此，於法律意旨之適用存有解釋空間時，方有函釋存在之可能，屬立法者規範權限之範疇，即非函釋所得僭越者。

關稅法未如一般之法律設有「主管機關」之條款，亦無授權主管機關訂定相關子法之明文，此一特點與關稅課徵屬法律保留事項有關（詳見前述）。不過，從各該條文內容以觀¹¹¹，關稅之課徵，尤其關稅稅率的研訂，其主管機關在中央應為財政部，而非關稅總局。又觀諸財政部關稅總局組織條例第2條規定¹¹²，財政部關稅總局所掌理的事項，亦不包括關稅稅則之解釋與適用。就此以言，關稅總局之系爭函釋實非「主管機關」於職權範圍內適用之法律條文，本於「法定職權」就相關規定所為之闡釋，其作為課徵關稅之依據，與租稅法律主義之意旨不無相違。

次就函釋形式以觀，系爭函釋係就經濟部國際貿易局函詢所為之答覆，國際貿易局並非執行關稅課徵之海關，故系爭函釋純屬機關內部間之意見交換，能否作為課徵關稅之依據，不無疑問。

再查函釋之內容，其係有關液晶（電漿）顯示器之如何歸列稅則號別，亦即系爭貨品具有 DVI 端子，可支援高解析度電視(high definition television, HDTV)，為數位或高畫質多媒體顯示器，宜歸列稅則號別第 8528.12.90 號。確切而言，系爭函釋將原本零關稅之「液晶（電漿）顯示器」歸列為應課關稅之「電視」，由此以觀，系爭函釋內容已非單純法律

111 例如關稅法第3條第2項規定：「財政部為研議進口稅則之修正及特別關稅之課徵等事項，得設關稅稅率委員會，其組織規程由財政部擬訂，報請行政院核定。所需工作人員，由財政部法定員額內調用之。」同法第5條第2項：「前項關稅配額之分配方式、參與分配資格、應收取之權利金、保證金、費用及其處理方式之實施辦法，由財政部會同有關機關擬訂，報請行政院核定之。」

112 內容為：「財政部關稅總局（以下簡稱本局）掌理左列事項：一、關於徵免關稅之核辦、核轉事項。二、關於關稅稅則之研修建議事項。三、關於私運貨物進出口之查緝事項。四、關於進口貨物價格之調查、審核事項。五、關於進出口貨物之化驗、鑑定事項。六、關於外銷品之進口原料保稅、退稅之核辦事項。七、關於燈塔及助航設備之建管、補給及無線電管理事項。八、關於關稅資料之建立處理事項。九、關於一般關務法規之研釋擬議事項。十、關於各地區關稅局設置之研擬事項。十一、關於關務之其他事項。」

條文之闡釋，而具有法規創設之效力，甚至創設法律所無之限制，逾越函釋容許之範圍，亦與租稅法律主義有違。

六、系爭函釋違反法律優位原則

系爭函釋之合憲與否，除須檢驗其是否為主管機關於職權範圍內適用之法律條文，本於法定職權就相關規定予以闡釋，如係秉持憲法原則及相關之立法意旨，遵守一般法律解釋方法為之外，尤須審查其內容是否牴觸上位法規範（法律及法律一般原則）之意旨，即所謂法律優位原則。

所謂「法律」者，除立法院通過、總統公布者外（憲法第170條），在憲法的規範體系中，與此「形式意義之法律」具有相同位階及效力者，至少尚有緊急命令及條約二種。憲法所稱「條約」，依據司法院釋字第329號解釋之意旨，係指「中華民國與其他國家或國際組織所締結之國際書面協定，包括用條約或公約之名稱，或用協定等名稱而其內容直接涉及國家重要事項或人民之權利義務且具有法律上效力者而言。其中名稱為條約或公約或用協定等名稱而附有批准條款者，當然應送立法院審議，其餘國際書面協定，除經法律授權或事先經立法院同意簽訂，或其內容與國內法律相同者外，亦應送立法院審議。」由此可知，國際書面協定，不問是否使用條約或公約之名稱，其內容直接涉及國家重要事項或人民之權利義務，且經立法院審議通過者，即具有法律之效力。

就關稅之課徵而言，我國係以具法律位階之「海關進口稅則」為之，立法院並未授權行政機關訂定相關稅則。換言之，關稅之課徵屬於「國會保留」事項。海關進口稅則之內容除總則、解釋準則、稅則號別、貨物名稱外，並包含具有條約性質之HS註解，顯示國際法暨國際條約為判定關稅課徵項目的重要準據。

如前所述，WTO於1997年3月26日就資訊科技產品降稅方案召開總結會議，除通過39個參與國（包括我國）提交之關稅減讓清單外，並通過採認「資訊科技產品貿易部長宣言之執行」文件。該文

件經1997年4月14日WTO貨品貿易理事會採認，成為WTO之法律文件。依據該文件，具WTO會員身分之參與國將於完成其國內批准及稅則修正程序後，依據GATT第28條進行該國GATT關稅減讓表之修正，透過GATT第2條規定，對該國發生國際法上之拘束力，故應屬一種國際協定¹¹³。ITA於1997年5月8日提經行政院第2526次會議，決議：「通過，送請立法院審議」，並於1997年5月13日經立法院審議通過，決議內容如下：「我國參與世界貿易組織(WTO)『資訊科技產品貿易部長宣言之執行』法律文件暨附件案，予以同意¹¹⁴。」根據司法院釋字第329號解釋之意旨，ITA應屬具有法律效力之國際書面協定，具有法律之位階。

關於液晶顯示器應否課徵關稅之爭議，緣於液晶顯示器用途之多元性，即其主要以電腦螢幕與電視機兩類為主軸。電腦螢幕屬於ITA產品零關稅項目；但電視機則非屬ITA項目，問題是：兼具電視機與電腦螢幕雙重功能的液晶顯示器，是否屬於ITA產品，爰生爭議。依據ITA協定附件所列項目，液晶顯示器產品應適用零關稅待遇，但液晶顯示器若內裝數位視訊介面，因可接收數位影像而兼具電視機的功能。

歐盟於簽訂ITA後，曾制定與上開我國財政部函釋見解相似之關稅法令，將大型液晶顯示器（19吋以上螢幕）歸列為稅則號別第8528節下「其它彩色影像監視器」而課徵14%的進口關稅。歐盟認為液晶顯示器若加裝數位視訊介面，應屬電視機功能，故無法提供ITA免關稅之貿易待遇。我國、美國及日本認歐盟此一認定標準違反ITA，而向WTO提出申訴案件。WTO爭端解決小組於2010年8月16日作成裁決，認定歐盟將具DVI端子之液晶顯示器認定屬稅則號別8528節之產品並適用該節關稅稅率已違反ITA，而歐盟對WTO裁決並未上訴，且已於2011年1月6日承諾我國、美國及日本將於同年

113 立法院公報，86卷39期，頁43（1997年）。

114 立法院公報（註113），頁43。

7月1日起，依ITA對上開具DVI端子之液晶顯示器施以「零關稅」。換言之，在ITA的規範框架下，液晶顯示器屬於零關稅之資訊科技產品。

系爭函釋與歐盟就液晶顯示器所承諾關稅減讓之描述相同，系爭函釋將液晶顯示器歸列為應課徵之資訊科技產品，亦屬違反ITA之規定，ITA既具有國內法之法律效力，則系爭函釋亦因違反法律優位原則而構成違憲。

七、小結

綜據上述，系爭函釋牴觸租稅法律主義及法律優位原則，構成違憲，茲將理由歸整如下：

（一）我國關稅之課徵，係依立法院制定公布之「海關進口稅則」（法律位階）為之，立法機關並未授權行政機關訂定相關規範。

（二）海關進口稅則「總則」明定，關稅之課徵參據「國際商品統一分類制度（HS）註解」及其他有關文件辦理，故國際條約或協定亦構成我國關稅課徵法源之一環，國際法暨國際條約為判定關稅課徵項目之重要準據。

（三）ITA將其所揭示的資訊科技產品貿易自由化目標納入WTO關稅減讓表，成為關稅承諾的一環，受GATT有關關稅減讓之規範，對於WTO會員具有法律上之拘束力，我國亦不例外。

（四）關稅之課徵，尤其海關稅則的研訂，其主管機關在中央應為財政部，而非關稅總局。又觀諸財政部關稅總局組織條例第2條規定，財政部關稅總局所掌理的事項，亦不包括關稅稅則之解釋與適用。關稅總局之系爭函釋非「主管機關」於職權範圍內適用之法律條文，本於「法定職權」就相關規定所為之闡釋，其作為課徵關稅之依據，與租稅法律主義之意旨不無相違。

（五）系爭函釋之內容，係有關液晶（電漿）顯示器之如何歸列稅則號別，亦即系爭貨品具有DVI端子，可支援高解析度電視（HDTV），為數位或高畫質多媒體顯示器，宜歸列稅則號別第

8528.12.90號。系爭函釋將原本零關稅之「液晶（電漿）顯示器」歸列為應課關稅之「電視」，系爭函釋內容已非單純法律條文之闡釋，而具有法規創設之效力，甚至創設法律所無之限制，逾越函釋容許之範圍，亦與租稅法律主義有違。

（六）關稅之課徵，我國係以具法律位階之「海關進口稅則」為之，屬於「國會保留」事項。海關進口稅則之內容除總則、解釋準則、稅則號別、貨物名稱外，並包含具有條約性質之HS註解，顯示國際法暨國際條約為判定關稅課徵項目的重要準據。ITA於1997年5月8日提經行政院第2526次會議決議通過，根據司法院釋字第329號解釋之意旨，ITA應屬具有法律效力之國際書面協定，具有法律之位階。

（七）歐盟於簽訂ITA後，曾制定與上開我國財政部函釋見解相似之關稅法令，將大型液晶顯示器（19吋以上螢幕）歸列為稅則號別第8528節下「其它彩色影像監視器」而課徵14%的進口關稅。我國、美國及日本認歐盟此一認定標準違反ITA，而向WTO提出申訴案件。WTO爭端解決小組於2010年8月16日作成裁決，認定歐盟將具DVI端子之液晶顯示器認定屬稅則號別8528節之產品並適用該節關稅稅率已違反ITA，故在ITA的規範框架下，液晶顯示器屬於零關稅之資訊科技產品。

（八）系爭函釋與歐盟就液晶顯示器所承諾關稅減讓之描述相同，系爭函釋將液晶顯示器歸列為應課徵之資訊科技產品，亦屬違反ITA之規定，ITA既具有國內法之法律效力，則系爭函釋亦因違反法律優位原則而構成違憲。

柒、總結綜論：臺灣法律人的國際視野與法律思維

國際條約與憲法解釋之關係，從法效力與法位階的角度切入，

問題多端，層面複雜，自非單篇論文所能詳析窮究，本文只是此一議題深度探索的開始。謹就初步研究心得，擇要整理如下，以供參考：

一、國際條約作為一種「法源」，牽涉國際法的法源與國內法的法源兩種不同層次的問題。在國際法的層次，條約的定義、名稱、訂定程序、生效要件等，悉依國際規範與司法實踐，屬於國際法上法源問題；相對而言，國際法（條約）是否及如何作為國內法的法源，各國可保有自己的觀點或立場，必須作「內國法（特別是憲法）取向」的思考與探討。

二、國際條約是否成為國內法的法源，其問題之探討須分辨六個課題：（一）國際條約是否發生國際法上的效力？（二）國際條約是否及如何具有國內法的效力（條約法效力問題）？（三）國際條約成為國內法的憲法上要件（條約形式合憲性問題）？（四）國際條約成為內國法後，其效力是否高於其他內國法（條約法位階問題）？（五）國際條約成為內國法後，是否牴觸憲法（條約實質合憲性問題）？（六）國際條約能否直接透過法院的援引（尤其是憲法解釋）而成為內國法？其效力為何（憲法解釋之法源問題）？

三、截至目前為止，大法官雖數度在解釋中援引國際條約，惟其運用之道，或是補充違憲審查論理，或是依附於憲法條文，或僅作為參考依據，或屬法律規定意旨的延伸等，國際條約並未構成憲法解釋的直接法源。國際條約的內國法化，牽涉立法與司法之間的權力分際與法秩序的民主基底，於基本人權的增補或人民權利之限制，尤不能忽略民主正當性與權力分立的嚴肅課題，與臺灣的特殊國際地位無關。

四、司法院釋字第329號解釋針對憲法上條約概念，提出「條約等同法律」的說理模式，旨在闡釋凡直接涉及國家重要事項或人民權利義務之協定，不問名稱，皆須經立法院審議。解釋理由書末尾雖稱：「臺灣地區與大陸地區間訂定之協議，因非本解釋所稱之國際書面協定，應否送請立法院審議，不在本件解釋之範圍」，惟

兩岸協定只要直接涉及國家重要事項或人民權利義務者，仍應送請立法院審議，始符憲制。

五、國際條約內國法化的方式，基本上可以歸納為「接納」與「轉換」二種對立模式。司法院釋字第329號解釋雖未直接明示我國憲法採取何種立法模式，然從「所締結之條約，其位階同於法律」等語似乎可以反推我國係採「接納」模式。不過，司法院釋字第329號解釋之作成，係緣於兩岸協議是否應送立法院審議之爭議，故嚴格而言，該號解釋僅處理條約生效之正當憲法程序問題，至於條約如何成為國內法及其法效力，原非大法官作成該號解釋之所問，若以此斷言國際條約內國法化的模式業已因該號解釋而定調，似乎還言之過早。

六、在司法院釋字第329號解釋的基礎下，國際條約內國法化既未定於一尊，無特定模式，則國際條約在臺灣的內國法化模式，在憲法解釋上，仍屬開放性的問題。不過，從立法的實踐層面來看，還是可以歸納出以下4種基本模式：（一）立法程序模式。（二）成文化模式。（三）法律援引模式。（四）行政程序模式。其中法律直接以國際條約作為限制或處罰之法定要件之情形，是否違反法律明確性原則與處罰法定原則，不無疑問，值得探究。

七、國際條約的法位階定位有憲法、法律、命令三種選項。基於司法院釋字第329號解釋建立的「條約＝法律＝立法院審議」的模式，凡經立法院依法律制定程序審議通過的條約，具有法律的位階；相對而言，依「行政程序模式」而內國法化的條約，因欠缺立法程序的提階，僅具有相當於行政命令的位階。至於內國法化之國際條約是否有憲法的位階？本文認為，除非憲法特別規定或可以在憲法上找到立基點，僅以立法程序審議通過之國際條約不具有憲法位階。

八、屬於同一位階之國際條約或內國法規，如因內容相互衝突而生法適用之問題，基本上無涉「位階上下」關係的排序，而是「新法優於舊法」或「特別法優於普通法」之法規範效力的解釋

（選法）問題，故應回到一般法律解釋方法，進行法規意旨之解讀與適用。換言之，同一位階法規適用之優先順序的判定，並無放諸四海之一般性準則，除憲法明定外，更無所謂「國際法優於國內法」之原則，而須在各該法規脈絡中找到優先適用的準據，法律適用者（尤其是法院）且應提出何以優先適用之法律上理由。

最後須一言者，本文耙梳司法院大法官解釋，反覆論陳，確立「國際條約並未構成（我國）憲法解釋的直接法源」之基本規範命題，而未論及憲法解釋中援引的國際條約是否具有「國際習慣法」的規範效力，實乃作者希望先建立並確立「國際條約並未構成（我國）憲法解釋的直接法源」這項命題，而後也才有探討國際條約是否具有國際習慣法性質的可能。國際條約若不問是否內國法化，均可作為憲法解釋的直接法源，則國際條約是否具有國際習慣法性質的問題，將會失其意義，而此正是作者以為期期不可者。此外，作者一開始即將探討重點設定在「國際條約」，限於題旨，若要將觸角延伸到「國際習慣法」，勢將逸出本文的結構與論述脈絡。因為，憲法解釋中援引之國際條約是否具有「國際習慣法」規範效力的問題，必須先就「國際習慣法」的概念、發展、內涵及國際實務等面向作有系統的探討，才能準確無誤的判定。此一研究方向的開展，毋寧是作者接續本文之後的另一努力起點。

二十一世紀，在全球意識崛起下，國際聯繫不斷增強，國與國之間不僅在政治及經貿上的依存程度，與日遽增，憲政制度與人權理念亦呈交互影響、彼此連動之勢。身處全球化的時代，臺灣的法律人除了要有宏觀開闊的視野，更需要嚴謹縝密的法理思辨與分析能力，既不能無視於國際發展而渾然未覺，但也不能曲意盲從、隨聲附和。唯有如此，始能放眼世界、立足臺灣，走出屬於自己的憲法之路。

參考文獻

1. 中文部分

- Christian Starck著，李建良譯（2011），全民基本共識與憲法法院裁判權，收於：Christian Starck著，李建良、范文清、蔡宗珍、陳愛娥、楊子慧譯，法的起源，頁287-301，臺北：元照。
[Starck, Christian (2011), Nationaler Grundkonsens und Verfassungsgerichte, 收於：Christian Starck著，李建良、范文清、蔡宗珍、陳愛娥、楊子慧譯，法的起源，頁303-319，臺北：元照。]
- （2011），國際條約、憲法及法律中的社會權，收於：Christian Starck著，李建良、范文清、蔡宗珍、陳愛娥、楊子慧譯，法的起源，頁147-161，臺北：元照。[Starck, Christian (2011), Soziale Rechte in Verträgen, Verfassungen und Gesetzen, 收於：Christian Starck著，李建良、范文清、蔡宗珍、陳愛娥、楊子慧譯，法的起源，頁163-179，臺北：元照。]
- 王自雄（2010），人權兩公約之國內法化暨其施行法之實施——從國際法的內化與人權在我國憲政體制下之法律地位論起，台灣法學雜誌，164期，頁113-122。
- 王震宇（2011），WTO與區域貿易協定之締結與適用——從最高行政法院九十六年度判字第一九八六號判決談起，月旦法學雜誌，195期，頁269-287。
- 丘宏達（2006），現代國際法，修訂2版，臺北：三民。
- 朱楠（2010），推動「廢除死刑」之新契機——立法院通過兩國際人權公約施行法之實務分析，法學新論，19期，頁57-69。
- 李建良（2003），政治問題與司法審查——試評司法院大法官相關解釋，收於：憲法理論與實踐（一），2版，頁395-434，臺

北：新學林。

- （2003），基本權利理論體系之構成及其思考層次，收於：憲法理論與實踐（一），2版，頁51-100，臺北：新學林。
- （2003），論法規之司法審查與違憲宣告——德國聯邦憲法法院裁判之分析，收於：憲法理論與實踐（一），2版，頁435-529，臺北：新學林。
- （2009），學之逃、家之逃、法之逃？／釋字六六四號解釋，台灣法學雜誌，140期，頁151-164。
- （2010），自由、平等、尊嚴——人的尊嚴作為憲法價值的思想根源與基本課題，收於：人權思維的承與變，頁1-62，臺北：新學林。
- （2010），歐盟環境法的演進與發展——從經濟合作到環境共榮，法學叢刊，55卷4期，頁87-123。
- （2010），論基本權利之程序功能與程序基本權——德國理論的借鑑與反思，收於：人權思維的承與變，頁205-270，臺北：新學林。
- （2010），論憲法上保護義務與保護請求權之關係——以「不足禁止原則」的論證構造為中心，收於：人權思維的承與變，頁169-204，臺北：新學林。
- （2010），憲法人權清單改革芻議——「台灣基本權利憲章」草案初稿，收於：人權思維的承與變，頁545-599，臺北：新學林。
- （2011），人身自由的憲法保障與強制隔離的違憲審查——釋字第690號解釋，台灣法學雜誌，186期，頁60-79。
- （2011），依「辭海」審判的行政法院——北高行99年度ECFA公投判決的法治警訊，台灣法學雜誌，182期，頁63-80。
- （2012），依「憲法」審判的行政法院——最高行101年度ECFA公投判決的民主底蘊，台灣法學雜誌，209期，頁1-17。

- (2013), 行政法基本十講, 4版, 臺北: 元照。
- 林佳範 (2010), 論兩公約對憲法人權保障的補充——一個初步架構的探討, 全國律師雜誌, 14卷3期, 頁23-41。
- 俞寬賜 (2002), 國際法新論, 臺北: 啟英文化。
- 姜皇池 (2011), 國際公法導論, 2版, 臺北: 新學林。
- 徐揮彥 (2010), 從國際人權規範論我國對文化權之實踐, 收於: 社團法人台灣法學會編, 台灣法學新課題 (八), 頁181-256, 臺北: 元照。
- 翁國彥 (2010), 給一個說法——兩公約實施與律師執業的嶄新挑戰, 在野法潮, 5期, 頁10-11。
- 張文貞 (2009), 憲法與國際人權法的匯流——兼論我國大法官解釋之實踐, 收於: 廖福特編, 憲法解釋之理論與實務第六輯 (上冊), 頁223-272, 臺北: 中央研究院法律學研究所籌備處。
- 郭書琴 (2010), 多元家庭與家事事件之實體與程序——自「經濟社會文化權利國際公約」第10條的內國化談起, 收於: 社團法人台灣法學會編, 台灣法學新課題 (八), 頁69-100, 臺北: 元照。
- 陳怡凱 (2010), 國際人權公約之內國效力——以公民與政治權公約暨經濟社會文化權公約施行法為例, 收於: 社團法人台灣法學會編, 台灣法學新課題 (八), 頁27-68, 臺北: 元照。
- 陳長文 (2012), 國際法之回顧與展望——以超國界法律角度檢視, 月旦法學雜誌, 200期, 頁88-119。
- 陳清秀 (2011), 兩公約實踐與賦稅人權保障, 法令月刊, 62卷2期, 頁67-82。
- 陳新民 (1994), 論「社會基本權利」, 收於: 憲法基本權利之基本理論 (上冊), 4版, 頁95-128, 臺北: 元照。
- 陳耀祥 (2010), 從兩公約之批准論經濟管制與財產權之保障——以通訊傳播產業為例, 收於: 社團法人台灣法學會編, 台灣法

學新課題（八），頁151-180，臺北：元照。

黃文雄（2009），台灣如何成為人權大國？——簽署兩公約批准書之後的省思，司法改革雜誌，72期，頁54-55。

黃明展（2010），論兩公約施行法之生效對判決與執行死刑之影響（上），司法周刊，1492期，頁2-3。

——（2010），論兩公約施行法之生效對判決與執行死刑之影響（下），司法周刊，1493期，頁3。

黃昭元（2011），國際公法課程基準的檢討與反思：國際法法源、國際法與內國法關係，台灣法學雜誌，181期，頁61-66。

廖福特（2010），法院應否及如何適用公民與政治權利國際公約，台灣法學雜誌，163期，頁45-65。

——（2010），國際人權條約內國法化與地方自治體，台灣國際法季刊，7卷2期，頁75-116。

謝靜慧（2010），公民權利和政治權利公約暨經濟社會文化權利公約下之兒童及少年人權——以法官保留原則與專業法庭（院）之運作現況為中心，收於：社團法人台灣法學會編，台灣法學新課題（八），頁101-150，臺北：元照。

羅昌發（1994），立法機關參與締約過程之研究，收於：貿易關係之法律問題——國際經貿法研究（二），頁95-162，臺北：元照。

2. 外文部分

Dixon, Martin. 2007. *Textbook on International Law*. 6th ed. Oxford: Oxford University Press.

Hannikainen, Lauri. 1988. *Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law*. Helsinki: Finnish Lawyers' Pub. Co.

International Trade Center (ITC). 1999. *Trade in Information Technology Products and the WTO Agreements: Current Situation and Views of Exporters in Developing Countries*. Geneva: ITC.

- Jennings, Robert, and Arthur Watts. Eds. 1996. *Oppenheim's International Law, Vol. 1: Peace, Introduction & Part I*. 9th ed. London: Longmans.
- Kadelbach, Stefan. 2006. *Jus Cogens* and Obligations *Erga Omnes* and other Rules: The Identification of Fundamental Norms. Pp. 21-40 in *The Fundamental Rules of the International Legal Order: Jus Cogens and Obligations Erga Omnes*, edited by Christian Tomuschat and Jean-Marc Thouvenin. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Kelsen, Hans (1929), *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts*, Tübingen: Mohr.
- Nowak, John E., and Ronald D. Rotunda. 2010. *Constitutional Law*. 8th ed. St. Paul, Minn.: West.
- Öhlinger, Theo (2007), *Verfassungsrecht*, 7. Aufl., Wien: Facultas-WUV.
- Pellet, Alain. 2006. Article 38. Pp. 677-792 in *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary*, edited by Andreas Zimmermann, Karin Oellers-Frahm, Christian Tams and Christian Tomuschat. Oxford: Oxford University Press.
- Rigaux, François. 1998. Hans Kelsen on International Law. *European Journal of International Law* 9:325-343.
- Schweitzer, Michael (1995), *Staatsrecht III*, 5. Aufl., Heidelberg: C. F. Müller.
- Shelton, Dinah. 2011. Introduction. Pp. 1-32 in *International Law and Domestic Legal Systems, Incorporation, Transformation, and Persuasion*, edited by Dinah Shelton. Oxford: Oxford University Press.
- Starck, Christian (2010), in: v. Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), *Kommentar zum Grundgesetz*, Bd. 1, 6. Aufl., München: Franz Vahlen, Art. 2.

- Triepel, Heinrich (1899), *Völkerrecht und Landesrecht*, Leipzig: C. L. Hirschfeld.
- Wagner, Heinz (1964), *Monismus und Dualismus: Eine methodenkritische Betrachtung zum Theorienstreit*, AöR 89, S. 212-241.
- Wasescha, Luzius, and Markus Schlagenhof. 1998. Information Technology Agreement (ITA): Towards a New Area of Sectorial Market Liberalisation in WTO, *Aussenwirtschaft* 53:113-127.
- Wasilkowski, Andrzej. 1996. Monism and Dualism. Pp. 323-330 in *Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century: Essays in Honour of Krzysztof Skubiszewski*, edited by Jerzy Makarczyk. The Hague, Boston: Kluwer Law International.
- Wenzel, Max (1920), *Juristische Grundprobleme*, Berlin: F. Dümmler.
- Wright, Philip Quincy. 1915. *The Enforcement of International Law Through Municipal Law in the United States*. Unpublished Ph.D. thesis. University of Illinois at Urbana-Champaign, March. <https://ia601002.us.archive.org/33/items/enforcementofint00wrig/enforcementofint00wrig.pdf>.
- Zemanek, Karl. 2000. New Trends in the Enforcement of erga omnes Obligations. Pp. 1-52 in vol. 4 of *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, edited by Jochen A. Frowein and Rüdiger Wolfrum. London: Kluwer Law International.

附錄一：有關國際規範之司法院解釋（一）

釋字	爭點	國際規範名稱	解釋內容	備註
329	憲法上「條約」之意涵？何者應送立法院審議？	未援引	解釋文：「憲法所稱之條約係指中華民國與其他國家或國際組織所締結之國際書面協定，包括用條約或公約之名稱，或用協定等名稱而其內容直接涉及國家重要事項或人民之權利義務且具有法律上效力者而言。其中名稱為條約或公約或用協定等名稱而附有批准條款者，當然應送立法院審議，其餘國際書面協定，除經法律授權或事先經立法院同意簽訂，或其內容與國內法律相同者外，亦應送立法院審議。」	1. 定義憲法上條約之意涵。 2. 依憲法第38條、第58條第2項、第63條締結之條約，與法律同位階。
372	夫妻一方不檢致他方行為過當，非當然構成「不堪同居虐待」之判例違憲？	世界人權宣言	理由書第1段：「人格尊嚴之維護與人身安全之確保，乃世界人權宣言所揭示，並為我國憲法保障人民自由權利之基本理念。憲法增修條文第九條第五項規定：『國家應維護婦女之人格尊嚴，保障婦女之人身安全，消除性別歧視，促進兩性地位之實質平等』即在宣示上述理念。此一憲法意旨，於婚姻關係及家庭生活，亦有其適用，業經本院釋字第三六五號解釋釋示在案。」	1. 以國際規範作為憲法保障「人格尊嚴」之參證。 2. 以國際條約作為增補人權清單之依據。 3. 未明示國際規範內容。
392	刑訴法檢察官羈押權、提審法提審要件等規定違憲？	歐洲人權及基本自由保障公約 (European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)、公民及政治權利國際盟約、美洲人權公約、聯合國公民及	理由書第18段：「另一九五三年生效之歐洲人權及基本自由保障公約 (European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) 第五條第三項所規定之『依法執行司法權力之其他官吏』 (other officer authorized by law to exercise judicial power) 暨一九七六年生效之公民及政治權利國際盟約第九條第三項與一九七八年生效之美洲人權公約第七條第五項類同之規定，是否應包括檢察	1. 以國際條約作為解釋憲法規定意旨之依據。 2. 以國際司法裁判作為解釋國際條約之依據。

		政治權利國際盟約	官，亦即人民被逮捕拘禁後，其所應解送之處，是否僅限於『法官』？此雖各執一詞，然參以歐洲人權法院於一九八八年關於『包威爾斯』乙案之判決所稱，若法律將犯罪偵查與公訴提起之權授予同一官吏，縱其係獨立行使職權，其職務之中立性仍應受質疑，有違前開公約第五條第三項所指之『依法執行司法權力之其他官吏』之規定等語(G.Pauwels Case, Judgement of 26 May 1988, COUNCIL OF EUROPE YEARBOOK OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS, 148-150 (1988))，即不得賦予羈押人民之權，而我國之檢察官既為偵查之主體，且有行使公訴之權，是即令依據前述相關之國際公約，顯亦不應有刑事訴訟法上之羈押權；何況我國憲法第八條第二項既明定為『法院』如上，而此之所謂法院係指有獨立審判權之法官所構成之狹義法院，亦已述之如前，尤不宜執此『國際盟約』、『公約』之規定主張我國憲法第八條第二項前段所稱之法院亦應包括『依法執行司法權力之其他官吏』如檢察官在內。」	
428	郵政法等法規就掛號郵件補償之要件等規定違憲？	萬國郵政公約最後議定書 (Universal Postal Convention, Final Protocol)	理由書第3段：「……依郵政法第三條規定：『關於各類郵件或其事務，如國際郵政公約或協定有規定者，依其規定。但其規定如與本法相牴觸時，除國際郵件事務外，適用本法之規定。』一九九四年九月十四日於韓國漢城簽訂，於一九九六年一月一日起正式生效之萬國郵政公約最後議定書(Universal Postal Convention, Final Protocol)，即有與前開郵政規則相同之規定。我國雖	1. 以國際條約作為法律解釋適用之準據。 2. 強調國際條約為「國際間通郵之一般規範」。

			非此公約之締約國，仍可視之為國際間通郵之一般規範。該公約第三十五條第一項規定，掛號函件、保險函件及其他證明函件，凡經按照國內就同類函件所定規章之條件予以投遞者，郵局之責任即告終止。惟同條項第二款規定，收件人或郵件退回原局時之寄件人，於國內規章所許可之情況下，對於被竊或毀損郵件（向郵局）提出保留聲明者，郵局仍須負責。亦即依該公約之規定，各類郵件如經照章投遞而收件人於領取郵件時並未提出保留權利之聲明者，各郵局即無須負責。」	
549	勞保條例就勞保遺屬津貼受領之規定違憲？	未明文適用何條約，僅說明應參酌相關國際勞工公約	解釋文：「……惟為貫徹國家負生存照顧義務之憲法意旨，並兼顧養子女及其他遺屬確受被保險人生前扶養暨無謀生能力之事實，勞工保險條例第二十七條及第六十三條至第六十五條規定應於本解釋公布之日起二年內予以修正，並依前述解釋意旨就遺屬津貼等保險給付及與此相關事項，參酌有關國際勞工公約及社會安全如年金制度等通盤檢討設計。」	1. 以國際條約作為警告性解釋之依據。 2. 未明示國際規範內容。
578	勞基法課雇主負擔勞工退休金違憲？	未明文適用何條約，僅說明應參酌相關國際勞工公約	解釋文第3段：「……由相關機關根據我國憲法保障勞工之基本精神及國家對人民興辦之中小型經濟事業應扶助並保護其生存與發展之意旨，參酌有關國際勞工公約之規定，並衡量國家總體發展，通盤檢討，併此指明。」	1. 以國際條約作為警告性解釋之依據。 2. 未明示國際規範內容。
582	共同被告不利己陳述得為他共同被告罪證之判例違憲？	歐洲人權及基本自由保障公約 (European Convention for the Protection of Human	理由書第2段：「西元一九五〇年十一月四日簽署、一九五三年九月三日生效之歐洲人權及基本自由保障公約(European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)第六條第三	1. 以國際條約作為解釋憲法規定意旨之依據以國際規範作為憲法保障「刑事被告享

		Rights and Fundamental Freedoms) 公民及政治權利國際公約 (International Covenant on Civil and Political Rights)	項第四款及聯合國於一九六六年十二月十六日通過、一九七六年三月二十三日生效之公民及政治權利國際公約 (International Covenant on Civil and Political Rights) 第十四條第三項第五款，亦均規定：凡受刑事控訴者，均享有詰問對其不利之證人的最低限度保障。足見刑事被告享有詰問證人之權利，乃具普世價值之基本人權。在我國憲法上，不但為第十六條之訴訟基本權所保障，且屬第八條第一項規定『非由法院依法定程序不得審問處罰』、對人民身體自由所保障之正當法律程序之一種權利（本院釋字第三八四號解釋參照）。」	有詰問證人之權利」的參證。 2. 以國際條約作為增補基本人權之依據。 3. 強調「普世價值之基本人權」的觀念。
587	民法及判例禁止子女提否認生父之訴違憲？	兒童權利公約 (Convention on the Rights of the Child) 第7條第1項	理由書第1段：「子女有獲知其血統來源之權利，為聯合國一九九〇年九月三日生效之兒童權利公約 (Convention on the Rights of the Child) 第七條第一項所揭禁；確定父子真實身分關係，攸關子女之人格權，應受憲法第二十二條所保障。」 「……為貫徹前開憲法意旨，應肯認確定真實血統關係，乃子女固有之權利，外國立法例如德國舊民法原已規定特殊情形子女得以補充地位提出否認生父之訴，一九九八年德國民法修正時配合聯合國兒童權利公約之規定，更明定子女自己亦得提起此項訴訟（德國民法第一六〇〇條、第一六〇〇a條、第一六〇〇b條參照），瑞士民法第二五六條、第二五六c條亦有類似規定，足供參考。」	1. 以國際規範作為憲法保障「獲知血統來源之權利」的參證。 2. 以國際條約作為增補基本人權之依據。
591	仲裁法未將仲裁判斷理由予	聯合國國際商務仲裁法範本	理由書第3段：「聯合國大會決議通過，並推薦各國採用之一九八五年	1. 以國際規範作為審查標準之

	盾明定為得提撤銷訴訟之事由，是否違憲？	(UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration) 規定	聯合國國際商務仲裁法範本 (UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration) 規定，當事人聲請法院撤銷仲裁判斷之事由，除『仲裁判斷違反本國之公共秩序者』，涉及實體事項者外，其餘諸如仲裁協議之當事人不適格、仲裁協議無效、仲裁人之選定或仲裁程序之進行未經合法通知或有其他原因致使當事人未獲陳述之機會、仲裁判斷逾越仲裁協議之範圍、仲裁庭之組成或仲裁程序抵觸仲裁協議或仲裁法，及爭議事件不具仲裁容許性等，均為有關程序之重大瑕疵（第三十四條，另第五條參照）。上開規定之目的，在於避免司法機關動輒對仲裁判斷之實質問題為全面之審理，俾維護仲裁制度之自主原則並發揮迅速處理爭議之功能。」	依據。 2. 以國際規範作為肯認系爭法律規定合憲之理由。
623	兒童及少年性交易防制條例第29條違憲？	兒童權利公約第19條及第34條	理由書第3段：「兒童及少年之心智發展未臻成熟，與其為性交易行為，係對兒童及少年之性剝削。性剝削之經驗，往往對兒童及少年產生永久且難以平復之心理上或生理上傷害，對社會亦有深遠之負面影響。從而，保護兒童及少年免於從事任何非法之性活動，乃普世價值之基本人權（聯合國於西元一九八九年十一月二十日通過、一九九〇年九月二日生效之兒童權利公約第十九條及第三十四條參照），為重大公益，國家應有採取適當管制措施之義務，以保護兒童及少年之身心健康與健全成長。兒童及少年性交易防制條例第1條規定：『為防制、消弭以兒童少年為性交易對象事件，特制定本條例』，目的洵屬正當。」	1. 以國際條約作為增補基本人權之依據？ 2. 以國際條約作為審查標準之依據。 3. 強調「普世價值之基本人權」的觀念。 4. 以國際條約建構國家保護義務，並肯認系爭規定之目的正當。

			理由書第5段：「保護兒童及少年免於因任何非法之性活動而遭致性剝削，乃普世價值之基本人權，為國家應以法律保護之重要法益，上開規定以刑罰為手段，取締促使人為性交易之訊息，從根本消弭對於兒童少年之性剝削，自為達成防制、消弭以兒童少年為性交易對象事件之立法目的之有效手段；又衡諸保護兒童及少年免於從事任何非法之性活動之重大公益，相對於法律對於提供非法之性交易訊息者權益所為之限制，則上開規定以刑罰為手段，並以傳布以兒童少年性交易或促使其為性交易為內容之訊息，或向未滿十八歲之兒童少年或不特定年齡之多數人傳布足以促使一般人為性交易之訊息為其適用範圍，以達防制、消弭以兒童少年為性交易對象事件之立法目的，尚未逾越必要合理之範圍，與憲法第二十三條規定之比例原則，並無抵觸。」	
678	電信法就無線電頻率使用應經許可，違者處刑罰並沒收器材等規定違憲？	聯合國所屬國際電信聯合會 (International Telecommunication Union) 之無線電規則 (Radio Regulations) 第18條，及聯合國海洋法公約 (United Nations Convention on the Law of the Sea) 第109條	理由書第3段：「無線電波頻率屬於全體國民之公共資源，為避免無線電波頻率之使用互相干擾、確保頻率和諧使用之效率，以維護使用電波之秩序及公共資源，增進重要之公共利益，政府自應妥慎管理。立法機關衡酌上情，乃於電信法第四十八條第一項前段規定，人民使用無線電波頻率，採行事前許可制，其立法目的尚屬正當。上開規定固限制人民使用無線電波頻率之通訊傳播自由，惟為保障合法使用者之權益，防範發生妨害性干擾，並維護無線電波使用秩序及無線電通信安全（聯合國所屬國際電信聯合會 (International Telecommunication Union) 之無線電規則 (Radio	1. 以國際條約作為審查標準之依據。 2. 以國際條約肯認系爭規定之目的正當、手段必要，且有助於目的之達成（合乎比例原則）。

			Regulations)第十八條，及聯合國海洋法公約(United Nations Convention on the Law of the Sea)第一〇九條參照)。兩相權衡，該條項規定之限制手段自有必要，且有助於上開目的之達成，與比例原則尚無牴觸，並無違憲法第十一條保障人民言論自由之意旨。」	
689	社會秩序維護法第89條第2款規定，使新聞採訪者之跟追行為受到限制，違憲？	世界人權宣言、公民與政治權利國際公約及歐洲人權公約規定	理由書第3段：「……且依世界人權宣言、公民與政治權利國際公約及歐洲人權公約規定，私人生活領域有不受他人任意干涉之權利，國家負有積極的保護義務，應提供法律保護，以免個人之私人生活領域遭受不當干涉，是系爭規定之目的殊屬正當。」	1. 以國際條約作為審查標準之依據。 2. 以國際條約建構國家保護義務，並肯認系爭規定之目的正當。 3. 未明示國際規範內容。
690	91.1.30傳染病防治法第37條第1項所定「必要之處置」包含強制隔離在內，違憲？	世界衛生組織(World Health Organization, WHO)之意見	理由書第4段「……又雖系爭規定並未就強制隔離之期間詳為規定，惟必要處置期間之長短，事涉傳染病之病源、傳染途徑、潛伏期及其傷害之嚴重性，自應由該管主管機關衡酌各種情況，並參酌世界衛生組織(World Health Organization, WHO)之意見而為符合比例原則之決定（以前述SARS疫情為例，該管主管機關臺北市政府於衡量當時世界各國對該疫情尚無處理之經驗、醫界處理之方法亦無定論，及該疫情已造成國內外民眾嚴重之傷亡等情況，暨參酌世界衛生組織之意見，因而決定受隔離處分者之隔離期間為十四日，見臺北市政府衛生局一〇〇年一月十八日北市衛疾字第〇九九四五六八六四〇〇號函）。」	1. 以國際組織之意見作為法律適用之參酌依據。 2. 未涉及國際條約之抽象規範問題。 3. 增加法律解釋、適用之個案判斷準據。 4. 國際組織之個案見解與內國法律解釋、適用之個案認定問題。

資料來源：作者製表（爭點部分，取自司法院大法官網站之大法官解釋）

附錄二：有關國際規範之司法院解釋（二）

運用國際條約之模式	釋字
以國際條約作為增補人權的參據	釋字第372、582、587、623號解釋
以國際條約作為審查標準的參據	釋字第591、623、678、689號解釋
以國際條約作為宣告方式的參據	釋字第549、578號解釋
以國際條約作為解釋憲法的參據	釋字第392、582號解釋
以國際條約作為解釋法律的參據	釋字第428、690號解釋

資料來源：作者製表

附錄三：援引國際條約之法律規定（一）

法律名稱	條文內容	援引模式
土地法第 18 條	外國人在中華民國取得或設定土地權利，以依條約或其本國法律，中華民國人民得在該國享受同樣權利者為限。	1. 平等互惠條款。
公平交易法第 47 條	未經認許之外國法人或團體，就本法規定事項得為告訴、自訴或提起民事訴訟。但以依條約或其本國法令、慣例，中華民國人或團體得在該國享受同等權利者為限；其由團體或機構互訂保護之協議，經中央主管機關核准者亦同。	1. 平等互惠條款。
引渡法第 1 條	引渡依條約，無條約或條約無規定者，依本法之規定。	2. 涉及外國人在本國、本國人在外國或國際事務之規定
引渡法第 6 條	數國對同一人犯請求引渡，而依條約或本法應為允許時，依左列順序定其解交之國： 一、依條約提出請求引渡之國。 二、數請求國均為締約國或均非締約國時，解交於犯罪行為地國。 三、數請求國均為締約國或均非締約國，而無一國為犯罪行為地國時，解交於犯人所屬國。 四、數締約國或數非締約國請求引渡，而指控之罪名不同者，解交於最重犯罪行為地國；其法定刑度輕重相同者，解交於首先正式請求引渡之國。	2. 涉及外國人在本國、本國人在外國或國際事務之規定
文化資產保存法第 25 條	政府機關辦理古蹟、歷史建築及聚落之修復或再利用有關之採購，應依中央主管機關訂定之採購辦法辦理，不受政府採購法限制。但不得違反我國締結之條約及協定。	4. 補充性規定。
民用航空法第 47 條之 3	航空器載運之乘客、行李、貨物及郵件，未經航空警察局安全檢查者，不得進入航空器。但有下列情形之一者，不在此限： 一、依條約、協定及國際公約規定，不需安全檢查。 二、由保安控管人依核定之航空保安計畫實施保安控管之貨物。	2. 涉及外國人在本國、本國人在外國或國際事務之規定。 3. 例外或除外規定。

	三、其他經航空警察局依規定核准。 前項安全檢查之方式，由航空警察局公告之。 航空器所有人或使用人不得載運未依第一項規定接受安全檢查之乘客、行李、貨物及郵件。 航空器上工作人員與其所攜帶及託運之行李、物品於進入航空器前，應接受航空警察局之安全檢查，拒絕接受檢查者，不得進入航空器。 航空器所有人或使用人對航空器負有航空保安之責。 前五項規定，於外籍航空器所有人或使用人，適用之。	
民用航空法第 72 條	民用航空運輸業得報請民航局核轉交通部許可後，設立航空貨物集散站，自辦其自營之航空器所承運貨物之集散業務。 前項規定於依條約、協定或基於平等互惠原則，以同樣權利給與中華民國民用航空運輸業在其國內經營航空貨物集散站經營業務之外籍民用航空運輸業，準用之。	1. 平等互惠條款。
民用航空法第 74 條之 1	航空站地勤業應為公司組織，並應合於下列之規定： 一、無限公司之股東全體為中華民國國民。 二、有限公司之資本總額逾百分之五十為中華民國之國民、法人所有，其代表公司之董事二分之一以上為中華民國國民。 三、兩合公司之無限責任股東全體為中華民國國民。 四、股份有限公司之股份總數逾百分之五十為中華民國之國民、法人所有，其董事長及董事逾半數為中華民國國民，且單一外國人持有之股份總數不得逾百分之二十五。 股份有限公司發行股票者，其股票應記名。 航空站地勤業因條約或協定另有規定者，不受前二項規定之限制。	3. 例外或除外規定。
民用航空法第 75 條	民用航空運輸業得報請民航局核轉交通部許可後，兼營航空站地勤業或自辦航空站地勤業務。 前項規定，於依條約、協定或基於平等互惠原則，以同樣權利給與中華民國民用航空運輸業	1. 平等互惠條款

	者在其國內經營航空站地勤業務之外籍民用航空運輸業，準用之。 前二項經許可兼營航空站地勤業或自辦航空站地勤業務者，交通部為維持航空站之安全及營運秩序，得限制其一部或全部之營業。	
民用航空法第 78 條	外籍航空器，非經交通部許可，不得飛越中華民國領域或在中華民國境內起降。但條約或協定另有規定者，從其規定。 民航局得派員檢查在中華民國境內起降之外籍航空器之各項人員、設備及其有關文件。機長不得拒絕、規避或妨礙。 第一項外籍航空器飛越中華民國領域或在中華民國境內起降申請許可之程序、應備文件、撤銷、廢止許可或禁止飛航之事由及其他應遵行事項之規則，由交通部定之。	2. 涉及外國人在本國、本國人在外國或國際事務之規定
民用航空法第 80 條	外籍民用航空運輸業，依條約或協定，或基於平等互惠原則，其航空器定期飛航於中華民國境內之一地與境外一地之間，按有償或無償方式載運客貨、郵件，應先向民航局申請核發航線證書。	1. 平等互惠條款
民用航空法第 115 條	外籍民用航空運輸業，違反本法或依本法所發布之命令或違反條約或協定之規定者，除依本法處罰外，民航局得撤銷其發給之航線證書或暫停其營業之全部或一部。	5. 限制或處罰之法定要件。
民防法第 29 條	本法對於在中華民國領域內有住所、居所或財產之外國人或無國籍人及有事務所或財產之外國法人、機關（構）、學校、團體、公司、廠場，適用之。但條約、協定或其他法律另有規定者，從其規定。	3. 例外或除外規定。
民事訴訟法第 108 條	對於外國人准予訴訟救助，以依條約、協定或其本國法令或慣例，中華民國人在其國得受訴訟救助者為限。	1. 平等互惠條款
刑事補償法第 36 條	本法於外國人準用之。但以依國際條約或該外國人之本國法律，中華民國人民得享同一權利者為限。	1. 平等互惠條款
行政法人法第 37 條	行政法人辦理採購，應本公開、公平之原則，並應依我國締結簽訂條約或協定之規定。	4. 補充性規定。

	前項採購，除符合政府採購法第四條所定情形，應依該規定辦理外，不適用該法之規定。前項應依政府採購法第四條規定辦理之採購，於其他法律另有規定者，從其規定。	
所得稅法第 124 條	凡中華民國與其他國家所簽訂之所得稅協定中另有特別規定者，依其規定。	6. 特別法之規定。
放射性物料管理法第 7 條	主管機關得依我國與外國或國際原子能組織所簽訂之核子保防相關條約或協定，督同外國或國際原子能組織所派之檢查員執行各項檢查及偵測，並要求經營者檢送指定之資料；所需繳交國際原子能組織之核子保防檢查費由設施經營者負擔。 前項核子保防作業之辦法，由主管機關定之。	2. 涉及外國人在本國、本國人在外國或國際事務之規定
律師法第 47 條之 10	外國法事務律師不得僱用中華民國律師，並不得與中華民國律師合夥經營律事務所。但為履行國際條約義務，外國法事務律師向法務部申請許可者，得僱用中華民國律師或與中華民國律師合夥經營法律事務所；其許可條件、程序及其他應遵行事項之管理辦法，由法務部定之。	2. 涉及外國人在本國、本國人在外國或國際事務之規定
政府採購法第 43 條	機關辦理採購，除我國締結之條約或協定另有禁止規定者外，得採行下列措施之一，並應載明於招標文件中： 一、要求投標廠商採購國內貨品比率、技術移轉、投資、協助外銷或其他類似條件，作為採購評選之項目，其比率不得逾三分之一。 二、外國廠商為最低標，且其標價符合第五十二條規定之決標原則者，得以該標價優先決標予國內廠商。	6. 特別法之規定。
政府採購法第 44 條	機關辦理特定之採購，除我國締結之條約或協定另有禁止規定者外，得對國內產製價值達百分之五十之財物或國內供應之工程、勞務，於外國廠商為最低標，且其標價符合第五十二條規定之決標原則時，以高於該標價一定比率以內之價格，優先決標予國內廠商。 前項措施之採行，以合於就業或產業發展政策	6. 特別法之規定。

	者為限，且一定比率不得逾百分之三，優惠期限不得逾五年；其適用範圍、優惠比率及實施辦法，由主管機關會同相關目的事業主管機關定之。	
政府採購法第 75 條	廠商對於機關辦理採購，認為違反法令或我國所締結之條約、協定（以下合稱法令），致損害其權利或利益者，得於下列期限內，以書面向招標機關提出異議： 一、對招標文件規定提出異議者，為自公告或邀標之次日起等標期之四分之一，其尾數不足一日者，以一日計。但不得少於十日。 二、對招標文件規定之釋疑、後續說明、變更或補充提出異議者，為接獲機關通知或機關公告之次日起十日。 三、對採購之過程、結果提出異議者，為接獲機關通知或機關公告之次日起十日。其過程或結果未經通知或公告者，為知悉或可得而知悉之次日起十日。但至遲不得逾決標日之次日起十五日。 招標機關應自收受異議之次日起十五日內為適當之處理，並將處理結果以書面通知提出異議之廠商。其處理結果涉及變更或補充招標文件內容者，除選擇性招標之規格標與價格標及限制性招標應以書面通知各廠商外，應另行公告，並視需要延長等標期。	7. 行政程序規範。
政府採購法第 105 條	機關辦理下列採購，得不適用本法招標、決標之規定。 一、國家遇有戰爭、天然災害、瘟疫或財政經濟上有重大變故，需緊急處置之採購事項。 二、人民之生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難，需緊急處置之採購事項。 三、公務機關間財物或勞務之取得，經雙方直屬上級機關核准者。 四、依條約或協定向國際組織、外國政府或其授權機構辦理之採購，其招標、決標另有特別規定者。	2. 涉及外國人在本國、本國人在外國或國際事務之規定。 3. 例外或除外規定。

	前項之採購，有另定處理辦法予以規範之必要者，其辦法由主管機關定之。	
政府採購法第106條	駐國外機構辦理或受託辦理之採購，因應駐在地國情或實地作業限制，且不違背我國締結之條約或協定者，得不適用下列各款規定。但第二款至第四款之事項，應於招標文件中明定其處理方式。 一、第二十七條刊登政府採購公報。 二、第三十條押標金及保證金。 三、第五十三條第一項及第五十四條第一項優先減價及比減價格規定。 四、第六章異議及申訴。 前項採購屬查核金額以上者，事後應敘明原由，檢附相關文件送上級機關備查。	2. 涉及外國人在本國、本國人在外國或國際事務之規定。
洗錢防制法第9條	檢察官於偵查中，有事實足認被告利用帳戶、匯款、通貨或其他支付工具犯第十一條之罪者，得聲請該管法院指定六個月以內之期間，對該筆交易之財產為禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他必要處分之命令。其情況急迫，有相當理由足認非立即為上開命令，不能保全得沒收之財產或證據者，檢察官得逕命執行之。但應於執行後三日內，聲請法院補發命令。法院如不於三日內補發或檢察官未於執行後三日內聲請法院補發命令者，應即停止執行。 前項禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他必要處分之命令，法官於審判中得依職權為之。 前二項命令，應以書面為之，並準用刑事訴訟法第一百二十八條規定。 第一項之指定期間如有繼續延長之必要者，檢察官應檢附具體理由，至遲於期間屆滿之前五日聲請該管法院裁定。但延長期間不得逾六個月，並以延長一次為限。 對於外國政府、機構或國際組織依第十六條所簽訂之條約或協定或基於互惠原則請求我國協助之案件，如所涉之犯罪行為符合第三條所列之罪，雖非在我國偵查或審判中者，亦得準用	1. 平等互惠條款。

	第一項、前項規定。 對第一項、第二項之命令、前項之裁定不服者，準用刑事訴訟法第四編抗告之規定。	
洗錢防制法第 14 條	犯第十一條之罪者，其因犯罪所得財物或財產上利益，除應發還被害人或第三人者外，不問屬於犯人與否，沒收之。如全部或一部不能沒收時，追徵其價額或以其財產抵償之。 為保全前項財物或財產上利益追徵或財產之抵償，必要時，得酌量扣押其財產。 對於外國政府、機構或國際組織依第十六條所簽訂之條約或協定或基於互惠原則，請求我國協助之案件，如所涉之犯罪行為符第三條所列之罪，雖非我國偵查或審判中者，亦得準用前二項之規定。	1. 平等互惠條款。
洗錢防制法第 15 條	依前條第一項沒收之犯罪所得財物或財產上利益為現金或有價證券以外之財物者，得由法務部撥交檢察機關、司法警察機關或其他協助查緝洗錢犯罪之機關作公務上使用。 外國政府、機構或國際組織依第十六條所簽訂之條約或協定或基於互惠原則協助我國執行沒收犯罪所得財物或財產上利益者，法務部得將該沒收財產之全部或一部撥交該外國政府、機構或國際組織。 前二項沒收財產之管理、撥交及使用辦法，由行政院定之。	1. 平等互惠條款。
洗錢防制法第 16 條	為防制國際洗錢活動，政府依互惠原則，得與外國政府、機構或國際組織簽訂防制洗錢之合作條約或其他國際書面協定。 對於外國政府、機構或國際組織請求我國協助之案件，除條約或協定另有規定者外，得基於互惠原則，提供第七條、第八條、第十條受理申報或通報之資料及其調查結果。	1. 平等互惠條款。 2. 涉及外國人在本國、本國人在外國或國際事務之規定。
科學技術基本法第 6 條	政府補助、委託、出資或公立研究機關（構）依法編列科學技術研究發展預算所進行之科學技術研究發展，應依評選或審查之方式決定對象，評選或審查應附理由。其所獲得之智慧財產權及成果，得將全部或一部歸屬於執行研究	6. 特別法之規定。

	發展之單位所有或授權使用，不受國有財產法之限制。 前項智慧財產權及成果，歸屬於公立學校、公立機關（構）或公營事業者，其保管、使用、收益及處分不受國有財產法第十一條、第十三條、第十四條、第二十條、第二十五條、第二十八條、第二十九條、第三十三條、第三十五條、第三十六條、第五十七條、第五十八條、第六十條及第六十四條規定之限制。 前二項智慧財產權及成果之歸屬及運用，應依公平及效益原則，參酌資本與勞務之比例及貢獻，科學技術研究發展成果之性質、運用潛力、社會公益、國家安全及對市場之影響，就其目的、要件、期限、範圍、全部或一部之比例、登記、管理、收益分配、迴避及其相關資訊之揭露、資助機關介入授權第三人實施或收歸國有及相關程序等事項之辦法，由行政院統籌規劃訂定；各主管機關並得訂定相關法規命令施行之。 公立學校、公立研究機關（構）、法人或團體接受第一項政府補助、委託或公立研究機關（構）依法編列之科學技術研究發展預算辦理採購，除我國締結之條約或協定另有規定者外，不適用政府採購法之規定。但應受補助、委託或主管機關之監督；其監督管理辦法，由中央科技主管機關定之。	
軍事徵用法第 14 條	年滿二十歲未逾四十五歲身體健全之男子，為軍事上必需之服務，得徵用之。 前項規定於左列之人不適用之： 一、正在服兵役中。 二、公務員。 三、外國使館、領事館所屬人員及依條約應免徵者。 四、學校之教職員及在學校肄業者。 五、獨自經營農、工、商業，而因徵用其所營事業無法維持者。 六、因被徵用家屬之生活難以維持者。 七、職務上對於所在地之民眾有重大貢獻，而為該地民眾所不可缺少者。	3. 例外或除外規定。

香港澳門關係條例第 36 條	香港或澳門居民或法人之著作，合於下列情形之一者，在臺灣地區得依著作權法享有著作權： 一、於臺灣地區首次發行，或於臺灣地區外首次發行後三十日內在臺灣地區發行者。但以香港或澳門對臺灣地區人民或法人之著作，在相同情形下，亦予保護且經查證屬實者為限。 二、依條約、協定、協議或香港、澳門之法令或慣例，臺灣地區人民或法人之著作得在香港或澳門享有著作權者。	1. 平等互惠條款
香港澳門關係條例第 37 條	香港或澳門居民、法人、團體或其他機構在臺灣地區申請專利、商標或其他工業財產權之註冊或相關程序時，有下列情形之一者，應予受理： 一、香港或澳門與臺灣地區共同參加保護專利、商標或其他工業財產權之國際條約或協定。 二、香港或澳門與臺灣地區簽訂雙邊相互保護專利、商標或其他工業財產權之協議或由團體、機構互訂經主管機關核准之保護專利、商標或其他工業財產權之協議。 三、香港或澳門對臺灣地區人民、法人、團體或其他機構申請專利、商標或其他工業財產權之註冊或相關程序予以受理時。 香港或澳門對臺灣地區人民、法人、團體或其他機構之專利、商標或其他工業財產權之註冊申請承認優先權時，香港或澳門居民、法人、團體或其他機構於香港或澳門為首次申請之翌日起十二個月內向經濟部申請者，得主張優先權。 前項所定期間，於新式樣專利案或商標註冊案為六個月。	1. 平等互惠條款
個人資料保護法第 21 條	非公務機關為國際傳輸個人資料，而有下列情形之一者，中央目的事業主管機關得限制之： 一、涉及國家重大利益。 二、國際條約或協定有特別規定。 三、接受國對於個人資料之保護未有完善之法	2. 涉及外國人在本國、本國人在外國或國際事務之規定。 5. 限制或處罰之法定

	規，致有損當事人權益之虞。 四、以迂迴方法向第三國（地區）傳輸個人資料規避本法。	要件。
原住民族傳統智慧創作保護條例第 21 條	中華民國政府與外國政府簽訂有關智慧創作保護之條約或協定者，從其規定。	6. 特別法之規定。
海上捕獲條例第 25 條	對於左列船舶應行拿捕： 一、敵船應逕行拿捕。但左列各船舶不參與軍事行動時，不在此限： 甲、專作沿岸捕魚用之船舶，或從事當地貿易之小船及其船內器具、貨物。 乙、從事宗教、科學、慈善事業之船舶。 丙、公曆一九〇七年海牙推行日內瓦條約原則於海戰條約所稱之病院船。 丁、俘虜交換船。 二、未得中華民國政府特許而與敵國通商航行之本國船舶。 三、中華民國或同盟國或中立國船舶有左列情形之一者： 甲、載運戰時禁制品前往敵國或其武裝部隊，或確悉其將經由中立國港口轉運至敵國或其武裝部隊，或載運戰時禁制人之船舶。 乙、破壞封鎖之船舶。 丙、為敵國刺探軍情或有參戰、助敵行為之船舶。 丁、受敵國軍艦或飛機護送之船舶。 戊、抗拒臨檢或搜索之船舶。 己、船舶文書，依法應具備而未完備，或有隱匿、毀棄、偽造、塗改情形之船舶。 庚、受敵國政府租賃之船舶。	5. 限制或處罰之法定要件。
國立中正文化中心設置條例第 36 條	本中心之採購作業，應本公開、公平之原則，並應依我國締結簽訂條約或協定之規定，由本中心擬訂採購作業實施規章，報請監督機關核定後施行，不受政府採購法之限制。	3. 例外或除外規定。 4. 補充性規定。
國防法第 34 條	友好國家派遣在中華民國領域內之軍隊或軍人，其權利義務及相關事宜，應以條約或協定	2. 涉及外國人在本國、本國人在外國

	定之。 外國人得經國防部及內政部之許可，於中華民國軍隊服勤。	或國際事務之規定。
國家賠償法第 15 條	本法於外國人為被害人時，以依條約或其本國法令或慣例，中華民國人得在該國與該國人享受同等權利者為限，適用之。	1. 平等互惠條款。
專利法第 4 條	外國人所屬之國家與中華民國如未共同參加保護專利之國際條約或無相互保護專利之條約、協定或由團體、機構互訂經主管機關核准保護專利之協議，或對中華民國國民申請專利，不予受理者，其專利申請，得不予受理。	1. 平等互惠條款。
專利法第 102 條	未經認許之外國法人或團體，就本法規定事項得提起民事訴訟。	1. 平等互惠條款。
組織犯罪防制條例第 15 條	為防制國際性之組織犯罪活動，政府或其授權之機構依互惠原則，得與外國政府、機構或國際組織簽訂防制組織犯罪之合作條約或其他國際協定。	1. 平等互惠條款。
規費法第 12 條	有下列各款情事之一者，業務主管機關得免徵、減徵或停徵應徵收之規費： 一、各機關學校辦理業務或教育宣導。 二、各機關學校間協助事項。 三、重大災害地區災民因災害所增加之規費。 四、因處理緊急急難救助所負擔之規費。 五、老人、身心障礙者、低收入戶之身分證明文件。 六、基於國際間條約、協定或互惠原則。 七、其他法律規定得免徵、減徵或停徵者。	1. 平等互惠條款。 3. 例外或除外規定。
植物品種及種苗法第 11 條	外國人所屬之國家與中華民國未共同參加品種權保護之國際條約、組織，或無相互品種權保護之條約、協定，或無由團體、機構互訂經中央主管機關核准品種權保護之協議，或對中華民國國民申請品種權保護不予受理者，其品種權之申請，得不予受理。	1. 平等互惠條款。
植物品種及種苗法第 43 條	未經認許之外國法人或團體，依條約、協定或其本國法令、慣例，中華民國國民或團體得在該國享受同等權利者，就本法規定事項得提起民事訴訟；其由團體或機構互訂保護之協議，經中央主管機關核准者，亦同。	1. 平等互惠條款。

植物品種及種苗法第 51 條	種苗、種苗之收穫物或其直接加工物應准許自由輸出入。但因國際條約、貿易協定或基於保護植物品種之權利、治安、衛生、環境與生態保護或政策需要，得予限制。 前項限制輸出入種苗、種苗之收穫物或其直接加工物之種類、數量、地區、期間及輸出入有關規定，由中央主管機關會商有關機關後公告之。	5. 限制或處罰之法定要件。
著作權法第 4 條	外國人之著作合於下列情形之一者，得依本法享有著作權。但條約或協定另有約定，經立法院議決通過者，從其約定： 一、於中華民國管轄區域內首次發行，或於中華民國管轄區域外首次發行後三十日內在中華民國管轄區域內發行者。但以該外國人之本國，對中華民國人之著作，在相同之情形下，亦予保護且經查證屬實者為限。 二、依條約、協定或其本國法令、慣例，中華民國人之著作得在該國享有著作權者。	1. 平等互惠條款。 3. 例外或除外規定。 6. 特別法之規定。
貿易法第 6 條	有下列各款情形之一者，主管機關得暫停特定國家或地區或特定貨品之輸出入或採取其他必要措施： 一、天災、事變或戰爭發生時。 二、危害國家安全或對公共安全之保障有妨害時。 三、國內或國際市場特定物資有嚴重匱乏或其價格有劇烈波動時。 四、國際收支發生嚴重失衡或有嚴重失衡之虞時。 五、國際條約、協定、聯合國決議或國際合作需要時。 六、外國以違反國際協定或違反公平互惠原則之措施，妨礙我國輸出入時。 前項第一款至第四款或第六款之適用，以對我國經濟貿易之正常發展有不利影響或不利影響之虞者為限。 主管機關依第一項第四款或第六款暫停輸出入或採行其他必要措施前，應循諮商或談判途徑解決貿易爭端。	2. 涉及外國人在本國、本國人在外國或國際事務之規定。 5. 限制或處罰之法定要件。

	主管機關採取暫停輸出入或其他必要措施者，於原因消失時，應即解除之。 前條追認規定於本條適用之。	
貿易法第 11 條	貨品應准許自由輸出入。但因國際條約、貿易協定或基於國防、治安、文化、衛生、環境與生態保護或政策需要，得予限制。 前項限制輸出入之貨品名稱及輸出入有關規定，由主管機關會商有關機關後公告之。	5. 限制或處罰之法定要件。
貿易法第 20 條之 2	經濟部國際貿易局得應出口人輸出貨品之需要，簽發原產地證明書或加工證明書，並得收取費用。必要時，得委託其他機關、財團法人、工業團體、商業團體或農會、漁會、省級以上之農業合作社及省級以上之農產品產銷協會辦理之。 工業團體、商業團體或農會、漁會、省級以上之農業合作社及省級以上之農產品產銷協會對於出口貨品亦得簽發原產地證明書或加工證明書。但為履行國際條約、協定及國際組織規範或應外國政府要求之特定原產地證明書，且經經濟部國際貿易局公告者，未經該局核准，不得簽發。 簽發原產地證明書或加工證明書，不得有下列行為： 一、未依規定之格式、程序或收費數額簽發。 二、未經核准簽發前項但書之特定原產地證明書。 三、未依規定保存文件。 四、未保守出口人之營業秘密。 五、其他有損害我國商譽或擾亂貿易秩序之行為。 原產地證明書及加工證明書之格式、原產地認定基準、加工證明書核發基準、第一項委託及終止委託之條件、第二項辦理簽發與核准簽發之條件、申請時應檢附之文件、簽發程序、收費數額、文件保存期限及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。	3. 例外或除外規定。
貿易法第 21 條	為拓展貿易，因應貿易情勢，支援貿易活動，主管機關得設立推廣貿易基金，就出進口人輸	3. 例外或除外規定。

	出入之貨品，由海關統一收取最高不超過輸出入貨品價格萬分之四・二五之推廣貿易服務費。但因國際條約、協定、慣例或其他特定原因者，得予免收。 推廣貿易服務費之實際收取比率及免收項目範圍，由主管機關擬訂，報請行政院核定。 第一項基金之運用，應設置推廣貿易基金管理委員會，其委員應包括出進口人代表，且不得少於四分之一。 推廣貿易基金之收支、保管及運用辦法，由行政院定之。	
郵政法第 13 條	關於各類郵件或其事務，國際郵政公約或協定有規定者，依其規定。但其規定與本法牴觸者，除國際郵件事務外，適用本法之規定。	4. 補充性規定
個人資料保護法第 24 條	非公務機關為國際傳遞及利用個人資料，而有下列情形之一者，目的事業主管機關得限制之： 一、涉及國家重大利益。 二、國際條約或協定有特別規定。 三、接受國對於個人資料之保護未有完善之法令，致有損當事人權益之虞。 四、以迂迴方法向第三國（地區）傳輸個人資料規避本法。	5. 限制或處罰之法定要件。
管理外匯條例第 4 條	管理外匯之行政主管機關辦理左列事項： 一、政府及公營事業外幣債權、債務之監督與管理；其與外國政府或國際組織有條約或協定者，從其條約或協定之規定。 二、國庫對外債務之保證、管理及其清償之稽催。 三、軍政機關進口外匯、匯出款項與借款之審核及發證。 四、與中央銀行或國際貿易主管機關有關外匯事項之聯繫及配合。 五、依本條例規定，應處罰鍰之裁決及執行。 六、其他有關外匯行政事項。	6. 特別法之規定。

資料來源：作者製表

※表列法條，按法律名稱首字筆畫順序排列

附錄四：援引國際條約之法律規定（二）

法律援引模式	法律名稱
1. 平等互惠條款。	土地法第 18 條 公平交易法第 47 條 民用航空法第 72 條、第 75 條、第 80 條 民事訴訟法第 108 條 刑事補償法第 36 條 洗錢防制法第 9 條、第 14 條、第 15 條、第 16 條 香港澳門關係條例第 36 條、第 37 條 國家賠償法第 15 條 專利法第 4 條、第 91 條 組織犯罪防制條例第 15 條 規費法第 12 條 植物品種及種苗法第 11 條、第 43 條 著作權法第 4 條
2. 涉及外國人在本國、本國人在外國或國際事務之規定。	引渡法第 1 條、第 6 條 民用航空法第 47 條之 3、第 78 條 放射性物料管理法第 7 條 律師法第 47 條之 10 政府採購法第 105 條、第 106 條 洗錢防制法第 16 條 個人資料保護法第 21 條 貿易法第 6 條
3. 例外或除外規定。	民用航空法第 47 條之 3、第 74 條之 1 民防法第 29 條 政府採購法第 105 條 國立中正文化中心設置條例第 36 條 規費法第 12 條 著作權法第 4 條 貿易法第 20 條之 2、第 21 條
4. 補充性規定。	文化資產保存法第 25 條 行政法人法第 37 條 國立中正文化中心設置條例第 36 條
5. 限制或處罰之法定要件。	民用航空法第 115 條 海上捕獲條例第 25 條

	植物品種及種苗法第 51 條 個人資料保護法第 21 條 貿易法第 6 條、第 11 條
6. 特別法之規定。	所得稅法第 124 條 政府採購法第 43 條、第 44 條 科學技術基本法第 6 條 原住民族傳統智慧創作保護條例第 21 條 管理外匯條例第 4 條 著作權法第 4 條
7. 行政程序規範。	政府採購法第 75 條

資料來源：作者製表

附錄五：關於國際條約效力位階之裁判

裁判字號	爭 點	內 文
最高法院 23 年 上字第 1074 號 刑事判例	上海公共租界內中國法院之協定第 5 條第 2 項是否優先於國內法適用？	上海公共租界內設置之法院，其土地管轄應以案件在各該法院管轄區域內發生者為限，此徵之關於上海公共租界內中國法院之協定第 5 條第 2 項所載，其他案件在各該法院管轄區域內發生者，應由工部局捕房起訴云云，至為明顯。國際協定之效力優於國內法，該協定關於土地管轄，既有此特別規定，自無適用刑事訴訟法第 13 條之餘地。
最高法院 72 年 台非字第 228 號刑事判決	美國公司在華未經認許，是否仍有告訴及自訴之能力？	非常上訴理由稱：按條約之簽訂，須由立法機關審議通過，經國家元首批准並公布，締約之程序，與法律案須經立法機關審議通過國家元首公布施行者，大致相同，故條約與國內法有同等效力，且條約係就締約國間之特別事項而為規定，依國際法應遵守國際信義之慣例，世界上絕大多數國家均認條約具有特別法之性質，其效力尤優於國內法，我國司法院民國二十年七月二十七日致前司法行政部第四五九號訓令，略謂：「原則上法律與條約抵觸，應以條約之效力為優，若條約批准在後或與法律頒布之日相同，自無問題，若批准在頒布之前，應將抵觸之點隨時陳明候核。」最高法院二十三年上字第一〇七四號判例，亦謂：「國際協定之效力，優於國內法。」
最高法院 72 年 台上字第 1412 號民事判決	中華民國與美利堅合眾國友好通商航海條約性質為何？	中華民國與美利堅合眾國友好通商航海條約，於民國三十五年十一月四日簽訂，經立法院議決批准公布，並於三十七年十一月三十日互換，同日生效，依我國憲法第一百四十一條所定「尊重條約」及同法第六十三條所定條約定須經立法院議決之規定以觀，該友好通商航海條約，實已具有國內法之同等效力，法院自應予適用。
最高法院 74 年 台非字第 137 號刑事判決	中美友好通商航海條約是否優先於國內法適用？	本件原判決既認國際協定之效力優於國內法，中美友好通商航海條約又已於民國三十七年十一月三十日生效，雖中美兩國於六十八年一月一日終止外交關係，但據雙方達成之協議，……自應繼續有效，……此項條約之規定，其效力既應優於國內法，則本件美商永備聯合電石公司……，提

		起第二審上訴，原第二審判決竟亦以同一理由予以維持，駁回其第二審上訴而確定，自有不適用國際協定優於國內法法則之違法，……。
最高行政法院 92 年度判字第 1399 號判決	就業服務法 限制外國人 工作權	經查：(一)、原告係持美國護照，不具我國國籍，亦未具就業服務法第四十八條規定身分，其欲在華工作，應依就業服務法第四十二條之規定，由其雇主向目的事業主管機關或該會申請許可後方得在我國境內工作，其工作項目以就業服務法第四十三條第一項第九款規定為限，原告擬從事餐廳清潔工作，非屬就業服務法第四十三條第一項所列第九款工作項目，而各目的事業主管機關對外國人在中華民國境內受聘僱工作，均需由其雇主向該管目的事業主管機關申請核發聘僱許可，並非核發開放式工作證。(二)、我國憲法所保障者為本國人民之基本權利，原告不具我國國籍，非中華民國國民，尚難與中華民國國民享有相同平等之基本權利與義務。又國際法上對境內外國人之待遇，係按國際法原則，以平等互惠之相互主義賦予外國人應有之地位、待遇，國家給予境內外國人之待遇除基本人權外，原則上由國內法自行規定。
最高行政法院 93 年度判字第 281 號判決	得否依中華民國美利堅合眾國友好通商航海條約第 9 條直接適用美國專利法 41 條 c 項 1 款？	按國際法與國內法為平行之法律體系，且均為行政法之法源；惟國際法要成為行政法之法源，並非毫無限制，必須條約或協定明定其內容，始可直接引用作為法規適用。或將條約、協定內容，透過國內法規之訂定，訂定於相關法規，才能有效執行外，必須司法審判機關採用，作為判決先例。一般而言，於國際法與國內法衝突時，國際法之效力應優先於國內法；但其應具上開要件，始有優先於國內法適用之餘地，合先敘明。

資料來源：作者製表

附錄六：關於國際條約效力位階之行政函釋

字號	爭點	機關	內文
72 年 2 月 21 日法律字第 1813 號	條約在我國國內法之效力？	法務部	條約在我國憲法及有關法律中均未明文規定其具有國內法的效力，但立法院審查條約案時，與審查法律案的程序完全相同，條約亦和其他立法院通過的法律一樣，均刊登在立法院公報及立法專刊中，是條約在我國應具有國內法之效力。復從憲法第一百四十一條精神以觀，條約與國內法牴觸時，似宜優先適用條約。
(79) 法律字第 10900 號	我國與他國訂定之行政協定（不論該國與我國有無邦交）其法律地位如何？	法務部	(二) 另查司法院於民國二十年七月二十七日以訓字第四五九號函訓示（前）司法政部：「查原則上法律與條約牴觸，應以條約之效力為優。若條約批准在後，或與法律頒布之日相同，自無問題。若條約批准在法律頒布之前，應將其牴觸之點，隨時陳明候核。」前開司法院訓示，已明確宣示條約效力，原則上優於國內法。最高法院二十三年上字第一〇七四號判例亦謂：「國際協定之效力優於國內法」。「立法院係於民國三十七年五月八日成立，上開判例成立時，尚無立法院，則判例內所稱之『國際協定』，是否泛稱一切之協定？有待探討。」另我國法院實務見解就一般而論（賀最高法院七十三年度台非字第六九號刑事判決為例），亦傾向於條約（協定）具有特別法性質，其效力應優於國內法。 (三) 我國與無邦交國家締結之協定，其地位宜與我國與有邦交國家締結之協定同視（以中美終止外交關係後，雙方以「中華民國北美事務協調委員會」暨「美國在臺協會」名義簽訂之協定為例，宜視「中華民國北美事務協調委員會」與「美國在臺協會」，分別係中美兩國政府之「代理人」，從而以其名義所簽訂之協定，在國際法上應被賦與類似具有官方關係之兩國所簽訂之協定。）綜上所述，依憲法第一百四十一條之精神及法院判例（決）之意旨，條約（協定）與國內法牴觸時，宜優先適用前者。蓋條約（協定）係就締約國間之特別事項而為規範，依國際社會討

			遵守國際信義之慣例，締約國有義務不制定違反條約（協定）之法律或於兩者衝突抵觸時，優先適用條約（協定）。我與無邦交國家訂定之各種行政協定，是否應經立法院同意程序？ 三、不論我國與有無邦交國家所簽訂之協定，若內容涉及人民權利義務、國家各機關組織、或其他重要事項應以法律定之者，則協定締結之作用，並非單純之行政行為，宜視為一種立法行為，參照中央法規標準法第五條之精神，上開協定宜經立法院之同意程序，俾使該協定與我國內法具有同等地位，並以「特別法」之型態，優先於國內法而予適用。如此方能符合前揭憲法法條並重條約（協定）之精神及法院判例（決）之意旨，與遵守國際信義之國際慣例。（本部七十二年二月二十一日法（七二）律字第一八一三號函，亦持相同見解）。
(60) 台內字第 7317 號	經核准喪失國籍後因未取得他國國籍再聲請回復國籍時准予註銷原發喪失國籍許可證明書並回復設籍	行政院	依國際法適用原則，凡經一國國會通過並經批准之國際公約，其效力應優先於各該國內法而適用，本案我國國籍法第十六條對於申請回復國籍者，雖加以若干條件之限制，惟上開國際聯合國國籍法公約第七條明定在取得另一國籍前不應有喪失國籍之效果，其規定之效力，自應優先於我國國籍法而適用，關於旅菲華僑陳天保及陳秀珍等五人申請回復國籍乙節，可依該部與有關單位會商之結論第一項照上開國籍法公約第七條規定辦理。附註：本部六十年四月廿九日為商討菲律賓僑聲請回復國籍邀請有關單位開會，所獲結論第一項：「國際聯合國國籍法公約之規定既然優於國籍法，關於聲請回復國籍案即按照國際聯合國國籍法公約第七條：「一國之法律規定發給出籍許可證明書，倘領得證書之人非有另一國籍時，此項證書對之不應有喪失國籍之效果。」之規定辦理。

資料來源：作者製表